

José Sérgio da Silva Cristóvam

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO

**Novo Regime
Jurídico-Administrativo e seus
Princípios Constitucionais Estruturantes**



**Apresentação de Ubaldo Cesar Balthazar
Prefácio de Humberto Ávila**

JURUÁ
EDITORA

comuns na atualidade, que falseiam e encobrem interesses egoísticos e parciais sob uma densa cortina de fumaça, envolvidos sob os quase sempre oscilantes e casuísticos contornos de um “interesse público”, quase que revelado de forma mítica ou divina por autoridades usurpadoras da legítima e democrática vontade, construída a partir do consenso soberano do povo e assentada nas Constituições contemporâneas.

De toda essa recuperação histórica do rico pensamento político ocidental, pode-se conceber que a noção de bem comum constitui-se a partir de uma constante moral, um conceito indeterminado (mas determinável) que guarda destacada relevância e ingerência na relação de integração entre os interesses individuais ou de grupos de pessoas com os interesses gerais de uma comunidade política. Ainda que a noção de bem comum possa trazer em si a ideia de negação e contraposição a interesses individuais ou corporativos, que acabariam por sucumbir aos “interesses maiores” da coletividade, um conceito moralmente legítimo de bem comum deve surgir da afirmação desse caldo de diversidades e (aparentes) contradições de interesses dos mais variados matizes e não da construção de um pensamento unitário ou da unanimidade em torno das questões de interesse coletivo ou geral.

Não se pode jamais esquecer que a construção da coletividade parte do indivíduo, que tem aspirações próprias e legítimas e que não podem ser ignoradas ou sufocadas pelo sentimento coletivo. O adequado balanceamento e composição desses interesses, por vezes conflitantes, parece ser o ponto de equilíbrio necessário à efetiva construção de uma comunidade política justa e capaz de alcançar aquele bem comum supremo aristotélico: a felicidade!

Inegavelmente, a dinâmica sociopolítica conduz à diversidade e contraposição de interesses, cabendo aos poderes constituídos não a imposição de valores unitários e perpétuos (fundados em verdades monolíticas e excludentes), mas a construção de consensos inclusivos, gestados a partir dessa assimetria social, “*capazes de originar uma unificação de vontades*”⁶⁷.

Estabelecida essa breve genealogia político-jurídica da noção de bem comum, convém prosseguir agora na análise dos contornos do conceito de interesse público a partir do advento do Estado moderno, desde as suas acepções características do Estado liberal, passando pelo Estado social e culminando com as reformulações que têm marcado esse período posterior à Segunda Guerra Mundial, na busca de elementos constitutivos de um adequado conceito de interesse público na contemporaneidade. Essa será a temática do próximo capítulo.

⁶⁷ Nesse sentido: BITTENCOURT, Juliana Castilho. **Interesse público e vontade geral: constatações do desvio de finalidade**. 2008. 112 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, 2008. p. 34.

Capítulo 2

PARA UM CONCEITO DE INTERESSE PÚBLICO

Em uma ordem constitucional caracterizada pelo movimento de constitucionalização de uma complexa, dinâmica e até (na prática) colidente gama de direitos fundamentais (interesses individuais e coletivos), a problemática da concretização e defesa destes legítimos interesses passa pela reconformação dos parâmetros do regime jurídico-administrativo, a partir dos contornos e limites de um conceito de interesse público afinado a esse novo quadrante constitucional.

Isto impõe, inclusive, a revisão da tradicional centralidade do princípio da supremacia do interesse público, propalado como princípio estruturante do regime jurídico-administrativo, a ser superado pelos novos vetores normativos do Estado constitucional de direito, fundados na defesa dos direitos fundamentais e no primado da dignidade humana.

Conforme já se disse alhures⁶⁸, a ideia da supremacia do interesse público, alçada à condição de “*verdadeiro axioma do moderno Direito Público*”⁶⁹, acabou por ser entronada no posto máximo e inapelável de justificação de toda a atividade administrativa. Como um claro “**mantra de legitimação da atividade administrativa**”, o argumento da supremacia do interesse público tudo explica e tudo justifica, inclusive escamoteando toda sorte de arbitrariedades, autoritarismos e ofensas a princípios constitucionais (mormente a impessoalidade e a moralidade admi-

⁶⁸ Algumas das considerações sobre o conceito de interesse público no Estado constitucional de direito, aqui debatidas, já foram abordadas anteriormente, ainda que de forma introdutória, no seguinte texto: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. O conceito de interesse público no Estado constitucional de direito. **Revista da ESMESC**. Florianópolis, v. 20, n. 26, p. 223-248, 2013.

⁶⁹ MELLO, **Curso de Direito Administrativo...**, p. 58.

nistrativa). Tudo passou a ser “magicamente legitimado” a partir de uma retórica frouxa e órfã de racionalidade, o que não escapou à percuciente crítica de Lenio Luiz Streck, para quem o interesse público se traduz atualmente em uma “expressão que sofre de intensa ‘anemia significativa’, nela ‘cabendo qualquer coisa’”⁷⁰.

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Na literatura jurídica nacional pós-abertura constitucional e democrática, coube a José Eduardo Faria uma das primeiras análises críticas da noção de interesse público⁷¹, já atento à inafastável problemática dos recorrentes conflitos entre legítimos interesses contrapostos (públicos e privados), traço comum em uma Constituição aberta e pluralista como a brasileira. Denunciando o caráter excessivamente vago e genérico do conceito de interesse público, Faria o descreve como “um conceito quase mítico, cujo valor se assenta justamente na indefinição de seu sentido e que, por ser facilmente manipulável por demagogos, populistas e tiranos da vida pública, acaba sendo analiticamente pobre”⁷².

Com efeito, este é o cenário jurídico-político no qual se insere a tônica central do debate aqui travado: partindo da premissa de que o Estado constitucional de direito, fundado na teoria dos direitos fundamentais⁷³ e na

⁷⁰ A expressão é de Lenio Luiz Streck, em artigo publicado no sítio “Consultor Jurídico”, onde aborda a problemática dos limites à atuação do Poder Judiciário e o desprestígio à lei, a partir da multifuncional e oca retórica da defesa do “interesse público”. STRECK, Lenio Luiz. Ministros do STJ não devem se aborrecer com a lei. *Revista Eletrônica Consultor Jurídico*. São Paulo, jun. 2012. Disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2012-jun-07/senso-incomum-nao-aborrecer-lei-ministra-nancy-andrighi>>. Acesso em: 10 jun. 2012.

⁷¹ Importa assinalar que são raros os estudos específicos e aprofundados acerca do conceito de interesse público, tanto na doutrina nacional como na estrangeira. Isso, inclusive, não escapou à crítica do administrativista lusitano Luís Filipe Colaço Antunes, que expressamente denuncia esse esquecimento do interesse público pelo discurso juspublicista, relegado a alguns pares de linhas dos manuais de Direito Administrativo. Nas palavras de Antunes: “*apetece perguntar por que razão a noção categorial de interesse público tem sido votada, nas últimas décadas, ao ostracismo pelos administrativistas?*”. ANTUNES, Luís Filipe Colaço. *O Direito Administrativo e a sua Justiça no início do século XXI*: algumas questões. Coimbra: Almedina, 2001. p. 14.

⁷² FARIA, José Eduardo. Antinomias jurídicas e gestão econômica. Lua Nova: *Revista de Cultura e Política*. São Paulo, n. 25, p. 167-184, abr. 1992, p. 173.

⁷³ O debate acerca da teoria dos direitos fundamentais será realizado no subitem 4.3.1 do capítulo quarto. Para uma análise panorâmica sobre o tema, consultar: SARLET, Ingo

centralidade do princípio da dignidade humana⁷⁴, engendra e reclama uma profunda redefinição dos contornos do regime jurídico-administrativo, impõe-se a construção de um conceito de interesse público compatível com esta nova engenharia constitucional, indelevelmente marcada pelo traço humanista⁷⁵ da “personalização da ordem normativa constitucional”.

A empreitada de construção do conceito de interesse público não pode negligenciar a análise, ainda que breve, das diferentes concepções que fundam a noção de Estado moderno, o que influencia de forma direta e inequívoca os contornos da atual noção de interesse público no Estado constitucional de direito.

2.2 SOBRE A NOÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO NO ESTADO MODERNO

A doutrina política atribui o “moderno” emprego do termo “Estado” (*status*), na intenção de configurar sociedades políticas organizadas e permanentes, ao já citado livro “*O Príncipe*”, obra que representa um importante marco para a ciência política e para o estudo da teoria do Estado, cabendo, para muitos, a Maquiavel o título de “*fundador da ciência política*”⁷⁶.

Ainda que seja bastante controverso e equívoco o conceito de Estado, Paulo Bonavides o apresenta em três acepções basilares: a filosófica, a jurídica e a sociológica. Do ponto de vista filosófico, o Estado pode ser definido como a “*realidade da ideia moral*”, a “*substância ética consciente de si mesma*”, a “*manifestação visível da divindade*”. No sentido jurídico, a partir da doutrina kantiana, o Estado pode ser entendido como a “*reunião de uma multidão de homens vivendo sob as leis do Di-*

Wolfgang. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

⁷⁴ A análise do princípio da dignidade da pessoa humana será realizada no item 6.2 do capítulo sexto. Apenas para adiantar, sobre o tema consultar: SARLET, Ingo Wolfgang. *Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988*. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.

⁷⁵ Para uma abrangente análise do humanismo a partir de uma ampla recuperação histórica das suas bases, desde a Antiguidade pré-socrática, passando pelo Medievo, Renascimento, até a Modernidade e o conhecimento transpessoal, consultar: OLIVEIRA, Odete Maria de. *Conceito de homem*: mais humanista, mais transpessoal. Ijuí: Unijuí, 2006.

⁷⁶ ARON, Raymond. *Prefácio da obra o Príncipe*. Tradução de Maria Júlia Goldwaser. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. XI.

reito”⁷⁷. Por fim, sob o prisma sociológico, o Estado constituir-se-ia em uma “instituição social, que um grupo vitorioso impôs a um grupo vencido, com o único fim de organizar o domínio do primeiro sobre o segundo e resguardar-se contra rebeliões intestinas e agressões estrangeiras”. Nas palavras de Bonavides, o Estado representa a “corporaçã de um povo, assentada num determinado território e dotada de um poder originário de mando”⁷⁸.

Já para Dalmo de Abreu Dallari, a partir de um viés claramente aristotélico-tomista, o conceito de Estado deve ser marcado por uma finalidade central e precípua: a noção de bem comum. Partindo da ideia de bem comum propagada pela Doutrina Social da Igreja, com base na Carta Encíclica Paz na Terra (*Pacem in terris*) do Papa João XXIII (publicada em 11 de abril de 1963), que definiu o bem comum como o “conjunto de todas as condições de vida social que consistam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana”⁷⁹, Dallari conceitua o Estado como a “ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território”⁸⁰.

⁷⁷ O Estado de direito em Immanuel Kant (1724 – 1804 d.C.) tem um traço marcadamente jurídico. Conforme já defendido alhures, na doutrina kantiana o “que caracteriza a atividade do Estado é a atividade jurídica, a instituição e manutenção de um ordenamento jurídico como condição para a coexistência das liberdades externas. Não se fala em Estado de direito como o Estado regulado ou limitado pelo Direito. Trata-se, sim, de uma ideia de Estado em que haja a possibilidade de coexistência mútua entre os indivíduos, segundo uma lei universal de liberdade. Pode-se buscar, ainda, no pensamento kantiano um modelo de Estado de direito que assegura ‘o seu’ de cada um, em decorrência do princípio jurídico da liberdade que pode ser assim exposto: ‘Lesame qualquer um que aja conforme uma máxima segundo a qual é impossível ter como meu um objeto de meu arbítrio’; porque uma constituição civil é tão somente o Estado de direito que assegura a cada um o Seu; mas sem que esse estado o constitua nem o determine, propriamente falando’. A ideia de liberdade é a marca distintiva do Estado de direito kantiano. Um estado de coisas em que o arbítrio de cada um é limitado pelo arbítrio dos demais, segundo um imperativo da razão. O Estado de direito que garante as liberdades externas dos indivíduos, segundo uma lei universal de liberdade, na doutrina kantiana constitui-se em um Estado paulatinamente mais igualitário, vez que a ideia de liberdade em Kant encerra um postulado igualitário, a liberdade como princípio que deve valer para todos”. Nesse sentido: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. A doutrina do Direito de Immanuel Kant. In: MACHADO, Nivaldo et al. (Org.). *Pensar o Direito*. Rio do Sul: Unidavi, 2011. p. 121; KANT, Immanuel. *Doutrina do Direito*. Tradução de Edson Bini. 2. ed. São Paulo: Ícone, 1993.

⁷⁸ BONAVIDES, Paulo. *Ciência política*. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 57-68.

⁷⁹ Nesse sentido: Parágrafo 56 da Encíclica Paz na Terra. JOÃO XXIII, Papa. *Carta Encíclica Pacem in Terris*. Vaticano, 1963. Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem_po.html#_ftn36>. Acesso em: 26 out. 2013.

⁸⁰ DALLARI, Dalmo de Abreu. *Elementos de teoria geral do Estado*. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 118.

Sob a perspectiva da evolução histórica do Estado moderno e das razões do seu aperfeiçoamento, Wolkmer afirma que o Estado, “enquanto fenômeno histórico de dominação, apresenta originalidade, desenvolvimento e características próprias para cada momento histórico e para cada modo de produção”. Inclusive, isso “pode ser comprovado com a escravidão na antiguidade, com a subordinação plena das organizações políticas ao poder da Igreja no feudalismo e com a secularização e unidade nacional na modernidade”, o que permite considerar que “o moderno Estado centralizado é produto das condições estruturais inerentes ao capitalismo burguês europeu, não sendo, portanto, mero reflexo evolutivo ou aperfeiçoamento de outros tipos históricos de Estados anteriores (Estado Antigo, Cidade-Estado, Estado Medieval)”⁸¹.

2.2.1 O alvorecer do Estado Moderno: o Estado Absolutista

A atual noção de Administração Pública⁸² e o conceito de interesse público guardam visceral ligação histórica e sociopolítica com a ideia de Estado moderno, que sucedeu ao feudalismo medieval. Há, inclusive, consolidado entendimento de que o próprio ramo do Direito Administrativo como “direito da Administração”, na sua moderna acepção, estruturou-se a partir da formação do Estado de direito, de feição liberal-individualista, como instrumento de limitação dos poderes constituídos, sob o primado da separação de poderes – a partir da distinção das três funções precípua do Estado (a legislativa, a executiva e a judicial)⁸³.

⁸¹ WOLKMER, Antonio Carlos. *Elementos para uma crítica do Estado*. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1990. p. 21.

⁸² A fim de sanar quaisquer confusões semânticas, o uso da expressão escrita com letras minúsculas aqui se refere à atividade administrativa, restando à grafia com maiúsculas – Administração Pública – quando alusiva ao conjunto de entidades jurídicas que podem desenvolver a atividade administrativa. Nesse sentido, o acordo semântico proposto por Marcello Caetano. CAETANO, Marcello. *Manual de Direito Administrativo*. Coimbra: Livraria Almedina, 1991.v. I, p. 05-06. No mesmo sentido, ver: RIVEIRO, Jean. *Direito Administrativo*. Tradução Rogério Ehrhardt Soares. Coimbra: Almedina, 1981. p. 13.

⁸³ O tema das origens do Direito Administrativo moderno será retomado posteriormente, inclusive a partir de uma perspectiva crítica da “história oficial” e análise crítica da crítica. Apenas para adiantar, nesse último sentido: GABARDO, Emerson; HACHEM, Daniel Wunder. O suposto caráter autoritário da supremacia do interesse público e das origens do Direito Administrativo: uma crítica da crítica. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). *Direito Administrativo e interesse público: estudos em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello*. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 182-195.

Mas não se pode olvidar que, no alvorecer do Estado moderno, houve um modelo de governança bastante interessante e peculiar, no chamado Estado de polícia, comum à Monarquia Absolutista. No Estado de polícia, o governo encontra-se legalmente incondicionado, sem limites na sua atuação. A fonte de todo o Direito é a pessoa subjetiva do rei, representante divino na terra⁸⁴, sendo a sua vontade a lei suprema e a síntese de todos os interesses do Estado enquanto comunidade política. Nesta quadra, como adverte Marçal Justen Filho, no Estado absolutista “*não seria exagerado afirmar que a totalidade dos interesses públicos estava na titularidade do Estado. Aliás, confundia-se interesse público e interesse do soberano*”⁸⁵.

O rei é o criador, executor e julgador da e segundo a lei, podendo, entretanto, decidir contrariamente à norma que ele mesmo instituiu. Este modelo de Estado foi-se atenuando, gradativamente, primeiro com a separação entre a figura subjetiva do rei e as relações entre o fisco e os súditos, que passaram a não mais ser reguladas pelo Direito de Polícia (*jus polittiae*), mas pelo Direito Civil⁸⁶.

A separação entre o Estado propriamente dito, dotado de soberania e regulado pelo Direito de Polícia, e o Fisco, entidade de Direito Privado, destituída de soberania, é, certamente, um dos aspectos característicos do Estado absolutista. Desta forma, apenas o “*Fisco entra em relações jurídicas com os particulares, contrata, se obriga, comparece em juízo, só contra ele podem os particulares reivindicar direitos subjetivos*”⁸⁷.

O Estado absolutista pode ser situado historicamente como um Estado de transição, do que decorre sua destacada importância, na medida em que consolidou a centralização do poder político na figura do monarca, diferentemente do modelo descentralizado característico da organização política feudal, preparando o advento do Estado liberal, fundado no modo de produção capitalista.

⁸⁴ A evolução do absolutismo pode ser dividida em dois períodos: o primeiro, que se estende até princípios do século XVIII, em que a monarquia se firma no “direito divino”; e uma fase subsequente, quando se procura atribuir ao poder uma fundamentação racionalista dentro do ambiente de iluminismo dominante, conhecido como “despotismo esclarecido”. MIRANDA, Jorge. **Manual de Direito Constitucional: preliminares – o Estado e os sistemas constitucionais**. 6. ed. Coimbra: Coimbra, 1997. t. I, p. 80.

⁸⁵ JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de interesse público e a “personalização” do Direito Administrativo. **Revista Trimestral de Direito Público**. São Paulo, n. 26, p. 115-136, 1999, p. 116.

⁸⁶ Nesse sentido: DI PIETRO, Maria Silvy Zanella. **Discrecionalidade administrativa na Constituição de 1988**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 11-13.

⁸⁷ MIRANDA, **Manual de Direito Constitucional...**, p. 80.

2.2.2 Estado liberal de direito e interesse público

A superação do Estado absolutista pelo Estado de direito veio marcada pela consolidação do princípio da legalidade (razão de legitimação e limitação do poder estatal), sobretudo pelo respaldo aos interesses econômicos e políticos da burguesia emergente do século XVIII, sensivelmente influenciada pelo apogeu do pensamento iluminista, base do liberalismo e das lutas pela garantia de liberdade aos cidadãos frente aos governos despóticos. A burguesia emergente reclamava uma entidade política forte o bastante para garantir seus direitos à liberdade e à propriedade. Para o liberalismo clássico, base filosófica do Estado liberal de direito, a lei detinha a função de garantir, por meio do Estado, a segurança da burguesia, seu direito à “liberdade de propriedade” em sentido amplo⁸⁸.

Claramente fundado na ideia de soberania da legalidade (visceralmente vinculada ao conceito de vontade geral e voltada à proteção das

⁸⁸ No liberalismo clássico, a defesa da propriedade como direito natural do homem, pode ser recuperada a partir do pensamento político de John Locke (1632 – 1704 d.C.). Diferente do estado de natureza em Hobbes (constante guerra de todos contra todos), para Locke o estado de natureza não é, necessariamente, mau. Os homens são livres, iguais e independentes. Ordenam suas vidas e dispõem de seus bens segundo seus interesses. O direito à liberdade, à vida e à propriedade somente encontra limite na lei natural. E como não existem soberanos, ou todos são soberanos, vige a jurisdição recíproca, em que cada um é juiz em causa própria. Sempre que um bem é tolhido ou turbado, cabe à vítima da agressão julgar o caso, aplicando a lei natural, e executar a decisão. Esse seria o maior inconveniente do estado de natureza, já que o homem, sendo juiz em causa própria, não é imparcial, não pune e sim, se vinga do agressor. Daí a degeneração em estado de guerra. Com o contrato social cria-se a sociedade, em que os homens buscam a segurança de seu direito mais precioso, a propriedade, posto em perigo pela insegurança advinda da jurisdição recíproca do estado de natureza. Este não deve ser extinto e sim, corrigido, mantendo-se o direito natural à propriedade. A sociedade civil vem trazer segurança à propriedade, na medida em que o poder de julgar é posto nas mãos de um juiz imparcial. Os homens formam a sociedade não para preservar a vida ameaçada pela falta de leis, mas para consolidar o direito natural à propriedade. Para Locke, o principal direito a ser defendido é o direito à propriedade, que é adquirida pelo homem mediante o emprego de seu trabalho, pelo qual o homem modifica um dado objeto transformando-o em sua propriedade, distinta da propriedade comum dos demais. Mas na teoria política de Locke, não se pode reduzir a noção de propriedade à ideia corrente de bens tangíveis, já que, em sentido amplo, a propriedade englobaria também diversos outros direitos, como o próprio direito à liberdade e à vida. Nesse sentido, consultar: LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo: ensaio relativo à verdadeira origem, extensão e objetivo do governo civil. 2. ed. São Paulo: Abril, 1978; ABAL, Rafael Peixoto. O pensamento político de John Locke. In: WOLKMER, Antonio Carlos (Org.). **Introdução à história do pensamento político**. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 140-153.

liberdades individuais), pode-se dizer que o advento do Estado de direito dependeu de um conjunto de condições determinantes. Neste quadrante, vale ressaltar, inicialmente, a construção política de um poder estatal unitário e o fenômeno do Direito positivado. Na mesma linha, é central a importância da burguesia, enquanto classe interessada na mudança da estrutura de poder e detentora dos meios necessários para desencadeá-la, bem como a separação entre o Estado e a Sociedade, sob a aspiração de que a prosperidade desta seria atingível a partir de decisões livres das vontades individuais. Por fim, jogou papel central “*a ruptura revolucionária com o poder estatal tradicional e, por consequência, a necessidade de constituir um novo poder estatal legítimo e compatível com a autonomia da sociedade*”⁸⁹.

Na verdade, convém ressaltar que a expressão “Estado liberal de direito” é aqui empregada pelo de fato estar consagrada pela doutrina jurídico-política, ainda que não pareça a mais adequada. Para tomar como exemplo o caso brasileiro, em última análise o atual modelo de Estado também apresenta um rol de direitos de caráter liberal (direitos de liberdade), porquanto fundado sobre uma ordem constitucional que garante diversos direitos individuais típicos do liberalismo clássico, como atestam vários dos incisos do art. 5º da Constituição Federal e outros dispositivos normativos espalhados pelo texto constitucional. Mas isso não autoriza dizer, por outro lado, que o Estado constitucional brasileiro está fundado em uma Constituição liberal.

Sem embargo, o Estado cada vez mais diminui sua intervenção em alguns setores da economia. Ainda que, de forma aparentemente contraditória, promova sensíveis medidas de intervenção em situações pontuais, como para realizar operações de salvamento do sistema financeiro, conduzindo-se a uma forma muito peculiar e cambiante de Estado mínimo para alguns setores (sociais e econômicos), mas intervencionista/protecionista em outras esferas.

Assim, parece que para fazer referência ao modelo de Estado típico do liberalismo clássico seria mais adequado falar em “Estado legal de direito”, uma vez que, com a derrocada do Estado absolutista e a ascensão do Estado de direito, houve, de fato, uma verdadeira substituição do império da vontade do monarca (governos dos homens) pelo império da vontade da lei (governo das leis)⁹⁰, uma espécie de *totem* da racionalidade

⁸⁹ GABARDO; HACHEM, *O suposto caráter autoritário...*, p. 164.

⁹⁰ Na obra *O Futuro da Democracia*, Bobbio promove uma interessante reflexão acerca da contraposição entre dois diferentes sistemas de exercício do poder (modelos de dominação), que designa como o “governo dos homens” e o “governo das leis”, a par-

dade moderna. A lei passou a ser a vontade soberana, à qual deveriam estar submetidos o Estado e os cidadãos.

No Estado de direito de modelo liberal oitocentista, o conceito de interesse público estava claramente radicado na proteção daquele peculiar modelo de individualismo. Para a sociedade liberal-burguesa que se consolidou até os finais do século XVIII, o papel destacado do Estado residia na defesa das liberdades individuais e na proteção dos particulares em face do próprio Estado. Por conseguinte, a concepção liberal de defesa do interesse público está fundada na garantia do conjunto de interesses privados, notadamente (mas não exclusivamente) na esfera do liberalismo econômico, sendo que “*o bem comum não era algo materialmente definido pelo Estado ou pela coletividade: ele estaria no livre desenvolvimento das vontades individuais, limitadas às fronteiras estabelecidas pela lei*”⁹¹.

Neste sentido, pode-se falar em um “constitucionalismo de primeira dimensão”, de feição marcadamente liberal-individualista, a partir do modelo de Estado legislativo-abstencionista, do que podem figurar como exemplos a Constituição estadunidense de 1787 e a Constituição francesa de 1791, fundada essencialmente na defesa dos chamados “direitos de primeira geração”⁹². Na verdade, sobre as bases de um modelo liberal-abstencionista de Estado de direito, erigido a partir de uma sociedade individualista em formação (burguesia), o papel do Estado na satisfação do interesse público estava muito mais vinculado a uma expressão negativa (não intervencionista), garantidor do exercício da autonomia da vontade privada dos indivíduos que compunham o tecido social. A busca da felicidade (bem supremo aristotélico-tomista) e o alcance dos bens da vida necessários a sua satisfação estavam situados na esfera das preocupações do indivíduo (esfera privada), não se constituindo (nem indiretamente) em responsabilidade público-estatal (interesse público).

O Estado e as leis deveriam estar a serviço da defesa das liberdades individuais (em especial no jogo econômico), pelo que o interesse

tir da recuperação do pensamento político ocidental. Nesse sentido: BOBBIO, Norberto. *O futuro da democracia*: uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 151-171. Para um estudo mais aprofundado sobre essa parte do pensamento político de BOBBIO, consultar: MELLO, Sérgio Cândido de. *Norberto Bobbio e o debate político contemporâneo*. São Paulo: Annablume, 2003. p. 22-32.

⁹¹ GABARDO; HACHEM, *O suposto caráter autoritário...*, p. 173.

⁹² A expressão “direitos de primeira geração” é retirada da obra de BOBBIO, a significar aqueles chamados “direitos de liberdade”, “liberdades públicas” ou “direitos negativos”. Nesse sentido: BOBBIO, Norberto. *A era dos direitos*. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 7. tir. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 09.

público estaria resumido e restaria cumprido a partir da proteção dos direitos e interesses dos indivíduos (livre-iniciativa privada), enquanto partes integrantes da sociedade que se constituiria por meio do desenvolvimento autônomo daqueles.

2.2.3 A noção de interesse público no Estado social de direito

A feição liberal-abstencionista de Estado de direito e de interesse público, construída a partir de uma (pouco adequada) visão homogeneizante dos interesses sociais e insensível a uma profunda situação de desigualdade social, fortemente recrudescida, sobretudo, a partir da Revolução Industrial⁹³, começou a ceder espaço ao advento do “Estado social de direito”.

Os marcos normativos originários da passagem do Estado liberal para o Estado social de direito são comumente recuperados a partir das Constituições mexicana de 1917 e alemã de 1919, aqui designado como “constitucionalismo de segunda dimensão”, de feição marcadamente social e fundada em um modelo de Estado prestacionista e intervencionista, a partir da normatização de um extenso rol de direitos sociais (direitos de segunda geração)⁹⁴. Entretanto, a evolução de um modelo estatal intervencionista, com certa ampliação do reconhecimento (embora quase que exclusivamente normativo) de direitos sociais, já pode ser notada na Alemanha desde a segunda metade do século XIX, em concomitância com a crise do modelo liberal-individualista de Estado⁹⁵.

⁹³ Para estudos mais aprofundados sobre a Revolução Industrial e suas influências e desdobramentos na sociedade moderna, pode-se consultar: HOBBSAWM, Eric J. *A era das revoluções: 1789-1848*. Tradução de Marcos Penchel e Maria L. Teixeira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009; HOBBSAWM, Eric J. *Da revolução industrial inglesa ao imperialismo*. Tradução de Donaldson Magalhães Garschagen. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011.

⁹⁴ Na difundida classificação proposta por Bobbio, os chamados “direitos de segunda geração”, típicos de um constitucionalismo social, referem-se, em geral, a interesses difusos e coletivos relacionados a dignas condições de trabalho, saúde, educação, previdência etc. Nesse sentido: BOBBIO, *A era dos direitos...*, p. 09.

⁹⁵ Para um estudo aprofundado acerca do Estado liberal e a passagem para o Estado social, pode-se consultar: BONAVIDES, Paulo. *Do Estado liberal ao Estado social*. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1996; LUCAS VERDÚ, Pablo. *Estado liberal de derecho y Estado social de derecho*. Madrid: Universidad de Salamanca, 1955; PEREZ LUNO, Antonio Enrique. *Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución*. 5. ed. Madrid: Tecnos, 1994.

Desse modo, pode-se recuperar como termo inicial de um modelo de Estado intervencionista de feições sociais, ainda que com devidas e acentuadas reservas históricas, sob um prisma muito mais formal que substancial, o governo do chanceler prussiano Otto Von BISMARCK (*Chanceler de Ferro*). Convém ressaltar, por outro lado, que durante o século XIX o papel constitucional dos direitos sociais ficava relegado à condição de meras cláusulas políticas de compromisso, no mais das vezes artificialmente concedidos por elites conservadoras ou liberais reformistas que pretendiam dessarte legitimar o Estado liberal, caracterizado pelo baixo intervencionismo para a contenção das desigualdades sociais, na tentativa de desarticular os movimentos sociais que buscavam um reconhecimento mais amplo de seus interesses. Exemplo paradigmático desse momento histórico é justamente o Estado social autoritário de BISMARCK, no qual os direitos sociais refletiam claras concessões outorgadas *ex principis* por oportunismo político e na intenção de neutralizar as crescentes demandas sociais, muito longe de se constituírem em verdadeiras conquistas decorrentes de movimentos sociais organizados⁹⁶.

A paulatina concretização de um modelo de Estado social de direito, caracterizado por uma perspectiva muito mais preocupada com a pessoa humana e pela busca da satisfação das suas necessidades por meio do aparato estatal (prestacionismo), trouxe consigo a normatização de uma extensa e prodigiosa carta de direitos sociais da pessoa enquanto coletividade (constitucionalismo de segunda dimensão), com a inequívoca reformulação tanto da estrutura estatal e suas responsabilidades (agigantamento do aparelho público), como dos contornos da própria noção de interesse público⁹⁷, mais afinada com os paradigmas de uma noção cristã de bem comum (*Cartas Encíclicas Rerum Novarum*⁹⁸ e *Pacem in Terris*⁹⁹) e de bem-estar geral.

⁹⁶ Para um estudo aprofundado sobre a evolução do Estado social e da efetivação dos direitos sociais, consultar: PISARELLO, Geraldo. Del Estado social legislativo al Estado social constitucional: por una protección compleja de los derechos sociales. *Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*. Alicante, n. 15, p. 81-107, 2001.

⁹⁷ Nas palavras de Antunes: “*De facto, um dos aspectos mais relevantes do Estado Social de Direito foi, sem dúvida, a intensificação da intervenção dos poderes públicos, com a consequente proliferação e massificação de interesses públicos, tantas vezes contraditórios entre si, numa dramática historicização e fragmentação do interesse público e do seu direito – o direito administrativo*”. ANTUNES, *O Direito Administrativo...*, p. 18.

⁹⁸ Pode-se buscar na vetusta Carta Encíclica *Rerum Novarum* (Das coisas novas), do Papa Leão XIII, datada de 15 de maio de 1891, uma posição da Igreja Católica Apostólica Romana sobre a noção de bem comum. Intitulada “*Sobre a condição dos operários*” e voltada a proclamar a necessidade de união e diálogo entre as classes do capi-

Com efeito, no Estado social de direito o Poder Público passa a assumir o protagonismo na consecução e na concretização dos direitos sociais, exigindo da Administração Pública uma postura muito mais ativa e prestacionista, por meio de ações positivas relacionadas à prestação de serviços públicos e à satisfação das necessidades coletivas. A condição

tal (burguesia) e do trabalho (proletariado), embora não abordasse direta e conceitualmente, a Carta Encíclica *Rerum Novarum* assim dispunha sobre o bem comum: “Mas, ainda que todos os cidadãos, sem exceção, devam contribuir para a massa dos bens comuns, os quais, aliás, por um giro natural, se repartem de novo entre os indivíduos, todavia as constituições respectivas não podem ser nem as mesmas, nem de igual medida. Quaisquer que sejam as vicissitudes pelas quais as formas do governo são chamadas a passar, haverá sempre entre os cidadãos essas desigualdades de condições, sem as quais uma sociedade não pode existir nem conceber-se [...] Sem dívida alguma, o bem comum, cuja aquisição deve ter por efeito aperfeiçoar os homens, é principalmente um bem moral”. Em outra passagem, resta assim sintetizado: “O fim da sociedade civil abrange universalmente todos os cidadãos, pois este fim está no bem comum, isto é, num bem do qual todos e cada um têm o direito de participar em medida proporcional. Por isso se chama público, porque ‘reúne os homens para formarem uma nação’”. LEÃO XIII, Papa. **Carta Encíclica Rerum Novarum**. Vaticano, 1891. Disponível em: <http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html>. Acesso em: 03 jan. 2014.

⁹⁹ Na célebre Carta Encíclica *Pacem in terris* (Paz na Terra), do Papa João XXIII, data de 11 de abril de 1963, a expressão *bem comum* apresenta 54 ocorrências, sendo que sua noção é construída política e filosoficamente, de forma ampla e conceitual pela Igreja Católica Apostólica Romana, quando defende que a realização do bem comum constitui a própria razão existencial dos poderes públicos, entre os parágrafos 53 a 59 da referida Carta, cabendo destacar o seguinte: “53. *Todos os cidadãos e todos os grupos intermediários devem contribuir para o bem comum [...]* 54. *Essa realização do bem comum constitui a própria razão de ser dos poderes públicos, os quais devem promovê-lo de tal modo que, ao mesmo tempo, respeitem os seus elementos essenciais e adaptem as suas exigências às atuais condições históricas [...]* Pois visto ter o bem comum relação essencial com a natureza humana, não poderá ser concebido na sua integridade, a não ser que, além de considerações sobre a sua natureza íntima e sua realização histórica, sempre se tenha em conta a pessoa humana. 56. *Acréscce que por sua mesma natureza, todos os membros da sociedade devem participar deste bem comum, embora em grau diverso, segundo as funções que cada cidadão desempenha, seus méritos e condições. Devem, pois, os poderes públicos promover o bem comum em vantagem de todos, sem preferência de pessoas ou grupos [...]* Acontece, no entanto, que, por razões de justiça e equidade, devam os poderes públicos ter especial consideração para com membros mais fracos da comunidade, pois se encontram em posição de inferioridade para reivindicar os próprios direitos e prover a seus legítimos interesses [...] 58. *Concordam estes princípios com a definição que propusemos na nossa encíclica Mater et Magistra: O bem comum ‘consiste no conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana’*”. JOÃO XXIII, **Carta Encíclica Pacem in Terris**... Acesso em: 26 out. 2013.

abstencionista e negativa comum ao Estado liberal-individualista converte-se em uma dinâmica estatal prestacionista e positiva altamente complexa, agigantada e dispendiosa, robustecida pelo colossal incremento operativo dos agora reconhecidos direitos fundamentais da pessoa humana.

Esta profunda ampliação das obrigações estatais trouxe consigo, como produto consequente, uma considerável relação de agigantamento (o que se passou a entender por proeminência) da esfera pública sobre os interesses privados, quase no sentido de completa sublimação dos interesses da coletividade sobre o indivíduo. É verdade que esta relação de superioridade (supremacia) acabou catalisada muito mais na relação Estado/particular do que no binômio coletividade/indivíduo. O Estado assume o posto (quase divino e totêmico) de onipotente “tutor” da sociedade e onisciente “guardião” do interesse público, nele se imiscuindo e com ele se confundindo com base em razões e justificativas populistas de ocasião¹⁰⁰, no mais das vezes vazias de sentido democrático, mas prenhas de fortes ventos autoritários e ditatoriais como os que varreram boa parte da Europa e da América Latina no século passado.

2.2.4 Estado constitucional de direito e interesse público: breves aproximações

Para suplantar a ordem de instabilidade política e social, a partir do Segundo Pós-Guerra, a Europa experimentou uma nova onda de reconstrução político-jurídica, com a radical afirmação da democracia e dos direitos humanos, no que se convencionou designar de Estado democrático de direito, aqui chamado de Estado constitucional de direito¹⁰¹. Esta

¹⁰⁰ Nesse mesmo sentido, Floriano de Azevedo MARQUES NETO denuncia que no “bojo desse processo de complexização ditado pela ampliação das funções do Estado, o aparato burocrático deixa de ser um mero instrumento de atuação do poder político dotado de uma racionalidade supostamente vinculada ao Direito. Transforma-se num corpo autônomo, dotado muita vez de interesses próprios, escudado na unilateralidade e na excepcionalidade dos poderes inerentes à autoridade estatal. Deixa de ser agente do poder político para erigir-se como filtro político para exercício do poder. E o faz, muita vez, privilegiando seus interesses enquanto corpo social autônomo, ou mesmo refletindo interesses particularísticos desprovidos de legitimidade”. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. **Regulação estatal e interesses públicos**. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 95.

¹⁰¹ Sobre a questão dos diferentes modelos de Estado, Luís Roberto BARROSO oferece uma síntese de rara simplicidade e (a um só tempo) sofisticação, que merece registro: “Ao longo do século XX, o Estado percorreu uma trajetória pendular. Começou liberal, com funções mínimas, em uma era de afirmação dos direitos políticos e individuais. Tornou-se social após o primeiro quarto, assumindo encargos na superação das desigualdades e na promoção dos direitos sociais. Na virada do século, estava neoliberal

onda de reconstitucionalização democrática também alcançou, ainda que de forma um tanto tardia (finais do século XX), grande parte da América Latina, a exemplo da ordem constitucional brasileira de 1988, aqui indicada como clara expressão de um autêntico “constitucionalismo de terceira dimensão”. Um modelo de Estado social e democrático de direito, fundado na limitação constitucional dos poderes constituídos, na soberania popular (autogoverno do povo), na cooperação de pessoas livres e iguais, bem como no respeito e na satisfação otimizada dos direitos e garantias fundamentais (individuais, coletivos e sociais)¹⁰².

A supremacia da Constituição e o caráter vinculante dos direitos fundamentais são dois traços característicos e fundantes do Estado constitucional de direito, um modelo de Estado de direito pautado pela força normativa dos princípios constitucionais¹⁰³ e pela pretensão de consolidação do paradigma da justiça substancial. Sobre esse novo modelo de Estado de direito, Bonavides ensina que, a partir da queda do positivismo e com o advento da teoria material da Constituição, “o centro de gravidade dos estudos constitucionais, que dantes ficava na parte organizacional da *Lei Magna* – separação de poderes e distribuição de competências, enquanto forma jurídica de neutralidade aparente, típica do constitucionalismo do Estado Liberal – se transportou para a parte substantiva, de fundo e conteúdo”, que passou a considerar “os direitos fundamentais e as garantias processuais da liberdade, sob a égide do Estado social”¹⁰⁴.

*ral, concentrando-se na atividade de regulação, abdicando da intervenção econômica direta, em um movimento de desjuridicização de determinadas conquistas sociais. E assim chegou ao novo século e ao novo milênio. O Estado contemporâneo tem seu perfil redefinido pela formação de blocos políticos e econômicos, pela perda de densidade do conceito de soberania, pelo aparente esvaziamento do seu poder diante da globalização”. BARROSO, Luís Roberto. Prefácio: o Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a redefinição da supremacia do interesse público. In: SARMENTO, Daniel (Org.). **Interesses públicos versus interesses privados**: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. ix.*

¹⁰² Neste sentido, consultar: BARROSO, Luís Roberto. O constitucionalismo democrático no Brasil: crônica de um sucesso imprevisto. **A Leitura**: Caderno da Escola Superior da Magistratura do Estado do Pará. Belém, v. 6, n. 10, p. 38-59, maio 2013, p. 39.

¹⁰³ O estudo sobre a teoria dos princípios constitucionais será objeto do subitem 3.3.3.1 do capítulo terceiro. Para análises complementares, consultar: ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios**: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004; BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000; CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. **Colisões entre princípios constitucionais**: razoabilidade, proporcionalidade e argumentação jurídica. 1. ed., 4. tir. Curitiba: Juruá, 2011; ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. **Conceito de princípios constitucionais**: elementos teóricos para uma formulação dogmática constitucionalmente adequada. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.

¹⁰⁴ BONAVIDES, **Curso de Direito Constitucional**..., p. 584.

O Estado constitucional de direito vem marcado pela relação intestina e indissociável entre o Estado democrático de direito e o Estado social (direitos sociais), com o deslocamento da centralidade das preocupações sociopolíticas e normativas para a pessoa humana, para o seu desenvolvimento cultural, político e social, a partir de um modelo substantivo de justiça social. Nas palavras de Jorge Reis Novais: o “Estado social e democrático de Direito apresenta-se, assim, impregnado de uma intenção material que se revela fundamentalmente na natureza dos valores que prossegue e na dimensão social da sua actividade, mas não menos no carácter meta-positivo dos vínculos que o limitam”¹⁰⁵.

Abre-se aqui um parêntese para trazer a interessante análise de Sérgio Cademartori acerca do Estado de direito, a partir de uma perspectiva diacrônica, quando divide a progressiva consolidação deste modelo de Estado em “governo *per leges*”, “governo *sub lege*” e “Estado constitucional de direito”. O aparato de dominação *per leges* constitui-se num poder que se expressa por meio de leis gerais e abstratas, decorrentes da vontade geral. Os atributos de generalidade e abstração da norma jurídica garantem a igualdade formal e afastam o arbítrio da ação governamental, uma vez que vinculam os poderes às formalidades e procedimentos dispostos em lei. No “governo *sub lege*” ocorre a vinculação e submissão dos poderes ao Direito, condicionando, além das formalidades e procedimentos da ação governamental, o conteúdo de tal ação, vinculando o governo a determinadas matérias¹⁰⁶.

Por sua vez, o Estado constitucional marca o caráter plenamente normativo e vinculante das Constituições, implicando a superação da redução positivista do Direito à lei e do jurídico ao legislativo. Deste modo, os direitos fundamentais passam a se constituir em matérias sobre as quais os poderes do Estado não podem dispor, uma vez que se constituem no fundamento de legitimidade do próprio Estado e expressão inarredável das democracias modernas. A garantia dos direitos fundamentais de liberdade e a concretização dos direitos fundamentais positivos é o dever primeiro do Estado, condição de legitimidade dos poderes constituídos¹⁰⁷.

Retomando a temática, convém ressaltar que o conceito de interesse público comum àquele modelo jurídico de cunho marcadamente

¹⁰⁵ NOVAIS, Jorge Reis. **Contributo para uma teoria do Estado de direito**: do Estado de direito liberal ao Estado social e democrático de direito. Coimbra: Almedina, 1987. p. 226.

¹⁰⁶ CADEMARTORI, Sérgio. **Estado de direito e legitimidade**: uma abordagem garantista. 2. ed. Campinas: Millennium, 2007. p. 06-20.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 20-26.

liberal e individualista, no mais das vezes indiferente às pressões das massas populares e às lutas pelo direito a ter direitos (substanciais), deve ser suplantado por um conceito de interesse público adequado ao atual modelo de “*Estado de direito inclusivo*”, que assume obrigações perante os cidadãos e procura dialogar com os anseios dos mais diferentes conjuntos de atores sociais.

Também já não parece sustentável aquela noção totalizante e estatalizada de interesse público, comum aos modelos de Estado social de direito, por vezes contrapostos e quase inimigos políticos de uma sólida ordem de direitos individuais. Em uma verdadeira ordem social e democrática, fundada no princípio da dignidade humana e na defesa e promoção dos direitos fundamentais, a relação conjugada de interesses individuais e coletivos é a tônica recorrente, devendo o conceito de interesse público estar afinado com essa dinâmica, instável e contraditória estrutura política, social e normativa.

A noção de interesse público adequada a este modelo de Estado constitucional de direito não pode ser outra que não aquela nascida, afirmada e limitada pela ordem constitucional vigente, fonte de legitimação e justificação de todas as instituições democráticas e dos poderes constituídos. E a convivência (mais ou menos conflituosa) entre interesses públicos e interesses privados deve submeter-se de forma indelével à batuta harmonizadora das normas constitucionais, regentes máximas da estrutura social e do Estado. O tempo atual é o da Constituição, à qual devem formal e substancial submissão tanto o Estado como os cidadãos e os demais atores sociais em geral.

Passada a breve recuperação do conceito de interesse público a partir dos diferentes modelos de Estado, oportuno o estudo do surgimento e dos contornos originais do Direito Administrativo, no contexto do então nascente Estado moderno, o qual servirá de substrato ao estabelecimento de um conceito de interesse público consentâneo ao atual Estado constitucional de direito.

2.3 O NASCIMENTO DO DIREITO ADMINISTRATIVO NO ESTADO MODERNO: SOBRE O PECADO AUTORITÁRIO ORIGINAL

O surgimento de uma disciplina autônoma relacionada ao funcionamento da atividade administrativa do poder estatal é tradicionalmen-

te atribuído ao movimento revolucionário francês de finais do século XVIII¹⁰⁸. O Direito Administrativo teria nascido do ventre humanista e libertário da Revolução Francesa de 1789¹⁰⁹, como instrumento emancipatório de superação do sistema de poder concentrado e absolutista do Antigo Regime (*Ancien Régime*), fundado na vontade do soberano¹¹⁰.

2.3.1 Sobre a “história oficial” do nascimento do Direito Administrativo

A história clássica do Direito Administrativo atesta o seu “nascimento oficial” com o advento da Lei de 28 do pluvioso do Ano VIII, de 1800 (*Loi du 28 pluviôse an VIII*), uma legislação que trazia os preceitos sobre a organização administrativa e regulava os litígios contra a Administração Pública. Esta submissão da organização da burocracia estatal e da definição das funções públicas à vontade da lei representaria a limitação do poder estatal, simbolizando a inequívoca derrocada do autoritarismo monárquico e a construção das bases do Estado de direito¹¹¹.

¹⁰⁸ Importa assinalar que Marques Neto desenvolve uma análise assaz interessante, quando identifica, já no Estado de polícia do Antigo Regime (Monarquia Absolutista), as bases do nascente ramo do Direito Administrativo, a partir da ideia de concentração de poder e da autoridade do Soberano, emergentes da afirmação do Absolutismo e da edificação do Estado moderno. Convém, por oportuno, esclarecer que o autor não sustenta a tese de que já no Estado de polícia seria possível encontrar um Direito Administrativo enquanto ramo científico e regime jurídico autônomo, o que somente ocorreria com o advento do Estado de direito. Por outro lado, aquela ideia tradicional de “ruptura total a partir do nada” não parece ser a melhor explicação para o nascimento desse regime jurídico-administrativo autônomo, pois várias noções (e mesmo práticas) do Antigo Regime foram acolhidas por esse Direito Administrativo em formação, ainda que sob outro contexto social e político. Nesse sentido: MARQUES NETO, *Regulação estatal...*, p. 57-67.

¹⁰⁹ Para uma análise da Revolução Francesa sob a rica ótica da construção histórica dos direitos humanos, dentre outros, pode-se consultar: BOBBIO, *A era dos direitos...*, p. 40-60; COMPARATO, Fábio Konder. *A afirmação histórica dos direitos humanos*. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

¹¹⁰ Para estudos sobre a sociedade francesa do tempo do Antigo Regime (monarquia) e as causas que levaram à Revolução Francesa, pode-se consultar: TOCQUEVILLE, Alexis de. *O Antigo Regime e a revolução*. Tradução de Rosemary Costhek Abílio. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

¹¹¹ Partindo da recuperação histórica oferecida pelo administrativista francês Charles Debbsch, Odete Medauar faz referência à Lei de 28 do pluvioso do Ano VIII, de 1800, assegurando que, “no tocante à organização, dois princípios a nortearam: hierarquização e centralização; conforme o primeiro, fixou-se de modo claro, pela primeira vez, a separação entre o representante que exerce funções no âmbito político e o funcionário, que atua no setor administrativo, totalmente subordinado àquele; o

O nascimento do Direito Administrativo e do próprio Estado de direito estariam visceralmente vinculados ao sistema de separação de poderes, tributário das ideias de garantia das liberdades individuais e de restrição à invasão injustificada do Estado na esfera de direitos dos cidadãos. As arbitrariedades e os abusos do Estado Absolutista, fundado na figura centralizadora do rei legislador, administrador e julgador, restariam substituídos por um sistema de limitações e contenções internas e externas do poder político.

Importa recordar que, conquanto a separação de poderes não tenha sido propriamente aplicada na história sociopolítica da Antiguidade clássica, o plano filosófico registra que desde aquela época havia a preocupação em identificar e dividir as funções político-governamentais¹¹². Mas foi somente a partir do pensamento do Barão de Montesquieu (1689 – 1755 d.C.)¹¹³ que restou estruturada a doutrina política da sepa-

poder de nomeação e exoneração cabe à autoridade superior, sobretudo ao Primeiro Cônsul (Napoleão), por força da Constituição do ano VIII; conforme o segundo princípio, a organização territorial se uniformizou e simplificou, prevendo-se, ainda em nível local, agentes representantes de poder central, os prefet, também subordinados integralmente a este. Quanto aos litígios, referida lei atribuiu ao Conselho de Estado funções de órgão consultivo, juiz de contestações em matéria administrativa e instância de apelação das decisões tomadas pelos conselhos de prefeitura no âmbito de sua competência para dirimir litígios; evidente que o Conselho de Estado preparava as decisões finais tomadas pelo Primeiro Cônsul, pois nesse período vigorava o sistema de justiça retida". MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. p. 10-11.

¹¹² Com a intenção de dividir as atribuições do governo soberano, Aristóteles falava em função consultiva, função judiciária e função relacionada aos assuntos da Administração. No entendimento do filósofo grego, a função consultiva estaria relacionada ao pronunciamento do governo soberano sobre a guerra e a paz e sobre as leis; a função judiciária solucionaria as controvérsias surgidas da aplicação das leis; a outra função, que deveria ser exercida por um magistrado, referia-se aos assuntos da administração, por exclusão, compreendendo tudo aquilo que não fosse atribuição das funções anteriores. ARISTÓTELES, *A Política*..., p. 147-158. O termo "magistrado" não deve aqui ser comparado ao atual juiz togado (membro do Poder Judiciário), porquanto, na Antiguidade clássica grega, a função da magistratura estaria sobremaneira ligada à contemporânea noção estatal de Administração Pública. Para estudos complementares, ver: RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. *Tripartição de Poderes na Constituição de 1988*. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo, ano 3, v. 11, p. 16-28, abr./jun. 1995, p. 16.

¹¹³ Os escritos de Montesquieu registram que, na história política da civilização romana, a temática da separação de poderes pode ser dividida entre o período do Governo dos Reis e, após sua expulsão, o estado florescente da República Romana. Nos primeiros reinados, os soberanos comandavam os exércitos, julgavam os assuntos civis e criminais e convocavam o Senado. O Senado, por sua vez, possuía grande autoridade e o povo tinha o direito de eleger os magistrados, de aprovar novas leis e, com a permis-

ração de poderes em seus contornos modernos, a qual serviu de fundamento e princípio regente às Constituições democráticas contemporâneas. Sob um discurso acerca da liberdade (o direito dos cidadãos em fazer tudo o que as leis permitem), o filósofo conclui tratar-se "*de uma experiência eterna que todo homem que possui poder é levado a dele abusar; ele vai até onde encontra limites [...] Para que não se possa abusar do poder, é preciso que pela disposição das coisas, o poder limite o poder*"¹¹⁴.

Pelo nascente sistema de contenção do poder, a atividade estatal restaria limitada pela vontade legislativa proveniente do Parlamento, expressão máxima do poder soberano do povo. Mas a execução da atividade administrativa deveria estar sujeita a uma disciplina jurídica especial, derogatória do Direito Comum (Direito Civil).

Os contornos do nascente Direito Administrativo, aparelhado por institutos e instrumentais (poderes e prerrogativas) dotados de originalidade e autonomia, são justificados por Jean Rivero tanto de um ponto

são do rei, declarar a guerra e fazer a paz. Com a expulsão dos reis, a distribuição dos três poderes começou a mudar, havendo uma maior participação dos plebeus nas decisões públicas. Na República Romana, pode-se notar a distinção das três funções típicas governamentais, a legislativa atribuída ao corpo do povo (Cônsules e Censores), a executiva que o povo deixou, quase por inteiro, ao Senado e aos Cônsules, e a jurisdicional que foi distribuída entre o povo, o Senado, os magistrados e certos juizes, conforme a matéria a ser decidida. MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, Barão de. *O espírito das leis*. Tradução Cristina Maracho. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 182-194.

¹¹⁴ Para Montesquieu, a liberdade do cidadão está na segurança de não ser julgado pela mesma pessoa que criou a lei, ou que o criador da lei não seja seu executor. Quando se confundem na mesma pessoa o criador da lei e o seu executor, pode-se "*temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente*". A liberdade dos cidadãos também fica comprometida quando o poder de julgar não fica separado do poder de legislar ou de executar as leis. "*Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as querelas entre os particulares*". Montesquieu não defende uma divisão estanque de funções, mas um sistema de colaboração entre as três esferas funcionais, cada uma desempenhando suas atribuições precípuas. O Poder Executivo deve ser exercido pelo monarca, enquanto que o Poder Legislativo deve ser dividido em duas casas, o corpo dos nobres e os representantes do povo. O poder de julgar não deve ser atribuído a um senado permanente, mas exercido por pessoas extraídas do corpo do povo, formando um tribunal que dure apenas o tempo necessário. Sendo assim, os juizes seriam da mesma condição do acusado (seus pares), não ficando o poder de julgar, tão terrível entre os homens, ligado nem a certo grupo social nem a determinada profissão, tornando-se, por conseguinte, invisível e nulo. MONTESQUIEU, *O espírito das leis*..., p. 166-168.

de vista lógico como por um prisma histórico. Primeiramente, o administrativista francês sustenta que não se poderia admitir nas relações jurídico-administrativas a aplicação do postulado da igualdade jurídica dos particulares, comum ao Direito Civil, uma vez que “*a Administração, guardiã do interesse público, deve poder assegurar a sua salvaguarda a despeito da resistência das vontades privadas*”¹¹⁵. Do ponto de vista histórico, o autor relembra que os revolucionários franceses, dominados pela lembrança do combate secular entre o Parlamento e a Administração Real, subtraíram a atividade administrativa e os litígios relacionados à Administração do controle do Poder Judiciário, confiando-os a uma jurisdição especial, visceralmente ligada ao Poder Executivo e encabeçada pelo Conselho de Estado (*Conseil d'État*). Por certo, esse sistema de jurisdição administrativa “*desempenhou um papel decisivo na elaboração de um direito administrativo autônomo*”¹¹⁶.

A centralidade do sistema de jurisdição administrativa é também referida por Diogo Freitas do Amaral, quando salienta o fato de que, no período pós-Revolução Francesa, a separação entre a Administração e a Justiça, retirando-se desta toda e qualquer ingerência ou poder decisório sobre os interesses e litígios que envolvessem a função administrativa e a Administração Pública, “*resultou da desconfiança do poder revolucionário face aos tribunais judiciais, que representavam ainda a continuação do 'Antigo Regime', pois estavam nas mãos da nobreza*”¹¹⁷. Cientes desta conjuntura, os revolucionários acabaram por esvaziar dos órgãos judiciais todas as competências decisórias sobre litígios em matéria administrativa, concebendo o princípio da separação de poderes “*como uma máquina de guerra dirigida contra os tribunais judiciais*”¹¹⁸.

¹¹⁵ RIVERO, *Direito Administrativo...*, p. 23.

¹¹⁶ *Ibidem*, p. 24.

¹¹⁷ AMARAL, Diogo Freitas do. *Curso de Direito Administrativo*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2012.v. II, p. 18.

¹¹⁸ O administrativista lusitano ilustra, inclusive, que a relação de divisão entre a Justiça e a Administração, com o estabelecimento da completa autonomia funcional entre os juízes, de um lado, e os agentes da Administração, do outro, já vinha regulada pela Lei de 16-24 de agosto de 1790, quando prescrevia que os “*juízes não poderão, sob pena de alta traição, perturbar de qualquer maneira as operações dos corpos administrativos, nem convocar perante si os agentes da administração por motivo atinente às funções destes*”. Na mesma senda, a Lei de 7-14 de outubro de 1790, pela qual “*as reclamações de incompetência relativamente a corpos administrativos não são do conhecimento dos tribunais, devendo ser levadas ao monarca, chefe da administração geral*”. Também, o art. 3º da Constituição de 3 de setembro de 1791, que afirmava “*não poderem os tribunais conhecer das funções administrativas ou citar perante eles administradores em razão das suas funções*”. *Ibidem*, p. 17-18.

2.3.2 Sobre a “outra história” do nascimento do Direito Administrativo e seus reflexos

A noção libertária e emancipatória do nascente Direito Administrativo pós-Revolução Francesa, alicerçado sobre as bases de um sistema de contencioso administrativo livre das “*ingerências reacionárias*” da Justiça francesa, sofre duras e consistentes críticas de Vasco Pereira da Silva, para quem o sistema de jurisdição administrativa representa sim, uma das “*experiências traumáticas*” da “*infância difícil*” do Direito Administrativo. O administrativista português é categórico ao denunciar o viés marcadamente autoritário do “*Contencioso Administrativo, na Revolução francesa, concebido com 'privilégio de foro' da Administração, destinado a garantir a defesa dos poderes públicos e não a assegurar a protecção dos direitos dos particulares*”¹¹⁹.

Em uma metáfora psicanalista, a primeira fase de criação do sistema de jurisdição administrativa é referida por Silva como a “*fase do pecado original do Contencioso Administrativo*”, nascido da promiscuidade entre as tarefas de administrar e de julgar, no que se convencionou chamar de “*sistema do administrador-juiz*”. Os revolucionários franceses acabaram por aplicar uma interpretação claramente distorcida e heterodoxa do modelo liberal de separação de poderes, a fim de justificar (legitimar) a autonomia da jurisdição administrativa e a proibição de qualquer interferência (ingerência) dos juízes sobre as coisas da Administração Pública: “*em vez de se reconhecer que 'julgar a Administração é ainda julgar', preferia-se considerar que 'julgar a Administração é ainda administrar' e que a 'jurisdição era o complemento da acção administrativa*”¹²⁰.

Com efeito, essa instituição de um sistema de jurisdição administrativa pretensamente garantista e limitador do poder estatal, ancorado no dogma liberal da separação de poderes, instaurou-se no seio de uma inegável “*confusão*” entre as funções administrativa e judicial, para todas aquelas matérias de interesse da Administração. A construção do modelo de “*juiz doméstico*” acabou por ficar gravada na certidão de nascimento do Direito Administrativo, o que Gustavo Binbenbojm chama de “*pecado autoritário original*”¹²¹.

¹¹⁹ SILVA, Vasco Pereira da. *O contencioso administrativo no divã da psicanálise: ensaio sobre as acções no novo processo administrativo*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2009. p. 10.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 14.

¹²¹ BINBENBOJM, *Uma teoria do Direito Administrativo...*, p. 11.

Mas em que medida o originário sistema de contencioso administrativo francês pode ser taxado de autoritário? É que as bases da nascente disciplina jurídico-administrativa, seus princípios gerais, institutos, prerrogativas e poderes instrumentais, não decorreram da vontade heterônoma do Parlamento (vontade da lei), sendo sim, forjados a partir da “jurisprudência” e do “ativismo normativo autovinculativo” do Conselho de Estado francês, derogatórios do sistema normativo comum (Direito Civil).

A construção de um direito especial da Administração Pública não decorreu da vontade geral manifestada pelo Legislativo, mas da auto-determinação do próprio Executivo, pela via do Conselho de Estado, que funcionava como o próprio legislador na produção do ordenamento jurídico-administrativo, a ser por ele mesmo aplicado. Isso representa uma inequívoca contradição em face do sistema de separação de poderes justificador da própria jurisdição administrativa.

Para reforçar a tese do “pecado autoritário original”, convém lembrar que o Executivo francês pós-revolução detinha uma prerrogativa muito especial e até inusitada (se considerada do ponto de vista do dogma liberal da separação de poderes), a de substituir e suplantar o Legislativo na criação do Direito Administrativo, uma legalidade potencialmente derogatória do Direito Civil. Seria, portanto, inverídica a mítica e romantizada ideia da gênese garantista do Direito Administrativo da Europa continental, pela qual o Executivo subjuguador do Antigo Regime restaria subordinado ao Parlamento, pela via do princípio da legalidade?

Como esclarece Paulo Otero, “o sistema contencioso do administrador-juiz confiava ao executivo a última palavra decisória sobre a competência do *Conseil d’État*”, o que admite considerar não só que “julgar a Administração ainda é administrar”, mas também que “legislar para a Administração já é administrar”¹²².

Oportuna é a advertência do administrativista lusitano acerca do que designou como a “ilusão garantística da gênese do Direito Administrativo”, para quem a invocação do princípio da separação de poderes não passou de pretexto assecuratório do “objectivo político concreto de garantir um efectivo alargamento da esfera de liberdade decisória da Administração Pública, tornando a sua actividade imune a qualquer controlo”¹²³.

Na verdade, esse nascente direito especial da Administração Pública, que marcou a Europa continental a partir da França revolucioná-

¹²² OTERO, Paulo. *Legalidade e Administração Pública*: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra: Almedina, 2007. p. 271.

¹²³ *Ibidem*, p. 275.

ria, tem sua gênese claramente assinalada por um direito de prerrogativas e privilégios especiais da Administração (direito da Administração), derogatório dos postulados de igualdade informadores do Direito Civil, e não como um direito de garantia dos cidadãos (direito dos administrados). Neste contexto, ressoa inequívoca a superação originária das propaladas “lógicas da liberdade/igualdade” pela “lógica da autoridade”¹²⁴.

Inegavelmente, a ampla e autovinculativa concentração do poder político e jurídico no sistema de contencioso administrativo decorreu da indelével desconfiança dos revolucionários franceses contra os tribunais judiciais. Segundo uma análise mais radical, há quem admita e sustente até “uma perfeita continuidade entre o modelo de controlo administrativo adoptado pela Revolução Francesa e aquele que vigorava no *Ancien Régime*”¹²⁵, no sentido de que, ao melhor estilo de algumas situações de festejada ruptura e revolução, tudo muda para que tudo continue como antes.

Por certo, a notória “fuga” do Executivo ao controle dos tribunais trouxe consigo acentuados “efeitos limitativos das garantias contenciosas dos administrados” no âmbito da jurisdição administrativa, o que refletiu na consagração de muitas “regras de privilégio a favor dos órgãos administrativos, havendo aqui uma nítida posição dominante da autoridade administrativa, além de assinaláveis contradições estruturais”¹²⁶.

Inclusive, fazendo referência ao famoso “caso Blanco” (*arrêt Blanco*)¹²⁷, julgado pelo Tribunal de Conflitos francês em 1873, donde se

¹²⁴ Importante ressaltar que essa “origem autoritária” do Direito Administrativo francês, que influenciou em larga medida grande parte da Europa continental, fundada na derrogação da dogmática de igualdade do Direito Comum, a partir da construção de um “direito especial” da Administração, não foi seguida pela tradição do Direito Público anglo-saxão. O Estado de direito inglês (*rule of law*) baseava-se na máxima de que os indivíduos e o Poder Público deveriam estar submetidos às mesmas leis e aos mesmos juízes, desaconselhados quaisquer tratamentos privilegiados ao Poder Público. Eis, inclusive, uma justificativa histórica para a relutância dos países vinculados ao sistema da *common law* em “reconhecer a autonomia didático-científica ao direito administrativo e o repúdio à adoção da jurisdição administrativa”. Nesse sentido, consultar: BINENBOJM, *Uma teoria do Direito Administrativo...*, p. 15-16.

¹²⁵ OTERO, *Legalidade e Administração Pública...*, p. 275.

¹²⁶ *Ibidem*, p. 277.

¹²⁷ O “caso Blanco” refere-se ao trágico infortúnio que acometeu uma criança de cinco anos (Agnès Blanco), atropelada pelo vagão de um trem (serviço público). Os pais da menina tiveram negada a indenização tanto pelo Tribunal de Bordéus como pelo Conselho de Estado, porquanto ambos se declararam incompetentes para decidir o pleito, ante a relação com a Administração Pública, o que afastava a incidência das regras de Direito Civil, situação dirimida pelo Tribunal de Conflitos para reconhecer a compe-

retira a afirmação histórica da autonomia do regime jurídico-administrativo, Silva recorre novamente à metáfora psicanalista para qualificá-lo como o “segundo acontecimento traumático” daquela “infância difícil” do Direito Administrativo, refletindo a inexorável existência de uma maior preocupação com a garantia da Administração do que com a proteção dos particulares.

A decisão do Tribunal de Conflitos francês pela competência da jurisdição administrativa para julgar o caso, mas sob um regime de “direito especial” da Administração, assegurada a sua condição de privilégio, demonstra de forma inequívoca que a gênese da propalada autonomia do Direito Administrativo decorreu da (nada garantista e emancipatória) preocupação em justificar a limitação da responsabilidade da Administração, ante o atropelamento de uma criança de cinco anos pelo vagão de um trem (serviço público). Longe de representar uma vitória libertária, a defesa da autonomia do regime administrativo serviu, na sua origem, para justificar e impor a limitação das responsabilidades do Executivo frente aos cidadãos e para derogar as regras do Direito Comum, fundadas no princípio da igualdade entre as partes, fazendo preponderar o sistema jurídico de privilégios da Administração¹²⁸.

Por outro lado, apesar de pouco difundido e até não reconhecido por expressiva parcela da doutrina administrativista, é certo que esse relevante fator histórico do “pecado original” da gênese autoritária do “direito da Administração” na Europa continental, não o impediu de experimentar uma lenta e gradual abertura e reconstrução emancipatória, enquanto disciplina jurídico-administrativa, até constituir-se verdadeiramente na atual disciplina do Direito Administrativo. Superada aquela conturbada e contraditória gênese autoritária, já agora em boa medida desvencilhada da sua vocação genética de direito da Administração, a disciplina jurídico-administrativa passou a reverberar contornos claramente progressistas de consolidação enquanto sistema de limitações do poder estatal.

Sem embargo, não se pode olvidar que todas essas contestações àquela clássica mentalidade da origem libertária e emancipatória do Direito Administrativo, para não dizer quase mítica e milagrosa, também não estão isentas de críticas. Emerson Gabardo é direto ao desqualificar essa nova genealogia histórica do Direito Administrativo, definindo-a

tência da jurisdição administrativa, mas não para julgar o caso sob as regras do Direito Comum e sim, a partir de “um ‘direito especial’ para a Administração, que tomasse em consideração o seu ‘estatuto de privilégio’”. SILVA, **O contencioso administrativo...**, p. 11.

¹²⁸ *Ibidem*, p. 55.

como um modismo de “precária capacidade explicativa”, que pretende “reduzir a força legitimatória de princípios como o do interesse público, ou mais especificadamente, da ‘supremacia do interesse público’”¹²⁹, revelando-se como uma “interpretação da história cujo fim é conferir às proposições do presente um sentido mais facilmente apreensível e consonante com a mentalidade vigente, que é a de maior liberalização e flexibilização da vida”¹³⁰.

Após uma análise do Direito Administrativo brasileiro, Gabardo considera todas essas críticas à “gênese autoritária” do regime jurídico-administrativo como “algo complicado e temerário, quando não totalmente inútil”¹³¹, já que a cultura jurídico-administrativista, como de resto a cultura jurídica brasileira em geral, sofreu larga influência de diversas e contraditórias doutrinas estrangeiras, aqui “miscigenadas” nesse conhecido “caldeirão jurídico tupiniquim”, no mais das vezes pouco apegado ao rigor histórico, político e jurídico das suas fontes, mas que possibilitou “um tão bem feito amálgama entre a tradição anglo-americana, a francesa, a alemã e a italiana em termos de Direito público”¹³². Isso autorizaria considerar que as possíveis raízes autoritárias da aplicação do Direito no Brasil, não só do Direito Administrativo, além do recorrente “uso e abuso do interesse público como fundamento retórico de legitimação do poder, não estão na França, mas na sua própria história personalista e carente de um real espírito republicano, que aos tropeços e solavancos redundou na efetiva construção de um espaço público (mas nem tanto...)”¹³³.

De fato, se é, ou não, duvidosa a maior ou menor influência ou até a concreta extensão dos efeitos da referida “gênese autoritária”, esse debate mostra-se rico e fecundamente revelador, cabendo reconhecer que várias das categorias básicas do Direito Administrativo, “como a discricionariedade e sua insindicabilidade perante os órgãos contenciosos, a supremacia do interesse público e as prerrogativas jurídicas da Administração, são tributárias deste pecado original”¹³⁴. Isso permite supor como verossímil a afirmação de que, “na melhor tradição absolutista, além de propriamente administrar, os donos do poder criam o direito que lhes é

¹²⁹ GABARDO, Emerson. **O jardim e a praça para além do bem e do mal: uma antítese ao critério de subsidiariedade como determinante dos fins do Estado social**. 2009. 396 f. Tese (Doutorado em Direito) – Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009. p. 237.

¹³⁰ GABARDO; HACHEM, **O suposto caráter autoritário...**, p. 157.

¹³¹ GABARDO, **O jardim e a praça...**, p. 237.

¹³² *Ibidem*, p. 238.

¹³³ GABARDO; HACHEM, **O suposto caráter autoritário...**, p. 157.

¹³⁴ BINENBOJM, **Uma teoria do Direito Administrativo...**, p. 15.

*aplicável e o aplicam às situações litigiosas com caráter de definitividade*¹³⁵, perpetuando na atualidade a consagração e manutenção de “regras de privilégio” em favor da Administração, derogatórias da ideia de igualdade jurídica e cristalizadoras da posição dominante da autoridade administrativa¹³⁶.

Feitas essas considerações sobre a controvertida genética do Direito Administrativo, parece oportuna a análise do interesse público a partir da doutrina dos conceitos jurídicos indeterminados, teoria capaz de oferecer relevante contributo à adequada formulação do conceito de interesse público.

2.4 INTERESSE PÚBLICO: CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO, MAS DETERMINÁVEL?

Parece haver consenso na doutrina jurídico-administrativista nacional de que a expressão “interesse público” situa-se dentre aquelas comumente aceitas como exemplo de “conceito jurídico indeterminado”¹³⁷. Mas isso não deveria ser entendido como “um defeito do conceito, mas um atributo destinado a permitir sua aplicação mais adequada caso a caso. A indeterminação dos limites do conceito permite a aproximação do sistema normativo à riqueza do mundo real”¹³⁸. Por outro lado, é altamente relevante perquirir se e em que medida esta indeterminação pode, ou não, ser objetivamente suprimível e quais as correspondentes consequências jurídico-políticas da resposta negativa ou positiva. Em outras palavras, a noção de interesse público traduz-se em um conceito jurídico objetivamente indeterminável e, portanto, insuscetível de significação e conceituação abstrata?¹³⁹ Ou, embora de difícil conceituação, pode-se buscar suas zonas de certeza negativa e até positiva, na construção dos contornos de um conceito de interesse público (determinável)?¹⁴⁰

¹³⁵ *Ibidem*, p. 15.

¹³⁶ OTERO, *Legalidade e Administração Pública*..., p. 277.

¹³⁷ Nesse sentido, entre outros, pode-se consultar: CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 33.

¹³⁸ JUSTEN FILHO, *Conceito de interesse público*..., p. 116.

¹³⁹ Nesse sentido: ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. In: SARMENTO, Daniel (Org.). *Interesses públicos versus interesses privados*: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 211-212.

¹⁴⁰ Nesse sentido: RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. Interesse público: um conceito jurídico determinável. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Viní-

2.4.1 A doutrina clássica dos conceitos jurídicos indeterminados

Os “conceitos jurídicos indeterminados” são aqueles chamados “conceitos práticos”¹⁴¹, frutos de expressões vagas, fluidas, elásticas, que não comportam um único entendimento, variando de sentido tanto no aspecto temporal como no espacial. Expressões como “moralidade pública”, “notório saber”, “bons antecedentes”, “reputação ilibada”, “bem comum”, “tranquilidade pública”, “relevância e urgência”, “notória especialização” e diversas outras que povoam as normas jurídicas escritas e, por sua imprecisão conceitual, acabam por abarcar significações diversas e, em certos casos, até conflitantes¹⁴².

Importa destacar, a partir de um ponto de vista material, que o conceito pode ser considerado como o “núcleo irradiador de um significado”, o elemento identificador de algo, o significado do termo, do signo. Todo conceito tem uma compreensão (conotação), de onde se retira o conteúdo formal do termo, e uma extensão (denotação), pela qual se revela a propriedade que o termo tem de ser aplicável a vários objetos, uma

cius Alves (Coord.). *Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito Administrativo*. São Paulo: Atlas, 2010. p. 114-118.

¹⁴¹ Para o administrativista lusitano Afonso Rodrigues Queiró, os conceitos jurídicos podem ser divididos em “conceitos práticos”, aqueles que apresentam certa imprecisão, pluralidade de significados, indeterminação (relacionados ao mundo da cultura, dos valores culturais e morais) e, “conceitos teóricos”, que, por oposição, são aqueles conceitos jurídicos compostos de expressões precisas, unissignificativas, determinadas (realidades do mundo da natureza, mundo da causalidade). Segundo Queiró, a discricionariedade da Administração restaria circunscrita aos “conceitos de valor” utilizados na norma jurídica, ou seja, os “conceitos não teóricos”. Os conceitos teóricos seriam aqueles comuns às ciências empírico-matemáticas, de contornos absolutamente individualizáveis, com valor objetivo e universal. Por isso, no caso de a lei adotar conceitos teóricos não remanesceria discricionariedade à Administração. Poderia até restar margem a dúvidas, sanáveis mediante interpretação, segundo os processos de hermenêutica administrativa, mas nunca poder discricionário à atividade administrativa, ou seja, discricção na aplicação do conceito jurídico ao caso concreto. Nesse sentido, consultar: QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. A teoria do “desvio de poder” em Direito Administrativo. *Revista de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro, a. 7, p. 52-80, jan./mar. 1947.

¹⁴² Para uma abalizada análise da teoria dos conceitos jurídicos indeterminados sob a ótica do discurso racional (nova hermenêutica), consultar: CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart. Conceitos jurídicos indeterminados no âmbito da nova hermenêutica. In: VALLE, Juliano Keller do; MARCELLINO JR., Julio Cesar (Org.). *Reflexões da pós-modernidade*: Estado, Direito e Constituição. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008. p. 121-134.

pluralidade de significações¹⁴³. Neste contexto, Eros Roberto Grau esclarece que os conceitos jurídicos são termos de significação, expressões ou sinais que objetivam uma significação, que pode ser atribuída a uma coisa, a um estado de coisas ou a uma situação que tenha relação com o direito. Os conceitos jurídicos pretendem expressar o significado de uma coisa ou de uma situação, atuando como sinais de significação, meios pelos quais podem ser expressos determinados elementos. Os conceitos jurídicos, em última análise, são medidas significativas, o sentido explicativo de determinado termo jurídico¹⁴⁴.

A doutrina ensina que o debate acerca dos conceitos jurídicos indeterminados, seus parâmetros de colmatação e os âmbitos de discricionariedade na determinação e concretização de significados pela Administração remontaria aos finais do século XIX, por ocasião da controvérsia travada entre os juristas austríacos Edmund Bernatizik (1886) e Friedrich Tezner (1888). A partir de um complexo processo intelectual chamado de “discricionariedade técnica”, Bernatizik entendia como possível a aplicação/interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados, dos quais poderia decorrer uma pluralidade de decisões corretas, que não estariam sujeitas à revisão dos tribunais, porquanto provenientes dos órgãos administrativos que detinham o conhecimento necessário para preencher os sentidos daqueles conceitos vagos (teoria da multivalência). Contrariamente, embora reconhecesse certo grau de insegurança comum a todas as significações dos sinais linguísticos, Tezner defendia que da aplicação dos conceitos jurídicos indeterminados não decorreria discricionariedade administrativa, no sentido de liberalidade de escolha, uma vez que da interpretação de um conceito (vago ou preciso) somente poderia decorrer (objetivamente) uma única decisão correta (teoria da univocidade ou unicidade)¹⁴⁵.

¹⁴³ COSTA, Regina Helena. Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa. *Revista de Direito Público*. São Paulo, a. 23, n. 95, p. 125-138, jul./set. 1990, p. 126.

¹⁴⁴ Segundo Grau, os conceitos jurídicos “*nos seus atos de expressão, isto é, nos seus termos [...] são signos de signos, ou seja, signos de significações atribuíveis – ou não atribuíveis – a coisas, estados ou situações [...]. O objeto do conceito jurídico expressado, assim, é uma significação atribuível a uma coisa, estado ou situação*”. Os conceitos jurídicos, em si mesmos, não são atos de expressão, não albergam significação; a significação reside nos seus termos. “*Os termos são as expressões dos conceitos jurídicos, os sinais (signos) de significação das coisas, estados ou situações. Por conseguinte, os conceitos jurídicos expressados através de seus termos têm como objeto significações atribuíveis a uma coisa*”. GRAU, Eros Roberto. Nota sobre os conceitos jurídicos. *Revista de Direito Público*. São Paulo, a. 18, n. 74, p. 217-221, abr./jun. 1985, p. 218.

¹⁴⁵ Para estudos complementares, consultar: BUSATTO, Carlos Ernesto Maranhão. *Reflexões críticas acerca do papel e significado do interesse público no Direito*

Com efeito, a questão da relação entre conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa é problemática recorrente, relacionando-se diretamente a extensão e intensidade da sindicabilidade jurisdicional da atividade administrativa, quando fundada em comando normativo que ostente os referidos conceitos plurissignificativos. Certamente, se entendido que a aplicação de conceitos práticos decorre de mera interpretação jurídica, da qual resultará o alcance da única solução correta para o caso concreto, a partir de um processo objetivo infenso àquela margem de subjetividade comum aos juízos discricionários, o controle jurisdicional deverá ser amplo, espalhando-se inclusive sobre os aspectos de correção ou incorreção da subsunção do caso concreto ao conceito normativo abstrato (aplicação do conceito jurídico indeterminado)¹⁴⁶.

Nesse sentido, trilhando a senda do que a doutrina tedesca convencionou designar como a “*teoria dos ‘conceitos jurídicos indeterminados’*”¹⁴⁷, o entendimento de Eduardo Garcia de Enterría e Tomás-Ramón Fernández rechaça a indeterminação dos conceitos jurídicos como espaço de habitação à discricção na atividade administrativa. Com propriedade, os administrativistas espanhóis defendem que a moldura normativa definida como conceito indeterminado ou prático só possibilitaria uma escolha, a melhor à persecução da finalidade legal, pelo que a fluidez ou indeterminação dos conceitos jurídicos só existiria *in abstracto*, não subsistindo nos casos concretos, por ocasião de sua aplicação¹⁴⁸. Para Garcia de Enterría e Fernández, “*a indeterminação do enunciado não se traduz em uma indeterminação das aplicações do mesmo, as quais só permitem uma ‘unidade de solução justa’ em cada caso*”¹⁴⁹.

Administrativo brasileiro. 2011. 125 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Direito. Porto Alegre, 2011. p. 43; SILVA, Almiro do Couto e. Poder discricionário no Direito Administrativo brasileiro. *Revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre, a. 27, n. 57, p. 93-106, dez. 2003, p. 101; DEL CLARO, Maria Ângela Marques. O Direito Administrativo e a doutrina dos conceitos jurídicos indeterminados. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná*. Curitiba, n. 40, p. 163-176, 2004, p. 170.

¹⁴⁶ Nesse sentido, consultar: BUSATTO, *Reflexões críticas acerca do papel...*, p. 43.

¹⁴⁷ BINENBOJM, *Uma teoria do Direito Administrativo...*, p. 215.

¹⁴⁸ Na doutrina brasileira, com entendimento bastante aproximado, GRAU defende que da indeterminação do conceito jurídico não podem decorrer juízos discricionários, porquanto a referida vagueza ou fluidez do conceito jurídico deve conduzir a uma unidade de solução para cada caso concreto. Quando a Administração exerce atividade discricionária, o faz a partir de juízos de oportunidade, ao passo que na aplicação de conceitos indeterminados exerce juízos vinculados à legalidade. GRAU, Eros Roberto. *O direito posto e o direito pressuposto*. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 146.

¹⁴⁹ GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. *Curso de Direito Administrativo*. Tradução de Amaldo Setti. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 393.

Convém reconhecer, por outro lado, a existência de várias situações em que a atuação administrativa fundada na promoção ou aplicação de determinados conceitos jurídicos imprecisos comporta expressiva liberdade de atuação à Administração Pública, na ponderação acerca dos parâmetros, limites e contornos para o cumprimento do desiderato normativamente imposto, o que inclusive ocorre, v.g., em várias situações relacionadas à chamada consecução e concretização do interesse público pela Administração.

Há situações em que a própria conformação legislativa ou as circunstâncias do caso concreto transferem ao agente público a atribuição de definir as medidas administrativas mais adequadas ao caso concreto. Isso, porém, não equivale a dizer que estas escolhas administrativas restariam aninhadas no seio de quaisquer arbitrariedades ou afastadas do controle jurisdicional de legitimidade.

Não parece adequado debater a correspondência maior ou menor entre a doutrina da discricionariedade administrativa e a teoria dos conceitos jurídicos indeterminados¹⁵⁰, sobre as bases de uma aparente relação de dualidade/conflito entre a discricionariedade plena da Administração (insindicabilidade jurisdicional) e/ou sua vinculação total à revisão judicial. Assim como não se pode avalizar a doutrina rígida e até extremada da “única solução correta” para a aplicação daquelas normas colonizadas por conceitos jurídicos indeterminados, não parece ressoar apropriada, da mesma forma, a defesa da plena insindicabilidade jurisdicional dos juízos discricionários da Administração Pública, uma vez que estes sempre deverão restar submetidos aos parâmetros de legalidade e legitimidade constitucional. Afastar ou assegurar, sempre e em todos os casos, a revisão jurisdicional da discricionariedade administrativa no caso de aplicação de normas veiculadas a partir de conceitos práticos não parece ser a melhor solução.

Sobre a questão da discricionariedade administrativa, cabe reconhecer que este é um dos temas que mais sofre os influxos axiológicos do modelo de Estado constitucional de direito, passando por uma autêntica mutação conceitual, com o abandono daquelas vestes autoritárias e infensas ao controle substantivo e material, típicas do modelo de Estado legislativo, passando com a constitucionalização do Direito Administrativo para uma dimensão muito mais submetida à parametrização axiológica dos princípios constitucionais. Ainda que não seja objeto desse estudo

¹⁵⁰ Sobre o tema, consultar: ALVES, Felipe Dalenogare. **Discricionariedade administrativa, conceitos jurídicos indeterminados e a possibilidade de controle jurisdicional**. São Paulo: PerSe, 2012.

uma abordagem ampla e abrangente do fenômeno da discricionariedade administrativa¹⁵¹, importa considerar que, no Estado constitucional de direito, a atividade administrativa encontra-se plena e visceralmente vinculada ao sistema normativo constitucional.

Não há espaço para juízos discricionários no sentido de valorações político-administrativas livres de quaisquer controles materiais (substantivos). Todo o agir administrativo, ainda que em diferentes graduações e parâmetros, está inteiramente vinculado à Constituição, de onde extrai seu fundamento de validade normativa e legitimidade política. As regras e princípios constitucionais incidem na atividade administrativa, de modo que já não há como defender um espaço de discricionariedade administrativa, mas uma maior ou menor vinculação a partir da perspectiva da juridicidade administrativa¹⁵².

Nunca é demasiado recordar que o agente público não é o dono dos bens e interesses que administra, exercendo apenas uma função administrativa delimitada pelo respectivo plexo de suas competências funcionais. Não lhe é lícito dispor de bens, interesses ou do agir da Administração segundo qualquer ordem de conveniências, paixões ou demandas diversas da cativa vinculação à juridicidade normativa constitucional. Mais do que a estática preocupação em cumprir com a lei (legalidade estrita), o gestor público deve estar preocupado com a concretização e conformação das determinações normativas constitucionais, sempre com a manutenção da mira finalística da atividade administrativa na defesa e promoção dos direitos fundamentais, fim último e fator de legitimação tanto da Administração Pública como, de resto, de todos os poderes constituídos.

¹⁵¹ Para uma abalizada análise da nova roupagem da discricionariedade administrativa no Estado constitucional de direito, em processo de sedimentação na doutrina nacional, sobretudo nas últimas duas décadas, consultar: CADEMARTORI, Luiz Henrique Urquhart. **Discricionariedade administrativa no Estado constitucional de direito**. 1. ed., 3. tir. Curitiba: Juruá, 2003; FREITAS, Juarez. **O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais**. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2004; HARGER, Marcelo. A discricionariedade e os conceitos jurídicos indeterminados. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 765, p. 11-36, out. 1998; PIRES, Luis Manuel Fonseca. **Controle judicial da discricionariedade administrativa**: dos conceitos jurídicos indeterminados às políticas públicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009; SICCA, Gerson dos Santos. **Discricionariedade administrativa**: conceitos indeterminados e aplicação. Curitiba: Juruá, 2006.

¹⁵² Sobre o tema, consultar: BINENBOJM, **Uma teoria do Direito Administrativo...**, p. 208-212; VIANA, Ruth Araújo. O princípio da juridicidade e os princípios constitucionais como instrumentos para o controle eficaz dos atos administrativos discricionários. In: SILVA, Maria Teresinha Pereira; ZANOTELLI, Mauricio (Coord.). **Direito e Administração Pública**: por uma hermenêutica compatível com os desafios contemporâneos. Curitiba: Juruá, 2011. p. 119-148.

No Estado constitucional de direito, mais do que a estática e fechada vinculação à estrita legalidade administrativa, a Administração Pública submete-se à vinculação ao princípio aberto e dinâmico da juridicidade administrativa, no sentido de que a atividade administrativa somente pode ser reconhecida como válida, legítima e adequada (justificada), se conforme ao sistema normativo de regras e princípios previstos na Constituição, com especial destaque para a satisfação dos direitos fundamentais¹⁵³.

Na doutrina brasileira, Germana de Oliveira Moraes sustenta a existência de uma categoria de conceitos jurídicos indeterminados que restariam insuscetíveis a um controle jurisdicional pleno e irrestrito, como no caso daquelas decisões administrativas relacionadas à concretização dos chamados “conceitos de prognose”, cujo preenchimento parte de um juízo de aptidão aplicado na avaliação de pessoas, coisas ou processos sociais¹⁵⁴.

Há situações da prática jurídico-administrativa em que, embora a norma esteja construída sob conceitos indeterminados (*prima facie*), existem meios e parâmetros capazes de afastar a discricionariedade administrativa na aplicação daqueles conceitos empíricos ou conceitos técnicos normatizados, transformando objetivamente em determinável aquele conceito normativo aparentemente indeterminado. Mas isso não é comum a todos os casos em que a Administração Pública aplica conceitos normativos práticos, remanescendo situações marcadas por certa margem de discricionariedade na ponderação e decisão pelos contornos da medida administrativa adequada (juízos valorativos).

Embora não pareça adequada a “confusão” conceitual, é certo que a diminuição da vinculação administrativa caracteriza a atuação estatal concretizadora de disposições normativas veiculadas por meio de conceitos imprecisos, uma vez que “tanto *discricionariedade* quanto *conceitos indeterminados* são técnicas legislativas que traduzem a abertura das normas jurídicas, carecedoras de complementação”¹⁵⁵.

No estudo da questão do interesse público, enquanto conceito jurídico indeterminado, Carlos Ernesto Maranhão Busatto aproxima a análise sob os parâmetros da discricionariedade administrativa, sustentando que, “por se situar implícita ou explicitamente no fim mediato ou

¹⁵³ Nesse sentido: BINENBOJM, *Uma teoria do Direito Administrativo...*, p. 125-194; OTERO, *Legalidade e Administração Pública...*, p. 735-743.

¹⁵⁴ MORAES, Germana de Oliveira. *Controle jurisdicional da Administração Pública*. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2004. p. 76.

¹⁵⁵ BINENBOJM, *Uma teoria do Direito Administrativo...*, p. 218.

imediatamente da disposição legislativa, o administrador é levado a preenchê-lo por meio de juízos valorativos ou prognósticos, atribuindo-lhe os mais diversos sentidos”¹⁵⁶.

Em síntese, convém ressaltar que, nada obstante a indeterminação conceitual característica e geneticamente constitutiva da noção de interesse público, tal situação não pode ser traduzida em uma pretensão de liberalidade ou discricionariedade do agente público para conduzir as decisões e atividades administrativas segundo qualquer dimensão vaga ou subjetiva de interesse público. A densificação administrativa do conteúdo do interesse público somente será legítima se passível de uma recondução racional ao sistema de regras e princípios eleitos pelo legislador constituinte e pela ordem normativa infraconstitucional, se parametrizada com a Constituição. Não se pode admitir que a concretização prática da noção de interesse público possa ser colonizada pelos domínios da discricionariedade administrativa. Em última análise, todas as decisões administrativas são vinculadas (em maior ou menor gradação) à ordem normativo-axiológica constitucional e infraconstitucional, de onde ressaem a justificativa, o fundamento, a finalidade e a própria legitimação do agir administrativo.

2.4.2 O interesse público como conceito jurídico indeterminado determinável

Dados os aportes teóricos preliminares, situando-se o conceito de interesse público na órbita dos conceitos jurídicos indeterminados, convém delimitar com maior apuro essa relação, sobretudo com vistas à definição da determinabilidade daquele conceito nuclear. A partir da proposição de que a expressão “conceito jurídico indeterminado” seja reservada somente para os casos de conceitos efetivamente dotados de elevado grau de indeterminação e vagueza de sentido, Antônio Francisco de Sousa apresenta a sua divisão em diferentes categorias: os *conceitos descritivos* ou *empíricos* seriam aqueles referíveis a objetivos relacionados à realidade prática, como os conceitos de homem, morte, doença; já os *conceitos normativos* estariam ligados a questões valorativas, tanto a partir de uma representação vinculada ao universo normativo, v.g., os conceitos de furto, roubo, estupro (*conceitos normativos em sentido estrito*), quanto nos casos em que o conceito preserva uma relação simultânea entre o universo normativo e uma concepção também axiológica, v.g., os conceitos de

¹⁵⁶ BUSATTO, *Reflexões críticas acerca do papel...*, p. 46.

pessoa indigna, conduta imoral (*conceitos normativos de valor*); e, ainda, os chamados *conceitos discricionários*, comuns à discricionariedade judicial e à discricionariedade administrativa, marcadas pelo que o administrativista português refere como “*autonomia da valoração pessoal*”¹⁵⁷.

Em estudo sobre o tema, e com enfoque ligeiramente diverso, Binenbojm ressalta que os enunciados normativos são constituídos por diversos *conceitos objetivos* (idade, sexo, hora, lugar), sobre os quais não remanescem dúvidas acerca da extensão e do alcance. Há, no mesmo quadrante, *conceitos de conteúdo objetivamente decifrável* (chuva de granizo, morte natural, tráfego lento), que podem receber uma determinação objetiva de sentido (significado) a partir do recurso à *experiência comum* ou a *conhecimentos específicos*. Por outro lado, os *conceitos jurídicos indeterminados* seriam aqueles cujo processo de aplicação venha marcado por dúvidas e controvérsias acerca do seu sentido e alcance (interesse público, urgência, reputação ilibada), reclamando do intérprete da norma uma valoração¹⁵⁸, que pode estar sujeito a um maior (amplo) ou menor (limitado) controle jurisdicional, a depender “*de sua associação ou dissociação da discricionariedade*”¹⁵⁹.

De fato, há incontáveis situações em que o conteúdo dos conceitos jurídico-normativos, embora não integralmente submetidos a uma única e já revelada conformação de sentido (significação), são plenamente decifráveis por meio do recurso a conhecimentos específicos e juízos avaliativos, remanescendo o cabimento de juízos de descrição valorativa da Administração somente no caso daqueles conceitos normativos “efetivamente indeterminados”, e que assim permanecerem no processo de integração da norma ao caso concreto.

Nesse mesmo sentido, Sousa ressalva que a indeterminação de sentido dos conceitos jurídicos não conduz, de forma desavisada e auto-

¹⁵⁷ SOUSA, Antônio Francisco de. *Conceitos indeterminados no Direito Administrativo*. Coimbra: Almedina, 1994. p. 17.

¹⁵⁸ Ainda que não se pretenda aprofundar o debate acerca da interpretação, importa assinalar que a interpretação da norma deve cingir-se à busca do seu conteúdo correto, sua intenção e extensão, o fim a que se propôs a lei com o uso de determinada expressão ou termo jurídico. Deve o intérprete, valendo-se das regras de hermenêutica, questionar acerca da intenção da norma, a partir do termo empregado (ainda que impreciso). Que fim pretendeu a lei quando resguardou a “moralidade pública”, quando exigiu o “notório saber”? Bonavides ensina que a interpretação é uma “*operação lógica, de caráter técnico mediante o qual se investiga o significado exato de uma norma jurídica, nem sempre clara ou precisa [...] Em verdade, a interpretação mostra o direito vivendo plenamente a fase concreta e integrativa, objetivando-se na realidade*”. Bonavides, *Curso de Direito Constitucional*..., p. 398-99.

¹⁵⁹ BINENBOJM, *Uma teoria do Direito Administrativo*..., p. 214.

mática, à livre discricionariedade administrativa, alertando que todo o “*conceito legal indeterminado é pluridimensional, mas nem toda a pruridimensionalidade de um conceito legal indeterminado é querida pela lei. Neste caso, é possível uma passagem para a unicidade, isto é, é possível que o conceito legal indeterminado passe a ser determinado*”¹⁶⁰.

Em todos os casos, ressalta-se a importância em apurar se o conteúdo do conceito indeterminado não se revela determinável a partir da “*experiência empírica, da interpretação com cunho valorativo ou auxiliada por conhecimentos técnicos específicos, pois a ampliação da margem de liberdade subjetiva do intérprete é excepcional e somente observada na apreciação de conceitos eminentemente valorativos*”¹⁶¹.

Ademais, não se pode olvidar que a imprecisão, a vagueza e a indeterminação dos conceitos jurídicos aplicados no ordenamento jurídico são comuns à linguagem cotidiana. Trata-se de um traço característico da linguagem, em todos os idiomas naturais. Não se trata de um erro ou defeito a ser corrigido. Assim, no caso da linguagem jurídico-normativa, a problemática gravita em torno dos limites de significação de cada conceito jurídico plurissignificativo.

Partindo dessa premissa, Fernando Sainz Moreno esclarece que todo conceito possui um núcleo que corresponde à sua essência, seu significado originário (núcleo conceitual). Esse núcleo de significação corresponderia à zona de certeza do conceito (domínio das afirmações evidentes). A zona de certeza comporta tanto uma aceção positiva (induvível aplicação/determinação do conceito jurídico para o caso/situação sob juízo) como um polo negativo (inequívoco descabimento do conceito normativo). No caso dos conceitos jurídicos indeterminados, entre as zonas de certeza positiva e negativa restaria uma zona de dúvida (halo), sujeita à integração/interpretação conceitual a partir de juízos e perspectivas pessoais (subjetivas)¹⁶².

Essa “zona cinzenta”, intermediária entre as certezas positiva e negativa, pela qual resta controvertida e imprecisa a definição do conceito jurídico e seus parâmetros de densificação, é comum aos conceitos jurídicos indeterminados, dentre os quais o interesse público. Na trilha destas considerações, Ribeiro adverte que, “*por mais que inicialmente, em abstrato, diretamente, não seja possível dizer, precisar, esquadriñar o que seja, é possível, sem grandes dificuldades, chegar-se a um consenso do*

¹⁶⁰ SOUSA, *Conceitos indeterminados no Direito Administrativo*..., p. 83.

¹⁶¹ BUSATTO, *Reflexões críticas acerca do papel*..., p. 45.

¹⁶² SAINZ MORENO, Fernando. *Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa*. Madrid: Civitas, 1976. p. 197.

que não é, e com o complemento dado pela situação posta, ao que, naquele caso, é o *interesse público*¹⁶³.

Em suma, quer a partir de uma perspectiva negativa quer pela via de uma dimensão positiva, a concretização otimizada dos contornos e limites do que seja o interesse público em determinada situação concreta dependerá de um juízo ponderativo da Administração Pública, a partir de uma atividade vinculativa e submetida direta e imediatamente à ordem normativa de regras e princípios constitucionais, complementada pelo conjunto de ponderações do legislador ordinário e dos demais instrumentos normativos infraconstitucionais, que servem de baliza e fundamento de legitimidade do próprio agir administrativo.

2.5 O INTERESSE PÚBLICO NO DIVÃ: PARA UM CONCEITO DE INTERESSE PÚBLICO

A construção de um conceito de interesse público não é, certamente, uma empreitada singela e acanhada¹⁶⁴. Há quem defenda, inclusive, que o interesse público acabe por ser refratário ao aprisionamento em

¹⁶³ RIBEIRO, *Interesse público*: um conceito jurídico determinável..., p. 118.

¹⁶⁴ No presente estudo o debate acerca do interesse público estará voltado, mais especificamente, à seara das relações jurídico-administrativas. Mas a temática relacionada ao conceito de interesse público, sua prevalência abstrata e apriorística, além da relação com a defesa e promoção dos direitos fundamentais, não está restrita ao Direito Administrativo. No Direito Tributário, por exemplo, debate com semelhantes contornos começa a tomar densidade. Sobre o tema, consultar: SEVEGNANI, Joacir. *A resistência aos tributos no Brasil*: Estado e sociedade em conflito. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009; TAVARES, Diogo Ferraz Lemos. *A supremacia do interesse público e o Direito Tributário*. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2012. Importa, ainda, suscitar que a construção do debate em torno da ideia de interesse público na seara tributária não pode prescindir de uma ampla recuperação da própria noção do tributo na História, no sentido de fixar em sólida contextualização histórica e política as adequadas bases da concepção de interesse público e seus desdobramentos na ordem constitucional, sobretudo a partir de uma dinâmica e aberta leitura do princípio republicano, conjugado com os demais princípios constitucionais estruturantes, como a dignidade da pessoa humana, o Estado democrático de direito e o princípio federativo. Sobre a recuperação das bases históricas e políticas da noção de tributo, consultar: BALTHAZAR, Ubaldo Cesar. *História do tributo no Brasil*. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005; BALTHAZAR, Ubaldo Cesar (Org.). *O tributo na História*: da Antiguidade à Globalização. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006; CATARINO, João Manuel Ricardo. *Para uma teoria política do tributo*. 2. ed. Lisboa: Centro de Estudos Fiscais, 2009; CATARINO, João Manuel Ricardo. *Redistribuição Tributária*: Estado social e escolha individual. Coimbra: Almedina, 2008.

uma noção propriamente conceitual (que ostente um conteúdo determinado). Seria, portanto, uma noção muito mais funcional e dinâmica do que conceitual, podendo apresentar muitas variações segundo critérios quantitativos e qualitativos, se apurada em diferentes épocas (tempo) e países (espaço)¹⁶⁵. Inclusive, esta dificuldade em estabelecer um conceito de interesse público levou o administrativista argentino Guillermo Andrés Muñoz a defender (de forma lapidar e até poética) que o interesse público seria como o amor: mais fácil sentir do que definir!¹⁶⁶

Ante a sua característica fluidez conceitual, há quem qualifique a ideia de interesse público como verdadeiro *tópois*¹⁶⁷, um *lugar comum* (*locus*), e que por isso mesmo dispensaria uma definição mais precisa, até para facilitar sua adequada e eficiente aplicação¹⁶⁸.

A aventada dificuldade em definir o interesse público também não escapou à aguçada lente do administrativista espanhol Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, atribuindo-a, entre outras particularidades, ao fato de estar visceralmente ligado à realidade, não existindo a sua margem ou dela afastado. O interesse público restaria descortinado e projetado a partir da sua operação de materialização, precipuamente promovida pela Administração Pública. Mas isso não equivale a dizer, por outro lado, que não existam parâmetros de aferição racional e normativa do interesse público, que residiria atualmente “no marco dos princípios informadores do Estado social e democrático de Direito”¹⁶⁹.

Convém agora colher algumas contribuições da doutrina jurídica estrangeira, na tentativa de lançar os adequados parâmetros ao concei-

¹⁶⁵ Nesse sentido: RIVERO, *Direito Administrativo*..., p. 15; VEDEL, Georges. *Derecho Administrativo*. Traducción de la 6. edición francesa por Juan Rincón Jurado. Madrid: Biblioteca Jurídica Aguilar, 1980. p. 257-260.

¹⁶⁶ MUÑOZ, Guillermo Andrés. El interés público es como el amor. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). *Direito Administrativo e interesse público*: estudos em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 21-31.

¹⁶⁷ Para estudo acerca da tópica jurídica, pode-se consultar: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. *Colisões entre princípios*..., p. 121-32; GARCIA AMADO, Juan Antonio. *Tópica, Derecho y método jurídico*. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Alicante, n. 04, p. 161-188, 1987; VIEHWEG, Theodor. *Tópica y jurisprudencia*. Traducción de Luis Díez-Picazo Ponce de Leon. Madrid: Taurus, 1964.

¹⁶⁸ FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Interesse público. *Revista do Ministério Público do Trabalho da 2ª Região*. São Paulo, n. 01, p. 09-20, 1995, p. 10-12.

¹⁶⁹ RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. El interés general como categoria central de la actuación de las Administraciones Públicas. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). *Direito Administrativo e interesse público*: estudos em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 42.

to de interesse público¹⁷⁰. Na doutrina administrativista francesa, pode-se obter da clássica obra de Georges Vedel um importante contributo para o conceito de interesse público. Após esclarecer que esta noção atende por diferentes designações (interesse público, interesse geral, utilidade pública), Vedel apresenta-o a partir de duas acepções: uma, político-constitucional e outra, jurídico-administrativa¹⁷¹.

Sobre a perspectiva política, Vedel sustenta a necessidade de afastar o que designa como dois equívocos recorrentes: primeiramente, há que se superar a ideia de que o interesse público não seria mais do que o simples somatório dos interesses particulares; da mesma forma, não se pode admitir a crença de que o interesse público não teria qualquer relação com os indivíduos ou com os grupos que compõem a nação, um erro sutil e que acaba comumente povoando os próprios comportamentos administrativos estatais. Nesse sentido, o interesse público nasceria do processo de arbitragem entre os diversos interesses particulares em jogo, por vezes inclinando-se em favor dos interesses de um grupo mais numeroso de indivíduos (critério quantitativo), a exemplo de uma desapropriação por necessidade ou utilidade pública; outras vezes, por outro lado, a partir do respaldo qualitativo de interesses de minorias, como no caso dos sistemas de assistência social e de saúde para determinados grupos de indivíduos das camadas menos favorecidas da sociedade¹⁷².

Essa perspectiva político-constitucional do interesse público, vinculada à consecução de uma finalidade (objetivo) pública geral e norteadora das ações estatais, encontra uma fartura de exemplos na ordem constitucional brasileira, desde o seu preâmbulo¹⁷³ e, sobretudo, no artigo

¹⁷⁰ Para um amplo e abrangente inventário doutrinário da noção de interesse público no Direito Comparado, pode-se consultar: DIAS, André de Vasconcelos. **O interesse público no Direito Comparado**. 2008. 127 f. Monografia da Disciplina de Direito Administrativo (Mestrado em Direito) – Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito, Ciências Jurídico-Políticas, Lisboa, 2008.

¹⁷¹ VEDEL, **Derecho Administrativo...**, p. 257.

¹⁷² *Ibidem*, p. 257-258.

¹⁷³ O preâmbulo (documento comum às Constituições contemporâneas) representa a síntese dos objetivos e finalidades estruturantes de determinado diploma constitucional, a ruptura com a ordem constitucional anterior e a instituição de um novo conjunto de valores e princípios fundantes do nascente Estado constitucional de direito. A doutrina majoritária e a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 2.076, Rel. Min. Carlos Velloso – Julgamento pelo Plenário em 15.08.2002 – Publicado no DJ em 08.08.2002) não reconhecem o preâmbulo como parte do texto constitucional propriamente dito, o que afastaria sua utilização enquanto paradigma de comparação para o controle de constitucionalidade de atos normativos e administrativos (tese da irrelevância jurídica). Nesse sentido, o preâmbulo constitucional seria um documento eminentemente político e desprovido de qualquer força normativa, não veiculando

3º da Constituição Federal, que elenca os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.

Desta forma, na perspectiva política o interesse público viria delineado pelo legislador constitucional (e também infraconstitucional), a quem competiria definir os objetivos político-sociais a serem perseguidos pela ação estatal. Apesar disso, nem sempre esses parâmetros políticos do interesse público alcançam expressa positividade jurídico-constitucional, “mas, uma vez que isso ocorra, a expressão torna-se paradigmática e fundamental: a lei passa a ser a definição incontestável e inviolável do interesse público”¹⁷⁴.

Já a noção jurídico-administrativa de interesse público estaria relacionada diretamente à determinação, pelas autoridades legislativas competentes (constitucionais e infraconstitucionais), da prevalência de determinados interesses especiais, cabendo ao legislador dispor das normas jurídicas necessárias para a consecução das finalidades públicas eleitas, com a respectiva criação de serviços públicos e a determinação das atividades estatais capazes de alcançar os referidos objetivos, inclusive indicando a autoridade competente para intervir na matéria, os meios e recursos aos quais poderá recorrer¹⁷⁵.

Na verdade, o sentido jurídico-administrativo do interesse público guarda estreita relação de dependência ao primado da legalidade, no sentido da fiel observância dos parâmetros normativos impostos (expressa e implicitamente) pela ordem jurídica. Por outro lado, embora a eleição (definição) das finalidades gerais de interesse público comumente não

propriamente normas constitucionais. Diversamente, corrente minoritária defende que o preâmbulo é texto normativo materialmente integrante da Constituição, dela fazendo parte e com ela se relacionando, em um todo orgânico, aberto e sistemático, sendo que suas disposições gozariam de força normativa vinculante tanto para o restante do texto constitucional, como para a totalidade do ordenamento jurídico, dos poderes constituídos e da sociedade. Síntese das diretrizes sociopolíticas, filosóficas e ideológicas da nova ordem constitucional, o preâmbulo serviria de parâmetro de conformação inarredável e verdadeira linha mestra interpretativa (tese da plena eficácia). Apesar disso, inclusive pelo caráter extremamente aberto e generalizante de suas disposições, parece correto reconhecer a dificuldade da argumentação no sentido de uma possível afronta direta ao preâmbulo, que já não tenha atacado (mais diretamente) outras disposições constitucionais específicas. Mas isso não retira, de forma alguma, seu valor como elemento de interpretação e integração do texto constitucional (tese da relevância jurídica indireta). Para estudos complementares, pode-se consultar: ARAÚJO, Sérgio Luiz Souza. O preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 e sua ideologia. **Revista de Informação Legislativa**. Brasília, a. 36, n. 143, p. 05-14, jul./set. 1999.

¹⁷⁴ MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. **Curso de Direito Administrativo**. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996. p. 430.

¹⁷⁵ VEDEL, **Derecho Administrativo...**, p. 258-259.

gravite no plexo de atribuições da Administração Pública, esta “*assume com frequência a tarefa de tomar atitudes que o concretize na atividade cotidiana, valendo-se de um amplo poder de apreciação casuística*”¹⁷⁶. Esta é, seguramente, a face mais perigosa e instável da consecução do interesse público, quando da sua concretização pela Administrativa Pública, sobretudo naqueles casos de alargada indeterminação normativa (conceitos indeterminados, interesse público implícito etc.), o que facilita sobremaneira a tomada de assalto dos espaços públicos por conjuntos de interesses egoísticos travestidos de incontestável interesse público.

A título ilustrativo, colaciona-se também o pensamento de outro administrativista francês, Jean Rivero, para quem o interesse público (geral) não seria “*o interesse da comunidade como uma entidade distinta dos que a compõem e superior a eles; é muito mais simplesmente, um conjunto de necessidades humanas – aquelas a que o jogo das liberdades não provê de maneira adequada e cuja a satisfação, todavia, condiciona a realização dos destinos individuais*”¹⁷⁷.

Na literatura jurídica lusitana¹⁷⁸, Rogério Guilherme Ehrherdt Soares compôs uma das primeiras obras monográficas específicas sobre a temática relacionada ao interesse público. Após uma análise das três clássicas funções do Estado moderno, Soares afiança que dentre elas a única livre é a de legislar, em uma espécie de “desvinculação absoluta” que não encontra limites de natureza jurídica. Entretanto, tal liberdade somente pode ser usada para a tutela do interesse público, repartindo os bens da sociedade (materiais e imateriais), conforme uma escala de fins a que se destinam, para a justa composição dos interesses em conflito¹⁷⁹.

¹⁷⁶ BUSATTO, *Reflexões críticas acerca do papel...*, p. 21.

¹⁷⁷ RIVERO, *Direito Administrativo...*, p. 15.

¹⁷⁸ Para um estudo panorâmico da noção de interesse público no Direito Administrativo português, pode-se consultar: ANTUNES, Luís Filipe Colaço. *Constituição, Administração e interesse público*: o eterno retorno ao momento originante ou o Estado contra a Administração. 25 Anos da Constituição da República Portuguesa de 1976: evolução constitucional e perspectivas futuras. Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, Lisboa, p. 542-560, 2001; CAUPERS, João. *Introdução ao Direito Administrativo*. Lisboa: Âncora, 2000. p. 61-66; CORREIA, José Manuel Sérvulo. *Noções de Direito Administrativo*. Lisboa: Danúbio, 1982.v. I, p. 227-231; SILVA, Frederico Rodrigues. *Abordagem crítica acerca do interesse público*: uma visão Brasil-Portugal. 2009. 51 f. Monografia da Disciplina de Direito Administrativo (Mestrado em Direito) – Universidade de Lisboa. Faculdade de Direito, Ciências Jurídico-Políticas, Lisboa, 2009; SOUSA, Marcelo Rebelo de. *Lições de Direito Administrativo*. Lisboa: Pedro Ferreira, 1995.v. I, p. 123-142.

¹⁷⁹ SOARES, Rogério Guilherme Ehrhardt. *Interesse público, legalidade e mérito*. Coimbra: Atlântida, 1955. p. 101.

Com base na doutrina carneluttiana de “*interesse público na justa composição dos conflitos*” (de caráter formalista), Soares avança para a construção de uma ideia de composição de conflitos a partir da noção material de necessidade coletiva ou interesse coletivo, designado de *interesse coletivo primário*, como sendo aqueles fins privados ou públicos reconhecidos pelo legislador. Nesta quadra, o interesse público não seria “*um interesse abstracto ou um bem que pertença a uma esfera totalmente distinta da esfera do cidadão: ‘o interesse público é, sem perder a sua qualidade de interesse superior, nem se resolver na soma desses interesses, a sublimação numa unidade da qual, todavia, os interesses particulares são coeficientes*”¹⁸⁰.

Interessante atentar que, diversamente do que ocorre no Brasil, no caso da atual ordem constitucional portuguesa, a Constituição de 1976 expressamente assegura, no inc. 1 do seu art. 267, o princípio da prossecução (não da supremacia) do interesse público, quando dispõe que a “*Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos*”¹⁸¹. Partindo desta esteira normativo-constitucional lusitana, Amaral chama a atenção para alguns corolários do chamado princípio da prossecução do interesse público: 1. Compete à lei definir os interesses públicos e não à Administração Pública, salvo as (por vezes tormentosas e desviadas) situações de competência administrativa para a concretização de conceitos indeterminados; 2. O interesse público ostenta conteúdo variável, não admitindo definições rígidas e inflexíveis; 3. A definição do interesse público pela lei impõe a obrigatoriedade de cumprimento pela Administração Pública; 4. O interesse público delimita a capacidade jurídica das pessoas coletivas públicas e a competência dos seus órgãos (princípio da especialidade); 5. Somente o interesse público legalmente previsto justifica a atividade administrativa, pelo que, na sua ausência, a atividade estará viciada por desvio de poder (finalidade); 6. A satisfação de interesses privados em vez de interesses públicos pela Administração Pública, seus órgãos e agentes caracteriza corrupção punível civil, criminal e adminis-

¹⁸⁰ *Ibidem*, p. 103.

¹⁸¹ A título ilustrativo, convém fazer referência à Constituição espanhola de 1978, que em termos bastante assemelhados à Constituição portuguesa de 1976, em seu artigo 103, 1 assegura que “*la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales...*”. Para uma análise da noção de interesses gerais na ordem constitucional espanhola, consultar: MEILÁN GIL, José Luis. *Intereses generales e interés público desde la perspectiva del Derecho Público español*. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). *Direito Administrativo e interesse público*: estudos em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 65-88.

trativamente; 7. A obrigatória prossecução do interesse público impõe à Administração Pública a adoção, em cada caso concreto, das melhores soluções técnicas, administrativas e financeiras possíveis (dever de boa administração¹⁸² ¹⁸³).

Com efeito, de todos esses corolários do princípio da prossecução do interesse público, didática e oportunamente referidos pelo administrativista lusitano, o penúltimo é seguramente o mais problemático e controvertido, na medida em que aparentemente posiciona os interesses privados e o Poder Público em rota de colisão.

À primeira vista, essa posição acaba por desconsiderar a hipótese (totalmente possível e recorrente nas sociedades contemporâneas) de o ordenamento jurídico albergar legítimos interesses particulares/privados, notadamente aqueles empreendimentos econômicos da iniciativa privada em geral, relacionados, v.g., às áreas do turismo, da cultura, da ciência e da tecnologia. Áreas direta ou indiretamente dependentes de uma atividade estatal de fomento econômico, tecnológico e/ou qualquer outra forma de estímulo estatal. E sem que isso venha a convolar aqueles interesses privados em interesses públicos. Já não se pode conceber a ideia de que, como um Midas moderno, tudo o que o Estado toque seja convertido em interesse público. Isso acabaria, inclusive, por ampliar de forma tal esse conceito, que o efeito seria esvaziá-lo por completo de sentido operativo (uma espécie de maldição de Midas): albergando tudo, para nada mais serviria!

Retomando o inventário doutrinário em curso, no Brasil pode-se seguramente atribuir a Celso Antônio Bandeira de Mello os estudos mais respeitados e tradicionalmente difundidos acerca da temática que envolve o interesse público. Segundo o administrativista pátrio, o “*interesse público deve ser conceituado como o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato de o serem*”¹⁸⁴.

É oportuno ressaltar, inclusive, que foi Mello o difusor no Brasil da célebre diferenciação entre interesses públicos primários e interesses públicos secundários, com base na obra de Renato Alessi. A partir do

¹⁸² Para estudos aprofundados sobre o dever de boa administração como direito fundamental dos cidadãos, pode-se consultar: FREITAS, Juarez. *Discrecionalidade administrativa e o direito fundamental à boa Administração Pública*. São Paulo: Malheiros, 2007.

¹⁸³ AMARAL, *Curso de Direito Administrativo...*, p. 36-38.

¹⁸⁴ MELLO, *Curso de Direito Administrativo...*, p. 51.

debate acerca da noção de função administrativa e sua centralidade para a Administração Pública¹⁸⁵, o administrativista italiano busca respaldo da doutrina carneluttiana para esclarecer que os interesses públicos (coletivos) não podem ser confundidos com os interesses do Estado, do aparelho da Administração burocrática ou do erário, assim unitariamente considerados. Essa relação seria apenas contingencial (possível, mas não necessária), pelo que os interesses secundários do Estado (aparato estatal) e da estrutura administrativa somente poderiam ser legitimamente mirados e almejados pela Administração Pública quando e se (somente se) coincidentes com os interesses coletivos primários, os únicos e verdadeiros interesses públicos propriamente ditos¹⁸⁶.

Nessa mesma linha, para José dos Santos Carvalho Filho a noção de interesse público radica na superação das “*fronteiras dos interesses individuais e representa uma demanda de satisfação por parte das comunidades*”, pelo que “*o interesse público não é o somatório dos interesses individuais dos componentes do grupo social, mas traduz interesse próprio, coletivo, gerador de satisfação geral, e não individual; enfim, busca o bem comum*”¹⁸⁷.

Esse debate é redimensionado por Justen Filho, inicialmente com base em uma conceituação negativa de interesse público, ou seja, a partir daquilo que não configura o conceito ou com ele se confunde, a fim de chegar ao que poderia ser assim definido. Primeiro, cabe reconhecer que o interesse público não se confunde com o interesse do Estado, já que este é, sim, instrumento de realização daquele. O interesse público sequer é essencialmente de titularidade do Estado, já que existem interesses públicos não estatais, como o caso do chamado terceiro setor (no Brasil, são exemplos as Organizações Não-Governamentais (ONGs), as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) e as Entidades do Sistema S). Por outro lado, sob as balizas de uma Constituição republicana e democrática como a brasileira, não se pode entender o Estado senão como instrumento de satisfação dos interesses públicos, ou seja, aquilo que gravita em torno da consecução dos direitos fundamentais, instância última de legitimação da própria estrutura estatal¹⁸⁸.

¹⁸⁵ Para estudos aprofundados sobre a noção de função administrativa a partir de Alessi, pode-se consultar: ALESSI, Renato. *Principi di Diritto Amministrativo*: I soggetti attivi e l'esplorazione della funzione amministrativa. 4. ed. Milano: Giuffrè, 1978. t. 1, p. 01-16.

¹⁸⁶ ALESSI, Renato. *Sistema Istituzionale del Diritto Amministrativo Italiano*. 3. ed. Milano: Giuffrè, 1960. p. 197-201.

¹⁸⁷ CARVALHO FILHO, *Interesse público...*, p. 73.

¹⁸⁸ JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 37.

Realmente, “nenhum ‘interesse público’ se configura como ‘conveniência egoística da administração pública’”, já que o chamado interesse secundário ou interesse da Administração Pública não é público, não sendo sequer efetivo interesse, mas mera conveniência circunstancial¹⁸⁹. Nem se confunde com os interesses do agente público, que deve pautar suas ações segundo os interesses da coletividade abstratamente considerada, e não interesses particulares egoísticos. O Estado “somente está legitimado a atuar para realizar o bem comum e a satisfação geral”¹⁹⁰.

Com efeito, o interesse público também não pode ser simploriamente qualificado como o interesse da maioria da população (critério quantitativo)¹⁹¹, o que afrontaria sobremaneira ao princípio do Estado

¹⁸⁹ Nesse sentido, ao que parece, Justen Filho acaba por afastar a doutrina alessiana da distinção entre os interesses primários e secundários, na medida em que aqueles interesses meramente instrumentais da Administração Pública não seriam públicos. Nas palavras do autor: “O chamado ‘interesse secundário’ (ALESSI) ou ‘interesse da Administração Pública’ não é público. Ousa-se afirmar que nem ao menos são ‘interesses’, na acepção jurídica do termo. São meras conveniências circunstanciais, alheias ao Direito. A tentativa de obter a maior vantagem possível é válida e lícita, observados os limites do direito, apenas para os sujeitos privados. Essa conduta não é admissível para o Estado, que só está legitimado a atuar para realizar o bem comum e a satisfação geral”. *Ibidem*, p. 39.

¹⁹⁰ *Idem*, *Ibidem*.

¹⁹¹ Sobre essa complicada e mesmo tormentosa questão da relação entre o interesse público e o princípio majoritário, convém trazer a difundida obra do administrativista argentino Héctor Jorge Escola, que, em 1989, desenvolveu abrangente trabalho monográfico específico sobre o interesse público como categoria fundamental ao Direito Administrativo, a partir de um conceito de interesse público marcado por uma estreita (mesmo constitutiva) relação com o princípio majoritário. Depois de defender que o Direito Administrativo tem seu real fundamento no interesse público, razão de ser da atividade administrativa, cabendo, sim, entendê-lo não como um direito da Administração Pública e sim, como um verdadeiro direito do interesse público, buscado por meio da ação do Poder Público, Escola oferece uma definição de interesse público, segundo a qual, “o resultado de um conjunto de interesses individuais, compartilhados e coincidentes, de um grupo majoritário de indivíduos, que se destina a toda a comunidade como consequência dessa maioria, e que encontra sua origem no querer axiológico desses indivíduos, figurando com um conteúdo concreto e determinável, atual, eventual ou potencial, com eles pessoal e diretamente relacionado, que podem reconhecer no interesse público seu próprio querer e sua própria valoração, prevalecendo sobre os interesses individuais que se lhe oponham ou afetem, os quais afasta ou substitui, sem aniquilá-los”. Nesse sentido: ESCOLA, Héctor Jorge. *El interés público como el fundamento del Derecho administrativo*. Buenos Aires: Depalma, 1989. p. 236-250. Sem embargo do meritório esforço da definição oferecida, não se pode negar a acentuada abrangência e abertura conceitual, o que prejudica sua adequada aplicação. Ademais, e isso parece ser o ponto mais problemático, a definição oferecida remete, de forma até perigosa, diretamente para uma ideia de interesse público a partir de uma regra de maioria, o que seria totalmente inadmissível em um

democrático de direito, destruindo e marginalizando os interesses das minorias, em uma perigosa supremacia ou ditadura dos interesses da maioria, quase sempre eventual, sazonal e manipulável. O interesse público, este conceito jurídico indeterminado¹⁹², não pode ser apressada e descontextualizadamente resumido a uma questão numérica, sob pena de odiosa ruptura com o princípio democrático e os direitos fundamentais que gravitam na órbita constitucional. Trata-se de um conceito muito mais qualitativo do que quantitativo, sintetizado no interesse coletivo plasmado nas estruturas axiológico-normativas edificadas com base na engenharia constitucional dos direitos fundamentais.

Para Justen Filho, somente seria viável “aludir a ‘interesse público’ como resultado de um longo processo de produção e aplicação do direito”, sendo que não haveria “*interesse público prévio ao direito ou à atividade decisória da Administração Pública*”. Por conseguinte, o conceito de interesse público envolveria uma questão ética e não técnica, pelo que haveriam demandas diretamente voltadas à “*realização de princípios e valores fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa humana*”. Desta maneira, poder-se-ia defender que o “*ponto fundamental é a questão ética, a configuração de um direito fundamental. Ou seja, o núcleo do direito administrativo não reside no interesse público, mas nos direitos fundamentais*”¹⁹³.

2.5.1 Sobre a bidimensionalidade do conceito de interesse público: sentido amplo e sentido estrito

Todas essas considerações permitem a construção de uma relação bidimensional do conceito de interesse público: tanto um conceito mais aberto e ampliativo, que pode ser reconduzido a uma dimensão político-axiológica do interesse público (sentido amplo); como um conceito mais restritivo, que, por falta de uma designação mais adequada, pode ser indicada como uma perspectiva jurídico-normativa (sentido estrito). Isto

modelo de Estado constitucional de direito, que tem no componente político do respeito às minorias um dos seus relevantes e insuprimíveis traços constitutivos.

¹⁹² O tema dos conceitos jurídicos indeterminados já foi objeto de análise anterior. Para estudos complementares, pode-se consultar: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Discrecionariedade e controle jurisdicional*. 2. ed. 3. tir. São Paulo: Malheiros, 1998; COSTA, *Conceitos jurídicos indeterminados...*, p. 125-138; CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. A evolução do princípio de legalidade e o controle jurisdicional da discrecionariedade administrativa. *Revista Discente Interinstitucional (RDI)*. Florianópolis, a. 1, n. 1, p. 139-169, jan./jun. 2006.

¹⁹³ JUSTEN FILHO, *Curso de Direito Administrativo...*, p. 43-44.

não equivale a dizer que exista qualquer disposição estanque ou irremediavelmente contraposta entre aquelas duas perspectivas, mas há elementos que asseguram o interesse funcional e operativo da distinção proposta.

Com base em uma perspectiva político-axiológica (sentido amplo), o conceito de interesse público pode ser construído a partir da justa posição àqueles princípios e valores constitucionais que fundam as próprias bases do Estado republicano, social e democrático de direito, conjugando-se àquelas cimeiras pautas axiológico-constitucionais que exprimem as noções de igualdade, liberdade, equidade, segurança, democracia e justiça¹⁹⁴, veiculadas expressa ou implicitamente pelos direitos e garantias fundamentais. Nessa perspectiva abrangente, é possível sustentar, inclusive, que em diversos casos concretos a efetiva satisfação do interesse público poderá residir exatamente na defesa de determinado interesse individual (privado), no sentido de que a realização deste importa na concretização daquele, em uma espécie de vinculação estrutural. Até porque, nesta dimensão político-axiológica, não há espaço para necessárias oposições abstratas e apriorísticas entre interesses públicos e interesses privados. Nem para quaisquer reducionismos estatistas de monopólio da defesa e promoção do interesse público.

Sobre esta perspectiva mais abrangente da noção de interesse público, Daniel Sarmento oferece um exemplo interessante no sentido de demonstrar que, em diversas ocasiões, a defesa de um direito fundamental (individual) acaba por resultar na reflexa ou até direta promoção do interesse público. Tome-se para análise a relevante e amplamente debatida questão da liberdade de manifestação e de reunião (art. 5º, IV e XVI da CF/88). Imagine-se que a Administração Pública, invocando a supremacia do interesse público, pretendesse proibir a realização de uma determinada manifestação no centro de uma dada cidade, com a justificativa de que tal atividade comprometeria gravemente o trânsito de vias importantes daquele espaço urbano. É possível, talvez até provável, que grande parte (e mesmo a maioria) da população atingida pelas manifestações apoiasse aquela decisão administrativa, por falta de identidade política com as bandeiras da manifestação ou simplesmente

¹⁹⁴ Ultrapassa os limites deste estudo uma análise do conceito de justiça e suas variadas teorias. Sobre o tema, pode-se consultar uma das mais influentes teorias da justiça na contemporaneidade, na obra do filósofo estadunidense John Rawls, com o seu debate no pensamento de Amartya SEN. Nesse sentido: RAWLS, John. **Uma teoria da justiça**. Tradução de Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 1997; SEN, Amartya. **A ideia de justiça**. Tradução de Nuno Castello-Branco Bastos. Coimbra: Almedina, 2009.

pelos inegáveis infortúnios decorrentes da restrição a sua locomoção (art. 5º, XV da CF/88)¹⁹⁵.

Por outro lado, uma análise mais ampliada da questão do interesse público, a partir de uma leitura político-axiológica da ordem constitucional, acabaria por conduzir à decisão ponderativa pela necessária prevalência das liberdades de manifestação e reunião (se estabelecidas dentro dos limites constitucionais, ainda que tensas, mas não pautadas pelo signo da violência gratuita), enquanto direitos fundamentais diretamente instrumentais ao Estado democrático de direito, mesmo que em detrimento daquelas conveniências pessoais e outros interesses relacionados ao regular trânsito (fluxo) de veículos na via pública.

A destacada genética contramajoritária dos direitos fundamentais não permite que eles sucumbam a anseios egoísticos, interesses de maiorias ocasionais ou restrições incompatíveis com a ética constitucional da prevalência dos direitos fundamentais. Neste caso, o interesse público estará claramente tatuado na própria perspectiva da defesa dos direitos fundamentais individuais de uma minoria, ainda que ante todo um estado de indignação e até pressão política da opinião pública¹⁹⁶, muitas vezes facilmente manipulável por interesses que produzem uma publicidade recortada e seletiva dos fatos que serão noticiados: quais os retalhos fáticos que serão e como serão divulgados pela imprensa!

Mas o exemplo acima dado permite, ainda, uma análise sob outra perspectiva, muito mais reveladora do perigo que pode representar a construção isolada de um conceito de interesse público assim fluido, abrangente e totalizante. O caso do direito de manifestação e reunião deixa evidente que, em diversas situações, justificativas administrativas de “preventiva” defesa da “ordem pública”, da “segurança da coletividade” e de uma dimensão de interesse público (muito próxima de uma ideia de interesses da maioria), permitem que a Administração Pública facilmente confunda/camufle a imediata e severa restrição a direitos e garantias individuais pela via de uma retórica frouxa de defesa do interesse público. Por vezes, o

¹⁹⁵ SARMENTO, Daniel. Supremacia do interesse público? As colisões entre direitos fundamentais e interesses da coletividade. In: ARAGÃO, Alexandre dos Santos; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coord.). **Direito Administrativo e seus novos paradigmas**. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 119-120.

¹⁹⁶ Ultrapassa os limites do presente estudo a análise mais detida da complexa categoria “opinião pública” e suas diferentes perspectivas e nuances. Para um estudo sobre o tema, pode-se consultar: BASTOS JÚNIOR, Luiz Magno Pinto. Para uma conceitualização de opinião pública a partir das categorias gramscianas de hegemonia e bloco histórico. **Revista Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos**. Florianópolis, v. 21, n. 40, p. 40-61, jul. 2000.

grande problema não gravita somente na órbita abrangente do conceito político-axiológico do interesse público. Reside, também, na sua desvirtuada e autoritária aplicação pelo Poder Público, afastada de uma ponderação dialética de defesa e promoção dos direitos fundamentais.

Questões como esta merecem elevada atenção e preocupação, em especial, em democracias como a brasileira (frágeis e ainda em construção), ante a facilidade encontrada pelas autoridades públicas para legitimar discursos de restrição a direitos individuais, com base em uma noção muitas vezes autoritária e acrítica de satisfação do interesse público, quase sempre aplaudida por uma opinião pública completamente refém dos mecanismos de imprensa em geral, capazes de criar autênticas e “prodigiosas” cortinas de fumaça, com a produção seletiva de verdades que interessam a determinados setores do poder político e econômico (de dentro e de fora do Estado). Um verdadeiro “canto da sereia” que pode seduzir rapidamente significativas parcelas de uma sociedade ainda classista, excludente e politicamente apática.

Este cenário de justificação das ações e omissões do Poder Público, com base em uma debilitada retórica do interesse público, também acaba por invadir e colonizar os tribunais, muitas vezes menos preocupados com o debate jurídico-constitucional de demandas de elevada expressão monetária e alcance de massa, suplantado por preocupações políticas vinculadas ao impacto econômico-financeiro das decisões. A “análise econômica do direito” pelos tribunais não pode invalidar cláusulas constitucionais veiculadoras de direitos fundamentais, ao argumento fluído da defesa do interesse público¹⁹⁷.

Muitas dessas posturas administrativas e judiciais não suportam sérias e firmes contestações, fundadas na supremacia da Constituição e na defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. De fato, esta noção ampliati-va acaba por denunciar um traço de grande fluidez conceitual, que prejudica uma pretensão de construção jurídico-normativa do conceito de interesse

¹⁹⁷ Ultrapassa os limites do presente estudo a abordagem do fenômeno da chamada “análise econômica do direito” (AED), debate que tem assumido representativos contornos no cenário contemporâneo, inclusive com especial destaque na relação com a defesa e promoção dos direitos fundamentais sociais. Para uma visão panorâmica sobre o tema, consultar: PACHECO, Pedro Mercado. *El análisis económico del Derecho*: una reconstrucción teórica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994; PIETRO-PAULO, João Carlos. *Limites de critérios econômicos na aplicação do Direito*: Hermenêutica e análise econômica do direito. 2010. 254 f. Tese (Doutorado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010; ROSA, Alexandre Morais da; LINHARES, José Manuel Aroso. *Diálogos com a Law and Economics*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

público. Mesmo assim, fica evidente que aquela concepção de supremacia do interesse público sobre o particular traz em si uma clara insubsistência enunciativa, uma vez que pressupõe uma estática e abstrata relação de conflito entre interesses que podem perfeitamente compor um harmonioso e conjugado quadro relacional. E mais: estabelece um parâmetro de prevalência abstrata e apriorística a uma situação que, quando conflituosa, acabará por exigir uma ponderação a partir de uma perspectiva concreta.

A perspectiva restritiva do conceito de interesse público (sentido estrito), por sua vez, vincula-se àqueles princípios, valores e objetivos que marcam o conjunto de interesses coletivos e sociais estabelecidos pela ordem normativa constitucional, conjugados em favor da comunidade política e não apenas de um ou outro cidadão individualmente considerado. Estes interesses coletivos e sociais devem ser densificados a partir de um processo de concretização ponderativa, tanto pelo Estado, via suas esferas ponderativas constitucionais, legislativas, administrativas e judiciais, como por todos os demais espaços públicos não estatais de defesa e promoção de interesses coletivos e sociais.

Esta perspectiva jurídico-normativa do conceito de interesse público já permite antever um cenário de possível convivência conflituosa entre interesses coletivos (públicos) e interesses individuais (privados). Um quadro de contraposição que deve ser estabilizado pelo marco normativo (constitucional e infraconstitucional) e pela respectiva via instrumental da ponderação de interesses e não a partir de qualquer parâmetro apriorístico e autoritário de prevalência abstrata do interesse público sobre o privado.

Mas, quer em uma dimensão político-axiológica (sentido amplo) quer ante o parâmetro jurídico-normativo (sentido estrito), não se pode jamais reduzir o conceito de interesse público a uma perspectiva limitada à satisfação de uma medida possível do interesse público naquela situação concreta, no sentido de que alguma prossecução do interesse público já seria o suficiente para legitimar ou justificar o agir administrativo ou determinada decisão judicial. Há uma espécie de imperativo categórico (no sentido kantiano)¹⁹⁸ que impõe a constante e perpétua busca

¹⁹⁸ A noção de “imperativo categórico” é central à filosofia de KANT, sendo mesmo imprescindível para a adequada compreensão da moralidade e da eticidade no seu pensamento. O termo “imperativo” surge na Obra *Fundamentação da Metafísica dos Costumes*, escrita em 1785, com uma disposição funcional e de sentido que pode ser comparada (entendida) àquela dimensão dos “mandamentos bíblicos”. A teoria kantiana refere-se ao “imperativo hipotético” e ao “imperativo categórico”. Aquele representa “a necessidade prática de uma ação possível como meio de alcançar qualquer outra coisa que se quer”. Este, por sua vez, representa uma “ação como objetivamente

pelo nível ótimo de satisfação do interesse público, na sua relação com a máxima concretização ponderativa dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Disso, inclusive, decorre o cimeiro fundamento de legitimação de todos os poderes constituídos e do próprio Estado, a consecução otimizada dos interesses públicos (coletivos e sociais) e privados (individuais) que gravitam na órbita desse sistema aberto de regras e princípios constitucionais.

2.5.2 Algumas questões relevantes sobre o conceito de interesse público: pretensão de universalidade, competência para definição, aplicação em concreto e controle

A partir da construção bidimensional do conceito de interesse público, tanto sob o prisma político-axiológico como na perspectiva jurídico-normativa, algumas questões assumem capital relevância, merecendo uma abordagem mais detida (ainda que não exaustiva): O interesse público pode ser definido a partir de um conceito universal? Quem pode legitimamente definir o que seja o interesse público (conteúdo e significado)? A quem compete aplicar tais definições e determinar sua abrangência? E quais os limites ao controle do conteúdo do interesse público concretamente aplicado?¹⁹⁹

A noção de interesse público, com essa ou outra designação²⁰⁰ (bem comum²⁰¹, interesse geral²⁰²), sempre acompanhou a civilização

necessária por si mesmo, sem relação com qualquer outra finalidade", pelo que somente o imperativo categórico apresenta o "caráter de uma lei prática, ao passo que todos os outros se podem chamar, em verdade, princípios da vontade, mas não leis". Neste sentido, o imperativo categórico kantiano pode ser descrito como o dever de toda a pessoa em agir conforme os princípios que ela deseja que todas as demais pessoas sigam, com base em uma lei moral universal. Na célebre síntese do Filósofo de Königsberg: "Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal". Disso resulta o seguinte imperativo universal: age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, por tua vontade, lei universal da natureza. E o imperativo prático prescreve o seguinte: age de tal modo que possas usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre como um fim em si mesmo e nunca como um meio. Neste sentido, consultar: KANT, Immanuel. **Fundamentação da metafísica dos costumes**. Coleção "Os Pensadores". Tradução de Paulo Quintela. São Paulo, Abril Cultural, 1980. p. 218-223.

¹⁹⁹ Alguns desses questionamentos são apresentados por Muñoz, como preocupações fundamentais que têm interessado à comunidade jurídica na Europa, em especial a alemã. Nesse sentido, ver: MUÑOZ, Guillermo Andrés. **El interés público...**, p. 22.

²⁰⁰ Embora parcela considerável da doutrina e da jurisprudência dos tribunais, bem como, por vezes, o próprio Direito Positivo, tenham indicado uma plena relação de sinóni-

humana. Esse é o entendimento de Rodríguez-Arana Muñoz, para quem desde sempre os homens têm se organizado para questões de interesses comuns, quer locais, quer gerais; quer na defesa de interesses de coletividades profissionais, quer para gerir ou administrar interesses supraindividuais em geral²⁰³.

Por outro lado, ainda que se possa buscar a construção de uma noção de interesse público já na Antiguidade (sobretudo a partir da ideia de bem comum), como já abordado anteriormente, não se pode negar que a sua acentuada centralidade ocorre a partir do advento da Modernidade, associada às construções dos ideais relacionados ao Estado de direito, à separação de poderes, aos conceitos de interesses individuais (privados) e coletivos (públicos), em meio ao substrato político e filosófico no qual germinou o próprio Direito Administrativo moderno²⁰⁴.

Questão de inequívoca pertinência refere-se ao debate em torno do suposto caráter de validade universal do conceito de interesse público, que ostentaria uma noção geral e abstrata da qual seria possível extrair uma ideia de seu conteúdo e significação²⁰⁵. Sobre o tema, cabe recordar

... com o emprego indiscriminado e indistinto de expressões como interesse público, interesse geral, bem comum, utilidade pública, interesse coletivo etc., não se pode olvidar a possibilidade de diferenciação, a partir de parâmetros filosóficos, políticos e de teoria do Estado. Isso poderia, inclusive, contribuir para a construção de um conceito de interesse público afinado com o atual modelo de Estado constitucional de direito. Nesse sentido, consultar: DURÁN MARTÍNEZ, Augusto. **Derechos prestacionales e interés público**. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe; HACHEM, Daniel Wunder (Coord.). **Direito Administrativo e interesse público: estudos em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello**. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 145-149.

²⁰¹ Além do que já foi tratado anteriormente, quando da análise do conceito de bem comum no pensamento político ocidental, para um estudo da ideia de interesse público a partir da noção de bem comum, pode-se consultar: DI PIETRO, **O princípio da supremacia do interesse público...**, p. 86-91.

²⁰² Conforme já referido anteriormente, tem-se o artigo 103, I, da Constituição espanhola de 1978, que dispõe como obrigação da Administração Pública servir com objetividade os interesses gerais. Nesse sentido, consultar: MEILÁN GIL, **Intereses generales e interés público...**, p. 65-88.

²⁰³ RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. **El interés general como...**, p. 35.

²⁰⁴ Além do que já foi tratado anteriormente, quando do debate acerca do nascimento do Direito Administrativo moderno, para uma análise crítica da gênese garantista do Direito Administrativo, consultar: OTERO, **Legalidade e Administração Pública...**, p. 269-282; SILVA, **O contencioso administrativo...**, p. 09-13; BINENBOJM, **Uma teoria do Direito Administrativo...**, p. 09-22. Para uma "crítica da crítica" e o afastamento das ideias de uma gênese autoritária do Direito Administrativo, consultar: GABARDO; HACHEM, **O suposto caráter autoritário...**, p. 155-201.

²⁰⁵ RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, Jaime. **El interés general como...**, p. 36.

o escólio de Dallari, que há mais de duas décadas defendia a impossibilidade de uma “*consideração genérica, prévia e universalmente válida do que seja o interesse público, revelando-se inevitável a avaliação pragmática do que é interesse público. Em cada situação será indispensável fazer a verificação, uma vez que não há um interesse público válido universalmente*”²⁰⁶.

Nada obstante, e partindo de uma peculiar concepção (estritamente normativa) de universalização, se presente a variável essencial de uma comunidade política fundada em um modelo de Estado constitucional e democrático de direito, parece possível defender um caráter universal e abstrato (mas, mesmo assim, não imutável e absoluto) do núcleo conceitual do interesse público, com base, v.g., em pautas assecuratórias comuns ao primado dos direitos humanos fundamentais, sobretudo a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. A universalidade do conceito de interesse público passaria, necessariamente, pelo reconhecimento da primazia dos direitos fundamentais, valores que devem ser colocados acima de quaisquer interesses ocasionais ou contingenciais, acima de quaisquer governos e de seus governantes, acima dos Estados e das próprias pessoas as quais se pretende defender.

Mas a ideia de universalidade do conceito de interesse público, aqui admitida em contornos assaz mitigados, em nada ilide a problemática relacionada à definição da autoridade legitimada para definir o seu conteúdo e significação. Partindo-se da premissa de que em um Estado constitucional de direito vigora o primado da Constituição como norma fundamental do sistema jurídico-político do Estado, não se pode conceber outra autoridade legítima para sua definição que não o Parlamento: enquanto legislador constituinte, a expressão da vontade soberana do povo, para aquelas questões relacionadas à esfera político-constitucional do interesse público; e como legislador infraconstitucional, para aquelas questões ligadas à perspectiva jurídico-administrativa do interesse público (primado da lei)²⁰⁷.

²⁰⁶ DALLARI, Dalmo de Abreu. **Interesse público na contratação das entidades da administração descentralizada**. Suplemento Jurídico da Procuradoria Jurídica do Departamento de Estradas e Rodagem, São Paulo, a. 126, p. 09-15, jan./mar. 1987, p. 15.

²⁰⁷ Nesse sentido, na firme defesa do afastamento da Administração Pública das cercanias que entornam a definição dos interesses públicos, Antunes assim preleciona: “Se, portanto, a Administração encontra, na **realização dos interesses públicos**, o escopo da actividade administrativa (GIANNINI), parece difícil considerar que seja função da Administração proceder à **qualificação do interesse público (primário)**. Se assim fosse, teríamos de admitir que é a própria Administração a decidir o objecto da sua actividade, iludindo o seu carácter instrumental em relação à concreção de um objec-

De fato, o espaço legítimo e originário, por excelência, de definição dos valores e interesses aceitos como válidos em uma dada sociedade não é outro que não a sua Constituição e suas leis. No essencial, não compete à Administração decidir acerca dos interesses públicos, seus conteúdos, limites, meios e recursos necessários à concretização. Sua função é instrumental, de prossecução daqueles interesses já delineados pelo legislador constitucional ou ordinário.

Nesse sentido, em diversos casos a ordem constitucional inclusive define, plena e expressamente, a preponderância de determinado interesse sobre os demais (quer públicos, quer privados), como ocorre, v. g., no caso do art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de “*desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro*”, submetendo o interesse privado (particular/individual) ao interesse público (coletividade). Em outras situações, a Constituição acaba por prever uma ordem limitadora de um determinado direito ou interesse, mas transfere ao legislador ordinário a atribuição de estabelecer os contornos da referida limitação. Isso ocorre, v. g., quando o art. 5º, XXIII, da Constituição Federal determina que “*a propriedade atenderá a sua função social*”, sendo que o seu art. 186 estabelece os requisitos pelos quais restaria cumprida a aludida função social da propriedade, mas deixa para a lei ordinária a fixação dos respectivos critérios e graus de exigência.

Quando a Constituição estabelece uma relação de prevalência de determinado direito ou interesse (nível da ponderação constitucional), não se pode admitir como legítima outra interpretação diversa daquela comprometida com a supremacia constitucional. Da mesma forma, ressaltados os casos de vícios de inconstitucionalidade ou de ponderação de princípios em relação concreta de conflito, há que se reconhecer a prevalência vinculativa das escolhas políticas do órgão legislativo (nível da

tivo pré-constituído. Tal significaria uma relativização inadmissível do princípio da legalidade, a caminho de uma escolha arbitrário-discrecionária do interesse público pela Administração. Se à Administração compete a prossecução do interesse público normativamente predeterminado, não resta outra possibilidade que não seja a de reconhecer que compete ao **legislador** e, portanto, à lei, à luz de critérios constitucionais, avaliar e qualificar, em primeira mão, a relevância de uma necessidade colectiva intensa como susceptível de integrar a noção jurídica de interesse público.[...] importa esclarecer que, quando afirmamos que a qualificação do interesse público específico é obra do legislador, utilizamos esta expressão em sentido amplo. Esta tarefa está, no essencial, fora do alcance da Administração, cuja estranheidade permanece em relação à escolha do objecto e ao escopo da respectiva actividade”. ANTUNES, **O Direito Administrativo...**, p. 42-43.

ponderação legislativa), sob pena, inclusive, de grave ofensa ao próprio princípio democrático e à legalidade administrativa.

Por outro lado, não há como desconsiderar (e isso parece insuprimível) os diversos casos de ausência de parâmetros normativos plenamente definitivos (prévia e conclusiva ponderação constitucional ou legislativa). Da mesma forma, torna-se necessário lembrar os traços comuns de complexidade e indeterminação normativa de certos conceitos jurídicos, além da acirrada disputa entre direitos e interesses que povoam uma ordem constitucional aberta e plural. Todas essas questões levam a reconhecer à Administração Pública uma função instrumental e supletiva de concretização dos conteúdos e conformação ponderativa dos limites da noção de interesse público. Uma atuação sempre vinculada aos parâmetros constitucionais e infraconstitucionais e à consecução otimizada dos direitos e interesses assegurados pela Constituição e pela ordem normativa infraconstitucional.

Mas estas dimensões supletivas e finalísticas jamais poderão ser legitimamente promovidas a partir de qualquer parâmetro vago, autoritário e apriorístico de supremacia do interesse público, e sim, pela via de um agir administrativo fundado em critérios e parâmetros adequadamente justificáveis. Um modelo de ponderação proporcional de interesses, em que são levadas em consideração as circunstâncias e peculiaridades da situação concreta, com base em um processo público, transparente e dialógico de justificação das decisões estatais.

Isso assegura não somente o afastamento de uma justificação *a priori* das escolhas político-administrativas, com base em um totêmico, vazio e incontrolável parâmetro de supremacia do interesse público, impondo também a obrigação de a Administração Pública declinar todas as razões e justificativas de suas escolhas – o que antes vinha acobertado por um arremedo de justificação, baseado nas (tão famosas quanto ocas) “razões de interesse público”. Justificativas que passam a estar submetidas, do ponto de vista jurídico, ao pleno controle externo de legalidade e legitimidade constitucional, pelas instituições constitucionalmente ungidas desta atribuição e, sobretudo, pelo controle político de toda a sociedade (controle social).

A superação da noção de supremacia do interesse público favorece e torna mais efetivo, inclusive, o próprio controle jurisdicional da atividade administrativa, uma vez que impõe ao juiz (guardião da Constituição e das leis) o dever de perquirir acerca da conformação constitucional ou legal das ações administrativas de prossecução do interesse público (atividade submetida e vinculada à Constituição e às leis), mas agora

com base em justificativas e motivações e não limitado ao quase intransponível dogma da prevalência apriorística do interesse público.

No Estado constitucional de direito, os interesses públicos não podem decorrer de uma necessária e constitutiva oposição aos interesses privados, pois é cada vez mais recorrente a relação de sobreposição entre “interesses públicos e privados”. Realmente, o conceito de interesse público confunde-se com os valores indisponíveis assegurados pela Constituição, sob o signo inafastável dos direitos fundamentais e da centralidade do princípio da dignidade da pessoa humana (personalização da ordem constitucional). Não se deve, pois, buscar o interesse público (singular), mas os interesses públicos consagrados no texto constitucional, que inclusive podem apresentar-se entre si conflitantes (ou com outros interesses privados) na conformação do caso concreto, a exigir necessariamente uma adequada e sofisticada ponderação de valores, ainda que não imune a uma elevada dose de instabilidade e insegurança jurídico-política.

O certo é que a Constituição Federal já nasceu em potencial trabalho de parto, para dar vida a um novo Direito Administrativo, filho e súdito inescusável daquela ordem constitucional renovadora, plenamente submetido aos vivificadores mandamentos que gravitam na órbita dos direitos fundamentais e do primado da dignidade humana. Nesse sentido, urge o debate em torno do tradicional princípio da supremacia do interesse público como a pedra de toque do Direito Administrativo, sua desconstrução ou reconstrução, que será a tônica do próximo capítulo, temática que abre a segunda parte desse estudo.

SEGUNDA PARTE

DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO À PONDERAÇÃO DE INTERESSES

Capítulo 3

O PARADIGMA TRADICIONAL DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E SUA NECESSÁRIA SUPERAÇÃO

Algumas das análises empreendidas no capítulo anterior permitem considerar que, assim como a noção jurídica de interesse público é sobremaneira influenciada por fatores políticos, sociais e econômicos, que estão na raiz da construção dos cambiantes modelos de Estado moderno, a pendular relação binomial autoridade/liberdade já esteve claramente acirrada na direção do primado do Estado como guardião e reitor máximo daqueles interesses públicos tutelados. Mas agora se desloca vivamente para o cidadão, a partir da personalização da ordem constitucional, do primado da dignidade humana e da prevalência dos direitos fundamentais. Este é o traço essencial do próprio modelo de Estado constitucional de direito, o que influencia diretamente na construção de um regime jurídico-administrativo²⁰⁸ capaz de dialogar com esta nova estrutura político-normativa.

Se admitida esta relação bipolar autoridade/liberdade como uma noção radical e mesmo genética do Direito Administrativo, enquanto ramo jurídico autônomo e especial, ganha especial relevo o debate sobre

²⁰⁸ As noções de sistema jurídico e de regime jurídico-administrativo serão apresentadas no subitem 5.3.1 do capítulo quinto. Apenas para adiantar, nos limites do presente trabalho, a ideia de regime jurídico adotada é tributária do difundido conceito de sistema jurídico de Claus-Wilhelm Canaris, fundado nas noções de adequação valorativa e a unidade interior da ordem jurídica. Para estudos complementares: CANARIS, Claus-Wilhelm. **Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do Direito**. Tradução de Antônio Menezes Cordeiro. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1996. p. 12-22; FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. **Conceito de sistema no Direito**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. p. 126-130.

os fatores e conjunturas que determinam (ou contribuem para) a oscilação dessa pendular polarização autoridade/liberdade, ou, para ser mais direto, dessa multifária e complexa relação Estado/cidadão.

Com efeito, a peculiar perspectiva do deslocamento da ordem constitucional para um epicentro personalista, fundado no primado da dignidade humana e na prevalência dos direitos fundamentais, deve ser o farol a indicar o caminho a esse (necessariamente) renovado regime jurídico-administrativo, ainda cambiante e em movimento de (re)construção²⁰⁹.

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O delineamento dos contornos do regime jurídico-administrativo, em um conjunto ordenado e coerente de normas jurídicas, ostenta invulgar e inegável relevância, porquanto afeto à própria conformação do Direito Administrativo enquanto disciplina jurídica autônoma. Na abordagem desta problemática, a partir de uma matriz publicista tradicional ao qual o Direito Administrativo ainda está visceralmente ligado, Mello defende a clássica doutrina pela qual o regime administrativo estaria fundado na “*consagração de dois princípios: a) supremacia do interesse público sobre o privado; b) indisponibilidade, pela Administração, dos interesses públicos*”²¹⁰.

A clássica teoria da supremacia do interesse público, que no Brasil vem sendo reproduzida há décadas, de maneira quase automática e sem maiores contestações críticas, será aqui identificada como o para-

²⁰⁹ Ainda que não para concordar integralmente com essa nova ordem jurídico-administrativa, a doutrina jusadministrativista (por assim dizer) tradicional admite a centralidade da pessoa humana nesse novo regime jurídico-administrativo. Por conseguinte, seguem as palavras de Di Pietro: “*Tudo isso se diz para demonstrar que o binômio autoridade/liberdade continua presente no direito administrativo. A tão falada centralidade da pessoa humana tem sido valorizada, com razão, até por força de norma constitucional. Mas não há como acabar com algumas prerrogativas da Administração Pública, simplesmente porque não há como igualar o cidadão com os entes que personificam o poder do Estado. Mesmo nos sistemas jurídicos que não adotam alguns dos institutos próprios do direito administrativo do sistema europeu continental, as prerrogativas públicas estão presentes, como ocorre em relação aos contratos celebrados pela Administração, ainda que o sejam no regime jurídico de direito privado*”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Introdução: existe um novo Direito Administrativo. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coord.). **Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito Administrativo**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 07.

²¹⁰ MELLO, **Curso de Direito Administrativo...**, p. 45.

*digma tradicional*²¹¹. Neste quadrante, segundo a difundida doutrina de Mello, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular é qualificado como “*verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público*”. Nele sustenta-se a “*superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e asseguramento deste último*”²¹². Mas o administrativista pátrio adverte que as prerrogativas e privilégios decorrentes da supremacia do interesse público somente deveriam ser aplicados na exata consecução do interesse público. Não para satisfazer interesses ou conveniências do aparelho estatal ou dos seus agentes, o que tornaria ilegítima a atividade administrativa.

Desse modo, o publicista pátrio retoma a célebre diferenciação alessiana entre interesses públicos primários e interesses públicos secundários, para defender que aqueles não podem ser confundidos com os interesses do Estado, do aparelho da Administração burocrática ou do erário, sendo que “*os interesses secundários do Estado só podem ser por ele buscados quando coincidentes com os interesses primários, isto é, com os interesses públicos propriamente ditos*”²¹³.

Nada obstante, a teoria que funda o regime jurídico-administrativo sob o *paradigma tradicional* do princípio da supremacia do interesse público (*teoria da supremacia*), embora de inegável respaldo e corrente difusão doutrinária, não parece sustentável. Isto se levados a sério os vetores basilares da Constituição Federal e do atual Estado constitucional de direito, sobremaneira assentados na centralidade da pessoa huma-

²¹¹ Importa esclarecer que a noção de *paradigma* empregada é aquela que remonta à célebre obra do filósofo Thomas Samuel Kuhn *A Estrutura das Revoluções Científicas*, aqui deslocada para o ramo das ciências sociais. Segundo Kuhn, existiriam determinadas formas e parâmetros de se entender a ciência, que se afirmariam enquanto paradigmas por um determinado período de tempo, definindo o objeto de análise, as questões relevantes a serem apontadas e as respectivas respostas e suas interpretações e consequências, definindo os contornos de determinado modelo científico. Mas, nesse paradigma científico, pode ocorrer que determinadas questões fiquem sem uma resposta satisfatória ou recebam soluções anômalas, o que pode acarretar uma espécie de *crise do paradigma vigente*, com a construção de novas teorias destinadas a remodelar o objeto e os parâmetros daquelas respostas insatisfatórias. Quando as teorias de contestação acabam por se consolidar, enquanto modelo científico, ocorre a chamada *mudança de paradigma*, com uma nova concepção acerca daquele objeto científico. Nesse sentido: KUHN, Thomas Samuel. **A estrutura das revoluções científicas**. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. Nesse mesmo sentido: BINENBOJM, **Uma teoria do Direito Administrativo...**, p. 26-29.

²¹² MELLO, **Curso de Direito Administrativo...**, p. 58.

²¹³ *Ibidem*, p. 56.

na, na prevalência dos direitos fundamentais, na ponderação proporcional de interesses e no modelo de Administração Pública democrática, aqui designados por *paradigma emergente*²¹⁴.

Neste quadrante insere-se o presente capítulo, quando serão apresentadas as linhas gerais de justificação do paradigma tradicional da teoria da supremacia, seguindo-se as críticas sob vários aspectos, que demonstram a sua incongruência e inadequação para responder à problemática contemporânea. Sobreleva a necessidade e a urgência na construção de um novo paradigma, o paradigma emergente da Administração Pública democrática e do Direito Administrativo fundado na promoção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Estes os contornos do debate que será travado a seguir.

3.2 A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR E SEUS FUNDAMENTOS

A noção-chave da teoria da supremacia do interesse público pode ser recuperada naquela originária concepção de desequilíbrio e desigualdade jurídico-política entre o Estado e os cidadãos, justificada a partir da prevalência do interesse geral (público) sobre as aspirações individuais (privadas). Por isso, o aparato estatal deveria estar ungido por um regime de prerrogativas e sujeições, necessários à fiel consecução das suas finalidades.

Nesse sentido, assim parecia ser o pensamento de Hely Lopes Meirelles, para quem a tônica daquela desigualdade originária entre o Estado e os administrados (na conhecida linguagem do autor) estaria assentada na “*supremacia do Poder Público sobre os cidadãos, dada a prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais*”²¹⁵.

²¹⁴ A expressão *paradigma emergente* é aqui empregada em um sentido aproximado àquele conferido pela teoria de Boaventura de Sousa Santos, quando o sociólogo português sugere a emergência de um processo de transformação paradigmática, no que toca ao fazer científico, a partir de um novo paradigma, não apenas científico mas também (sobretudo) de cunho social e emancipatório. Nesse sentido: SANTOS, Boaventura de Sousa. **A crítica da razão indolente**: contra o desperdício da experiência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2000. No mesmo sentido aqui empregado, consultar: LIMA, Gabriel de Araújo. Teoria da supremacia do interesse público: crise, contradições e incompatibilidade de seus fundamentos com a Constituição Federal. **A&C Revista de Direito Administrativo e Constitucional**. Belo Horizonte, a. 9, n. 36, p. 123-153, abr./jun. 2009, p. 127.

²¹⁵ MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo brasileiro**. 38. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 108-109.

3.2.1 A construção histórica da noção de supremacia do interesse público

A doutrina que relaciona as raízes da teoria da supremacia ao surgimento oitocentista do Direito Administrativo, enquanto disciplina autônoma e especial, derogatória do Direito Comum, não é compartilhada por Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Para ela, as bases dessa teoria da supremacia seriam muito mais ancestrais e remontariam à própria concepção aristotélica de que o todo vem antes das partes (concepção organicista)²¹⁶, pelo que a totalidade teria fins não redutíveis ao somatório dos fins dos membros singulares que a compõem e o bem da totalidade²¹⁷.

Na mesma senda, a administrativista pátria procura relacionar a noção de supremacia do interesse público com a ideia tomista de bem comum, pela qual o homem (ser social) procuraria não somente o seu bem mas também aquele do grupo a que pertence, cabendo ao Estado perseguir o bem comum, aquilo que justifica a própria reunião da comunidade política. Segundo adverte Di Pietro, esta noção de bem comum vinculada a um contexto de solidariedade social sofreria um profundo abalo com o triunfo do individualismo e das teses contratualistas e liberais do século XVIII, que teve seu ápice com a Revolução Francesa²¹⁸.

Por outro lado, apesar de impregnado dos ventos liberal-individualistas do século XVIII, o nascente Direito Administrativo teria realmente surgido com claros “*traços de autoritarismo, de supremacia sobre o indivíduo, com vistas à consecução de fins de interesse público*”. Mas a noção de supremacia do interesse público sobre o particular somente ganharia forte envergadura e efetiva conformação com a recuperação da centralidade da ideia de bem comum (influenciado pela Doutrina Social da Igreja), já no período do Estado social de direito. Um modelo marcado pelo agigantamento do aparato e da atuação estatal em todos os setores, “*com o objetivo de corrigir a profunda desigualdade social gerada pelo liberalismo*”²¹⁹.

²¹⁶ O debate acerca da concepção organicista de interesse público e sua incompatibilidade com a ordem constitucional brasileira será retomado abaixo. Sobre o tema, consultar: SARMENTO, Daniel. Interesses públicos vs. Interesses privados na perspectiva da teoria e da filosofia constitucional. In: _____. **Interesses públicos versus interesses privados**: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 52-58.

²¹⁷ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. O princípio da supremacia do interesse público. **Revista Interesse Público**. Belo Horizonte, a. 11, n. 56, p. 35-54, jul./ago. 2009, p. 36.

²¹⁸ DI PIETRO, **Discrecionalidade administrativa...**, p. 211.

²¹⁹ DI PIETRO, **O princípio da supremacia do interesse público...**, p. 42.

Ainda que sofisticada esta recuperação política e histórico-evolutiva, não parece que seja possível cogitar-se propriamente de uma ideia de supremacia do interesse público sobre o privado, com os contornos conferidos pelo chamado paradigma tradicional, antes do advento do próprio Direito Administrativo moderno. Na forma como está posto pelo paradigma tradicional, o terreno fértil para a teoria da supremacia foi mesmo aquele período de transição entre o Estado liberal-abstencionista e o Estado social de direito.²²⁰

Conforme visto alhures²²¹, é seguro que se possa reconstruir (o que parece inequívoco) uma genealogia aristotélico-tomista de bem comum como raiz política ancestral do moderno conceito de interesse público, e até quicá uma ideia de primado do público. Mas disto não se retira que uma noção jurídica (mais ou menos estável e acabada) de supremacia do interesse público tenha atravessado a História da Humanidade no Ocidente. Até porque a histórica noção de bem comum guarda contornos político-filosóficos consideravelmente diversos daqueles da moderna teoria jurídico-política da supremacia, sobretudo nos moldes consagrados já às portas do regime administrativo comum ao Estado social de direito, marcada por um modelo de Estado prestacionista e intervencionistas sem precedentes históricos comparativos.

De fato, a noção jurídica de supremacia do interesse público sobre o privado decorre da construção do Direito Administrativo sob o signo da autoridade. Mais do que uma disciplina normativa de defesa da liberdade do indivíduo em relação ao Estado e de instrumento de limitação dos poderes estatais, já na sua origem o moderno Direito Público foi forjado sob o pálio da autoridade, com a construção de um regime normativo derogatório do Direito Comum e fundado em prerrogativas em muito aniquiladoras do primado da igualdade das relações jurídicas (gênese autoritária).

Esta genética autoritária vinha justificada a partir da ideia de imperiosa necessidade para o cumprimento das finalidades do Estado liberal-abstencionista (garantia das liberdades individuais instrumentais à tutela do bem-estar geral). Porém, da construção do Estado social de direito, com a notável ampliação das finalidades materiais do aparato estatal, resultou a correspondente hipertrofia da teoria da supremacia. Consolidado o Estado como o tutor máximo e absoluto do interesse público,

²²⁰ Este parece também ser o pensamento de Bobbio. Nesse sentido: BOBBIO, **Estado, governo, sociedade...**, p. 25.

²²¹ No capítulo primeiro, sobretudo nos subitens 1.2.1 e 1.2.2, há uma breve recuperação política do conceito de bem comum, a partir da filosofia aristotélico-tomista.

com a exponencial ampliação das suas finalidades prestacionistas, consequentemente, a noção de supremacia do interesse público sobre o particular também se agigantou, tomando feições de síntese fundamental e verdadeira pedra de toque de todo o moderno Direito Público.

Inclusive, esta vinculação da teoria da supremacia à construção e consolidação do Estado social de direito induz parte da doutrina a uma postura de defesa apaixonada da teoria da supremacia, pensando que assim defende um modelo social e democrático de Estado. Na verdade, uma atenta e realista análise da teoria da supremacia e do Estado social de direito jamais admitirá os avanços do Estado social como relacionados, ainda que indiretamente, à teoria da supremacia, ou mesmo que esta tenha destacado relevo instrumental à consecução daquele.

Realmente, a aplicação do princípio da supremacia do interesse público não tem lugar destacado na teoria do Estado e na política, como justificativa instrumental à ampliação de direitos sociais e coletivos. A justificação dessas políticas prestacionistas sempre foi construída com base em uma sutil e instável composição de interesses entre as classes de comando (político e econômico) e as massas. A teoria da supremacia sempre foi mais usada, isso sim, como princípio de plantão, a justificar aquelas “práticas injustificáveis” do Estado, a evitar o constrangimento e o controle político e jurídico-judicial de setores da classe estatal dirigente e seus infiltrados, a conferir uma aparente racionalidade jurídica a desmandos estatais (quase sempre) setorizados e pouco, ou quase nada, relacionados a razões (pautas) de efetivo interesse público.

Mas é recorrente, porém, o pensamento que leva parte da doutrina a qualificar (ou desqualificar, de forma aparentemente pejorativa) as teorias do chamado paradigma emergente como concepções neoliberais, na medida em que estariam comprometidas com o retorno do primado das liberdades individuais e com o abrandamento daquela noção de bem comum que fundamenta o modelo de Estado social e democrático de direito. Di Pietro, que vê nessas teorias do paradigma emergente claros contornos de neoliberalismo, chega a dizer que essas teorias críticas partem de uma *dimensão de supremacia do interesse público que “jamais teve aplicação. Exagera-se o seu sentido, para depois combatê-lo, muitas vezes de forma inconsequente, irresponsável e sob falsos pretextos”*.²²²

Mais abaixo serão retomadas essas questões. Mas convém ressaltar, desde logo, que a crítica ao paradigma emergente, taxado de neoliberal e inconciliável ao modelo de Estado social e democrático de direito, não encontra sustentação nem política e nem filosófica. Ainda que fun-

²²² DI PIETRO, **O princípio da supremacia do interesse público...**, p. 45.

damentadas e fruto das melhores intenções de seus defensores, não são estas as bases políticas ou filosóficas do paradigma emergente, que está sim, fundado em uma matriz claramente personalista, centrada na dignidade humana e na defesa dos direitos fundamentais (individuais e coletivos).

Totalmente diferente deste paradigma personalista, as teorias de matiz neoliberal sempre se mostraram muito mais preocupadas com a defesa do capital (liberdade de mercado) do que com as liberdades individuais do sujeito, relegando um enorme e numeroso universo de pessoas (camada mais pobre e humilde) a uma inequívoca condição de abandono e derrota humanista.

Mas vale insistir que, conforme advertido acima, não há como relacionar e (muito menos) atribuir quase que romanticamente os avanços do Estado social na concretização dos direitos sociais ao paradigma tradicional da teoria da supremacia. Mormente no Brasil, onde a *práxis*²²³ da noção de supremacia do interesse público jamais esteve efetivamente empregada na promoção ou proteção dos “valores da democracia, da república, da legalidade e/ou do Estado Social”²²⁴.

3.2.2 A construção jurídica do princípio da supremacia do interesse público

Partindo agora para o debate de contornos mais jurídicos, segundo a doutrina de Mello, a supremacia do interesse público sobre o privado ostentaria legítimo *status* constitucional de princípio implícito da Constituição Federal, podendo ser dela extraído enquanto decorrência direta do Estado de direito e do próprio sistema constitucional como um todo, transparecendo um caráter universal e representando um “*princípio geral de Direito inerente a qualquer sociedade*”²²⁵.

Mais do que isso: na verdade, a teoria da supremacia alcança uma condição de princípio constitucional “diferenciado”. Mas por que diferenciado? Porque, conforme já dito, a supremacia do interesse público

²²³ A ideia de *práxis* aqui mencionada é aquela oferecida por Leandro Konder, no sentido de entender a prática e a teoria como interligadas (interdependentes). A teoria como um momento necessário da *práxis*, que para se tornar mais humana, precisa ser promovida por um sujeito mais livre e mais consciente. Isso permite reconhecer que é a atividade que precisa da teoria. Sobre o tema, consultar: KONDER, Leandro. *O futuro da filosofia da práxis*: o pensamento de Marx no século XXI. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 115-116.

²²⁴ LIMA, Teoria da supremacia do interesse público..., p. 130.

²²⁵ MELLO, Curso de Direito Administrativo..., p. 95-96.

é apresentada e difundida como “verdadeiro axioma” do Direito Público, uma proposição normativa autoevidente e aceita por todos, inclusive não sujeita ao debate jurídico ou qualquer tipo de argumentação demonstrativa.

Conquanto respeitável e amplamente difundida, parece claro que essa teoria da supremacia enquanto axioma (dogma) ressoa muito mais retórica do que normativa, revelando-se de sentido jurídico bastante rarefeito. Aliás, ainda que pareça contraditório, pelo visto a única forma de aceitação da validade desse fundamento axiomático da prevalência abstrata e apriorística do interesse público seria a existência de uma norma constitucional expressa. Mas isso não ocorre na atual ordem constitucional, pois uma norma com este conteúdo traria um elevadíssimo *deficit* de coerência lógica e concordância interna ao sistema constitucional, sobretudo na relação com o princípio da dignidade humana e a teoria dos direitos fundamentais. Porém, é certo que, se expressamente normatizado na Constituição, não seria necessário recorrer à retórica axiomática, deslocando-se a problemática para o campo da hermenêutica constitucional.

Malgrado a inexistência de uma norma (regra ou princípio) expressa que assegure a supremacia abstrata do interesse público sobre o particular, poder-se-ia defender o seu *status* constitucional como uma norma implícita, decorrente da própria ordem jurídico-constitucional, não mais sob aquela qualificação axiomática. Esta empreitada é assumida por Fábio Medina Osório, para quem haveria na Constituição Federal um princípio implícito da supremacia do interesse público. Tal princípio estaria assentado na existência de uma série de dispositivos constitucionais que protegem vários bens coletivos e restringem direitos individuais, o que legitimaria o regime de normas de privilégio conferido à Administração Pública para a consecução de seus fins²²⁶.

Nada obstante a bem empenhada argumentação, não parece que seja possível extrair da Constituição Federal uma norma (regra ou princípio) que assegure a prevalência abstrata do interesse público sobre o particular. Ademais, não se pode admitir como válida a tese de que o conjunto de prerrogativas/privilégios da Administração Pública possa ser, *a priori*, legitimado a partir de uma noção (assim pouco subsistente) de supremacia do interesse público. Isso dependerá sim, do conjunto de normas (regras e princípios) constitucionais e infraconstitucionais vigentes, aplicados segundo aqueles parâmetros e critérios consagrados pela hermenêutica contemporânea.

²²⁶ OSÓRIO, Fábio Medina. Existe uma supremacia do interesse público sobre o privado no Direito Administrativo brasileiro? *Revista de Direito Administrativo*. São Paulo, n. 220, p. 69-107, 2000, p. 87-91.

3.2.3 Os fundamentos da corrente reconstrutivista do princípio da supremacia do interesse público

Mesmo que ainda sob os auspícios do paradigma tradicional da teoria da supremacia, quando Osório sustentava, em 2000, a existência de um princípio constitucional implícito de supremacia do interesse público, já não o fazia naqueles exatos contornos da doutrina clássica, mas a partir de um primeiro ensaio reconstrutivista de seus pressupostos e limites teóricos. A partir de uma concepção de interesse público como um valor direcionador da Administração Pública, naquela oportunidade o autor já reconhecia a incompatibilidade de um princípio de prevalência radical e apriorística do interesse público, determinante da invariável e absoluta preponderância de interesses públicos em detrimento de interesses privados. Deixava, inclusive, o alerta de que um princípio de prevalência, assim concebido, seria impensável se contrastado com o conjunto de garantias e direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal²²⁷.

Anos mais tarde, precisamente em 2005, a revisão reconstrutivista da teoria da supremacia foi retomada por Barroso, com base em uma versão fraca do princípio²²⁸, partindo do resgate da distinção alessiana do interesse público em primário e secundário: aquele como a razão de ser do Estado e a síntese das finalidades que a ele cabe promover (justiça, segurança e bem-estar social); este descrito como o interesse da pessoa jurídica de Direito Público parte de uma determinada relação jurídica. Desta forma, somente o interesse público primário é que desfrutaria de supremacia (*prima facie*), porquanto não seria passível de ponderação, funcionando ele próprio como parâmetro de ponderação. Por outro lado, jamais seria possível atribuir supremacia (abstrata) ao interesse público secundário sobre o interesse particular, uma colisão que deverá ser solucionada a partir da ponderação entre os interesses em conflito, com base nas circunstâncias fáticas e jurídicas existentes²²⁹.

Para amparar sua proposição, Barroso reconstrói a definição de interesse público a partir da conciliação constitucionalizada entre interesses coletivos e individuais, verdadeira pauta de conformação de todas as relações jurídicas e sociais (dos particulares entre si, deles com as pessoas de Direito Público e destas entre si). O interesse público primário consistiria “na melhor realização possível, à vista da situação concreta a ser

²²⁷ *Ibidem*, p. 65-66.

²²⁸ A expressão é de BINENBOJM. Nesse sentido: BINENBOJM, *Uma teoria do Direito Administrativo...*, p. 101.

²²⁹ BARROSO, *Prefácio...*, p. xiii-xv.

apreciada, da vontade constitucional, dos valores fundamentais que ao intérprete cabe preservar ou promover”²³⁰.

Mas mesmo esta versão fraca da teoria da supremacia também não está imune a críticas de envergadura. Primeiro, do ponto de vista jurídico-normativo, há que se questionar acerca da utilidade conceitual de uma noção de interesse público assim abrangente e totalizante. Também, convém ressaltar que esta definição abandona aquela teoria da prevalência abstrata e apriorística, sendo que agora o interesse público primário somente seria revelado após um exercício (juízo, arbitramento) de ponderação concreta entre interesses individuais e coletivos, a partir dos elementos fáticos e normativos reveladores do interesse preponderante. Mas, neste caso, não haveria qualquer justificativa lógica na existência de um princípio que, em outras palavras, dissesse que o que prepondera preponderará!

Nesta quadra, parece correta a crítica de Binjenbojm quando afirma preferir a ponderação proporcional como parâmetro definidor do interesse público *in concreto*, pois um “*princípio que se presta a afirmar que o que há de prevalecer sempre prevalecerá não é um princípio, mas uma tautologia*”. De fato, o “*problema teórico verdadeiro, para o direito administrativo, não é a prevalência, mas o conteúdo do que deve prevalecer*”²³¹.

Outra tentativa de reconstrução do princípio da supremacia do interesse público, também sobre bases mais flexíveis do paradigma tradicional, vem proposta por Alice Gonzales Borges, que, a exemplo de Mello e Barroso, parte da noção alessiana de interesse público primário. Para levar a cabo seu intento reconstrutivista, apresenta uma peculiar (para não dizer complicada) noção de interesse público, profundamente vinculado a aspectos quantitativos comuns a um genuíno princípio majoritário (regra da maioria)²³². Defende que em um Estado democrático não se pode en-

²³⁰ *Ibidem*, p. xvi.

²³¹ BINENBOJM, *Uma teoria do Direito Administrativo...*, p. 102.

²³² A título ilustrativo, ainda que a sua preocupação seja voltada à justificação judicial dos casos difíceis (teoria da argumentação jurídica), o jurista finlandês Aulis Aarnio oferece interessantes reflexões sobre o princípio majoritário, a partir da sua difundida noção de Comunidade Jurídica I e II. A *Comunidade Jurídica II* seria um conceito ideal, semelhante ao famoso *Juiz Hércules* dworkiniano, usado para medir a racionalidade da interpretação jurídica, já que “nela se refletem de maneira mais clara as relações entre o Direito, a sociedade, as questões morais e políticas, e em torno delas giram as expectativas sociais de certeza e segurança jurídica”. Por conseguinte, a *Comunidade Jurídica I* seria formada por todos os juristas profissionais e as demais pessoas envolvidas com os assuntos jurídicos, portanto, um auditório concreto que existe na prática jurídica, ao passo que a *Comunidade Jurídica II* seria formada por todos

tender pela imposição coativa do interesse público sobre o individual, mas pela sua predominância enquanto interesse majoritário. Interesses públicos e privados conflitantes ou não coincidentes seriam qualitativamente iguais e respeitados, havendo a natural preponderância do interesse público majoritário, que nada mais seria do que um interesse individual coincidente com o da maioria dos membros da sociedade. Portanto, quando alijado ou substituído um direito individual como resultado da prevalência de um interesse público, aquele deve ser “compensado pela perda de seus direitos e interesses, mediante sua equitativa conversão em outro valor equivalente”²³³.

Na verdade, Borges sustenta a ideia de que entre interesses públicos e privados não existiria qualquer distinção qualitativa de grau (superioridade), mas somente quantitativa (interesse público majoritário). Os interesses particulares figurariam como uma dimensão do interesse público, muitos deles, inclusive, no seu mais elevado grau possível, porquanto correspondentes a direitos fundamentais do indivíduo. Assim, define interesse público como “o somatório de interesses individuais coincidentes em torno de um bem da vida que lhes significa um valor, proveito ou utilidade de ordem moral ou material, que cada pessoa deseja adquirir, conservar ou manter em sua própria esfera de valores”²³⁴.

Sob tais balizas, a administrativista pátria sustenta a manutenção/reconstrução do princípio da supremacia do interesse público, mas

aqueles que se comprometam com as regras e princípios da racionalidade discursiva (auditório ideal). Assim, para tentar resolver o problema dos casos difíceis e da pluralidade de soluções corretas, Aarnio sustenta que uma das possíveis soluções seria o recurso ao princípio da maioria, situação em que uma decisão justificada por razões apropriadas, em última análise, seria aquela apoiada pela maioria da *Comunidade Jurídica II*. Mas esse princípio majoritário é dosado por um caráter contrafático – exige-se a legitimação por meio de um procedimento racional ideal, que respeite todas as regras e exigências da racionalidade discursiva, o que impõe sejam levadas em consideração as opiniões das minorias nos processos de tomada de decisão, até porque o que deve prevalecer nessa sociedade ideal é a força do melhor argumento. Nesse sentido: AARNIO, Aulis. **Derecho, racionalidad y comunicación social: ensayos sobre Filosofía del Derecho**. México: Fontamara, 1995, p. 62; AARNIO, Aulis. **La tesis de la única respuesta correcta y el principio regulativo del razonamiento jurídico**. Traducción de Josep Aguiló Regla. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Alicante, n. 8, p. 23-38, 1990, p. 33-38. Para maiores estudos sobre a teoria de Aarnio e sua ideia de resposta correta para os casos difíceis, consultar: CRISTÓVAM, Colisões entre princípios..., p. 261-265; DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. **A justificação do Direito e a sua adequação social**: uma abordagem a partir da teoria de Aulis Aarnio. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002.

²³³ BORGES, Alice Gonzales. Supremacia do interesse público: desconstrução ou reconstrução? *Revista de Direito do Estado*, a. 1, n. 3, p. 137-153, jul./set. 2006, p. 142-144.

²³⁴ *Ibidem*, p. 143.

remete sua concretização a um procedimento de ponderação racional (proporcionalidade), entre os interesses acaso conflitantes, de modo a assegurar “uma solução ótima, na qual cada um deles obtenha a maior realização possível”. Segundo defende, quando o Direito Administrativo erige na supremacia do interesse público – enquanto “habitual (mas não absoluta, nem eterna) prevalência do querer valorativo majoritário dos interesses da sociedade – o (único) fundamento e justificativa para o exercício das chamadas prerrogativas de potestade pública, é para manter o mínimo de estabilidade e ordem necessária para a vida em sociedade”²³⁵.

Outra interessante proposta reconstrutivista é trazida por Iuri Mattos de Carvalho, para quem o princípio da supremacia do interesse público, dissociado dos interesses estatais, jamais se prestaria a justificar atos abusivos do Estado, pelo que deveria haver cuidado com uma proposta desconstrutivista, que “ao invés de um avanço na direção de uma Administração Pública mais democrática poderia servir de justificção jurídica para a colonização do interesse público por interesses privados”²³⁶.

Firme no entendimento de que um conceito de interesse público adequado ao “pluralismo da sociedade contemporânea precisa revelar a multiplicidade de interesses que devem ser levados em consideração, pelo agente público, no exercício da competência discricionária”, Carvalho sustenta que o conceito de interesse deve ser redefinido a partir do compromisso e da vinculação da Administração Pública com a satisfação dos direitos fundamentais. Uma noção de interesse público não descolado da sua perspectiva histórica (relatividade) e nem apriorística e abstratamente aferível. Interesse público como o resultado de um procedimento vinculado à concretização dos direitos fundamentais, o “resultado do procedimento de determinação da medida administrativa que melhor atenda a realização dos direitos fundamentais (interesses coletivos e direitos individuais), levando-se em consideração o caso concreto”²³⁷.

Deste modo, a pauta de aferição do interesse público, enquanto resultado de um procedimento de realização dos direitos fundamentais (individuais e coletivos), estaria fundada em um modelo racional-ponderacionista, a partir dos contornos da proporcionalidade. Como conse-

²³⁵ *Ibidem*, p. 152-153.

²³⁶ CARVALHO, Iuri Mattos de. O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado: parâmetros para uma reconstrução. *Revista Diálogo Jurídico*. Salvador, n. 16, p. 01-15, maio/ago. 2007, p. 02. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/supremacia_do_interesse_p%C3%BAblic_iuri_carvalho.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2014.

²³⁷ *Ibidem*, p. 08-09.

quência, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado seria relegado a uma perspectiva exclusivamente formal. Uma sensível reconfiguração daqueles seus primevos contornos de princípio de precedência abstrata e apriorística, agora definido como normas de atribuição de competência “para a Administração Pública constituir obrigações ou alterar relações jurídicas por meio de ato unilateral, que devem ser respeitados na maior medida possível, levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e jurídicas”²³⁸.

Com efeito, as propostas reconstrutivistas de Borges e Carvalho são sedutoras e efetivamente avançam em alguns aspectos. Ambas têm pontos de intersecção, sobretudo quando afirmam a prevalência dos direitos fundamentais, ainda que Borges reconduza os direitos fundamentais a sua própria noção totalizante de interesse público. Outra contribuição importante vem da flexibilização do estático e endurecido coração do paradigma tradicional, com o reconhecimento da centralidade de uma teoria ponderacionista comum ao paradigma emergente. Mas o fazem, lamentavelmente, mantendo variadas e insuprimíveis incongruências.

Não se pode esquecer que, quando há uma autêntica crise de paradigmas, é sobremaneira difícil buscar uma via de conciliação intermediária, a partir da congregação daquelas duas dimensões teoricamente conflitantes, sem que disso decorram algumas indesejáveis anomalias e efeitos colaterais (incoerências). Em outras palavras, para lembrar aquela máxima do Evangelho de Jesus Cristo, não se pode servir a dois senhores²³⁹. Há aqui uma regra inescapável: para o novo nascer em plenitude, o velho terá que ser descontinuado e superado.

Uma primeira objeção que pode ser dirigida àquela proposta reconstrutivista de Borges refere-se ao seu próprio conceito de interesse público, enquanto interesse majoritário decorrente do somatório dos interesses individuais, que nele encontrariam a projeção de suas próprias aspirações. Aqui voltam todas aquelas conhecidas críticas ao recurso à regra da maioria e ao primado dos acordos majoritários formados no seio da comunidade política. A crítica decorre do seu radical *deficit* de legitimação democrática, forjado quase sempre a partir do desrespeito às minorias e seus interesses, como são radicais exemplos os nefastos resultados registrados pela recente História da Humanidade

²³⁸ *Ibidem*, p. 11-14.

²³⁹ Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 24: “Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas” (Mt 6, 24). MATEUS. In: A Bíblia Sagrada. Tradução ecumênica. São Paulo: Paulinas, 2002.

(Stalinismo, Nazismo, Fascismo etc.). Isso sem contar a profunda dificuldade de estabelecer um princípio majoritário, quer ideal-objetivo quer pragmático, como fator de solução de conflitos entre princípios, valores ou interesses contrapostos²⁴⁰.

Situação um pouco menos traumática decorre da noção de interesse público proposta por Carvalho, como resultado do procedimento de ponderação de direitos fundamentais (interesses individuais e coletivos contrapostos). Mesmo assim, disso resultam semelhantes objeções, por conta do nítido caráter totalizante (político-axiológico) da ideia de interesse público como resultado de um procedimento de concretização de direitos fundamentais, sem uma adequada preocupação em estabelecer um conceito de interesse público submetido a uma perspectiva jurídico-normativa.

Mas há outro ponto que reclama reflexão, o fato de essa noção de interesse público ser funcional e não conceitual. Procura mais explicar como a Administração Pública chegaria a uma decisão adequada (concretização de direitos fundamentais contrapostos) e não, propriamente, oferecer um conceito objetivo de interesse público compatível com a teoria da supremacia do interesse público.

Outra objeção, ainda sobre a proposta conceitual de interesse público de Borges, mas que por outras vias serve também à proposta funcionalista de Carvalho, relaciona-se à rarefeita utilidade de um conceito

²⁴⁰ De fato, não se pode negar a enorme dificuldade de estabelecer, no discurso jurídico contemporâneo, as bases para um modelo de princípio majoritário, como critério racional de ponderação entre interesses contrapostos. Aqui, interessa considerar a ideia de que o consenso comunitário (estabilidade social), fático ou ideal, é o que se busca em uma sociedade dinâmica, aberta, complexa e plural como a brasileira, que tem seus valores, princípios e interesses fundados em uma ordem constitucional ainda em construção cultural, política e jurídica. Nesse sentido, embora esteja a discutir a problemática dos critérios para alcançar a decisão judicial razoável dos casos de conflitos entre princípios (casos difíceis), sustenta o jusfilósofo espanhol Manuel ATIENZA que o recurso ao *argumento majoritário* (regra da maioria), embora passível de aplicação, acarreta alguns sérios problemas. Primeiro, importa saber o que se deve entender por comunidade? O tribunal que deve decidir o caso, os tribunais de um país, a doutrina, a população diretamente afetada pela decisão, o conjunto da sociedade? Trazendo para o centro do debate aqui travado, a Administração Pública é quem deve decidir em concreto qual interesse prepondera? Na prática, podem surgir (e surgem) diversos acordos majoritários contrapostos entre si (interesses em conflito). Segundo, não se pode identificar de plano “opinião razoável” com “opinião majoritária”, sendo temerária e até desarrazoada a exclusão *a priori* de uma decisão alinhada com o consenso fático minoritário. Nesse sentido: ATIENZA, Manuel. **Para una razonable definición de “razonable”**. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Alicante, n. 4, p. 189-200, 1987, p. 197.

de interesse público que não reconheça qualquer diferenciação qualitativa com o interesse privado. Ora, se a proposta de Borges foi bem entendida, o interesse público decorreria da conjugação dos interesses individuais, a partir de um critério majoritário. Nesse sentido totalizante, em última análise, tudo seria assim qualificado, na medida em que o interesse individual nada mais representaria do que o interesse público potencialmente elegível pelo critério majoritário. Mas qual o resultado de um conceito assim abrangente, que não o de submeter todos os direitos e interesses privados a uma instável e (na prática) estatalizada relação jurídico-política? Aqui parece claro o perigo da desconstrução daquela insuprimível perspectiva da esfera do indivíduo (legada pela Modernidade) e de sua parcela de autonomia política, jurídica, social e ética.

Em uma terceira crítica, decorrente desta última, poder-se-ia também indagar qual a base lógico-teórica que ainda sustentaria esse “repaginado” princípio da supremacia do interesse público, se, do ponto de vista conceitual, todos os interesses estariam albergados naquela noção-chave? Se tudo converge à noção de interesse público, qual o sentido em sustentar a sua primazia? Se o Deus cristão é uno e se não há outro além Dele, qual o sentido de um mandamento dirigido aos cristãos que diga “*Adorarás somente ao senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto*”?²⁴¹ A consequência tautológica e a incoerência lógica parecem inequívocas, o que denuncia um caráter muito mais simbólico nessa proposta continuísta do que uma decorrência lógico-conceitual.

Tanto que Carvalho, para se manter fiel à corrente reconstrutivista do paradigma tradicional, acaba por reduzir drasticamente a noção de princípio da supremacia do interesse público, submetido a uma perspectiva formal de norma de atribuição de competência. Por meio dela, a Administração Pública estaria ungida das prerrogativas unilaterais de constituição de obrigações e alteração de relações jurídicas, limitadas à justificação decorrente da ponderação das circunstâncias fáticas e normativas em concreto.

De fato, no momento em que se retiram as qualidades de norma impositiva de prevalência objetiva (*prima facie*) e apriorística da supremacia do interesse público, traços fundantes daquele paradigma tradicional, passando-se a admitir como conciliável com a teoria da ponderação, o resultado é a profunda desnaturação das suas estruturas conceituais. Isso, inclusive, põe em descrédito a sua capacidade de figurar como centro de justificação do regime jurídico-administrativo. Se a supremacia do

²⁴¹ Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, versículo 10 (Mt 4, 10). MATEUS. In: *A Bíblia Sagrada*. Tradução ecumênica. São Paulo: Paulinas, 2002.

interesse público somente ocorrerá em concreto, realmente já não existe (enquanto tal) aquele tradicional princípio de supremacia. Nem sequer seria necessário, já que, em última análise, tudo remeteria à noção totalizante de interesse público.

Em um modelo de Estado constitucional de direito, fundado no primado da dignidade humana e na prevalência dos direitos fundamentais, o que sustenta qualquer relação jurídica (pública ou privada) é a ordem político-normativa encartada na Constituição. Assim, reluzem os legítimos interesses públicos (sociais e coletivos) e particulares (individuais) que compõem o complexo universo jurídico de uma dada comunidade política, iluminados pela ampla constelação de normas constitucionais conformadoras, ao que se somam aqueles outros corpos normativos ordinários, se afinados à ordem constitucional.

Portanto, qualquer prerrogativa administrativa só será legítima se, e somente se, parametrizada com essa ordenação constitucional, e não porque fundada em uma concepção abstrata (quase totêmica) de supremacia do interesse público sobre o particular, ou mesmo de uma noção fraca (flexível) de supremacia: quer enquanto base (tautológica) de prevalência a partir de um conceito totalizante de interesse público; quer como norma formal de atribuição de competência.

3.3 A CRÍTICA À TEORIA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E A SUPERAÇÃO DO PARADIGMA TRADICIONAL

A construção desse novo regime jurídico-administrativo, marcado pela matriz constitucional de personalização e prevalência dos direitos fundamentais, deve assentar no princípio da dignidade da pessoa humana, no Estado democrático de direito²⁴² e no princípio republicano²⁴³, a

²⁴² O estudo mais aprofundado do princípio democrático será realizado no subitem 6.3.2 do capítulo sexto. Para uma visão panorâmica das teorias da democracia, pode-se consultar: CUNNINGHAM, Frank. *Teorias da democracia*: uma introdução crítica. Tradução de Delamar José Volpato Dutra. Porto Alegre: Artmed, 2009. Para estudos sobre a noção de democracia procedimental e consenso, consultar: HABERMAS, Jürgen. *Direito e democracia*: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebenichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997.v. I e II; HABERMAS, Jürgen. *Teoría de la acción comunicativa*. Traducción de Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Taurus, 1987.

²⁴³ O estudo mais aprofundado do princípio republicano será realizado no subitem 6.4.2 do capítulo sexto. Aqui, para uma referência inicial, pode-se consultar: ATALIBA,

partir de um processo de constitucionalização do Direito Administrativo e humanização (personalização) de seus contornos.

Do entrelaçamento dos princípios republicano, do Estado democrático de direito e da dignidade da pessoa humana resultam os fundamentos para a construção dos pressupostos, institutos e limites deste renovado regime jurídico-administrativo. Com a superação do paradigma tradicional da axiomática prevalência abstrata e apriorística do interesse público sobre o particular, avança-se para o paradigma emergente da Administração Pública democrática, fundada na centralidade da dignidade humana, na prevalência dos direitos fundamentais e no modelo de ponderação proporcional de interesses.

Esta reedificação do regime jurídico-administrativo seguramente reclama uma profunda reestruturação de diversos institutos e teorias que fundam a disciplina jurídico-administrativa, agora sobremaneira colonizada pela personalizadora ordem constitucional. Por conseguinte, o conceito de interesse público passa, inequivocamente, por uma adequação à carta de direitos fundamentais, pelo princípio da dignidade da pessoa humana e pela teoria da ponderação de interesses. Uma relação indelevelmente marcada e reconfigurada pelo deslocamento da centralidade relacional do Estado para a pessoa humana.

As críticas ao paradigma tradicional da teoria da supremacia perpassam vários prismas e matizes, dentre os quais o lógico, o epistemológico, o axiológico, o ideológico e o normativo-conceitual. Todos serão apresentados e debatidos, a iniciar pelas críticas à insubsistência do (assim designado) “princípio” da supremacia do interesse público sobre o particular, a partir do parâmetro lógico.

3.3.1 A crítica lógica ao paradigma tradicional da supremacia do interesse público

Uma primeira crítica que pode ser dirigida ao princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, diz respeito a sua já denunciada inconsistência lógica. De início, cumpre dizer que haveria aqui uma impropriedade enunciativa preliminar. Sim, porque, se é possível dizer que aquela noção abstrata de interesse público primário absorveria integralmente os interesses privados, a partir da ideia de um todo orgânico e indissociável, em última análise todos os interesses e

Geraldo. **República e constituição**. 2. ed. atualizada por Rosolea Miranda Folgosi. São Paulo: Malheiros, 1998.

direitos passariam a ser abarcados pela totalizante esfera do público. Então, qual a utilidade e mesmo a possibilidade de se defender a existência de um princípio abstrato que enuncie a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, se *in abstracto* todos os interesses estariam (direta ou indiretamente) abrangidos pela concepção totalizante de interesse público?

Há aqui uma clara incongruência enunciativa. O melhor seria, então, não mais falar em um princípio relacional²⁴⁴, de supremacia do interesse público sobre o particular, mas somente do princípio da supremacia do interesse público, em termos absolutos.

Mas há, ainda, outra objeção lógica à teoria da supremacia, nos seus contornos relacionais comumente formulados. Se o enunciado é o da prevalência abstrata do interesse público sobre o particular, como seriam resolvidos aqueles casos em que a contraposição ocorre entre dois ou mais interesses qualificados como públicos? Se ambos aprioristicamente preponderam, como seria resolvida a questão em concreto? Por certo, aqui não se está falando de casos em que o próprio legislador constitucional ou infraconstitucional já tenha inclinado a balança de preferência para determinado interesse. Quando isso acontece, ressalva-se alguma argumentação de inconstitucionalidade a ser debatida, deve-se privilegiar a construção decisória normativa, uma vez que *a priori* fundada em um legítimo procedimento democrático de escolha e promoção de interesses.

Com efeito, para o caso de contraposições concretas entre dois ou mais interesses públicos normativamente reconhecidos, a resposta da teoria da supremacia seria um silêncio total. Na melhor das hipóteses se ouviria, como resposta, aquele recorrente “nada a declarar”, já que nenhuma implicação ou utilidade prática poderia ser extraída, não havendo outra saída que não o uso dos métodos comuns ao modelo de ponderação proporcional, com todas as suas peculiaridades e deveres de explicitação das premissas e das razões da escolha operada pela respectiva autoridade competente.

Mas existe, ainda, outra importante indagação: Se a noção de interesse público comum ao paradigma tradicional é aquela de contornos abrangentes e totalizantes, que contempla os interesses privados como traços constitutivos do interesse público primário, como seria possível e

²⁴⁴ Em sentido semelhante, sobre a insubsistência da noção relacional de um princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, consultar: ÁVILA, **Repensando o “princípio da supremacia...”**, p. 173-174.

qual seria a utilidade de se afiançar a supremacia apriorística do interesse público sobre o privado?

Esta crítica lógica, além de não ser superada pela corrente reconstitutivista do paradigma tradicional, resta aparentemente reforçada. Admitindo-se como correto dizer que a corrente reconstitutivista da supremacia pressupõe uma relação de oposição entre o interesse público e o interesse privado; que esta oposição está sujeita a uma ponderação em concreto (ponderação proporcional); mas que existe uma norma de prevalência *prima facie* e apriorística do interesse público sobre o privado; qual a viabilidade de uma cláusula normativa de supremacia do interesse público? Ao que parece, seria promovido um procedimento ponderativo (relacional), no caso concreto de conflito entre interesses públicos e privados, para ao final reconhecer o que já se sabia, que o interesse público invariavelmente prepondera²⁴⁵.

Realmente, tanto em um sentido forte (paradigma tradicional) como na sua versão fraca (corrente reconstitutivista), a teoria da supremacia se apresenta inconciliável com os contornos do paradigma emergente da Administração Pública democrática, fundado na teoria dos direitos fundamentais, na dignidade da pessoa humana e no modelo de ponderação proporcional.

Como em um jogo de dados viciados (pela prevalência abstrata do interesse público), passa-se a admitir um procedimento ponderativo *in concreto*, mas já se antevê o resultado cativo e apriorístico. Na verdade, esta insubsistência lógica conduz inequivocamente àquela tautologia já bem detectada por Binjenbojm, pela qual o princípio da supremacia afirma que o que deve prevalecer (*in abstracto*) sempre prevalecerá (*in concreto*)²⁴⁶.

Além de colocar-se distante de um efetivo modelo de ponderação proporcional, a teoria da supremacia traz em si outra grave consequência, que é a de não exigir fundamentação ou justificação das escolhas e decisões do Poder Público. Por conseguinte, não se pode negar o “*fato de a fórmula preconcebida presente no ‘princípio’ ir de encontro ao dever de fundamentação (‘dever de explicitação das premissas’) a que se sujeitam os Poderes do Estado*”²⁴⁷.

²⁴⁵ Em sentido semelhante, Gabriel de Araújo Lima é textual quando diz que essas objeções não foram superadas pela corrente reconstitutivista, que ele designa como “teoria eclética do princípio da supremacia”. Nesse sentido: LIMA, *Teoria da supremacia do interesse público*..., p. 133.

²⁴⁶ BINENBOJM, *Uma teoria do Direito Administrativo*..., p. 102.

²⁴⁷ *Ibidem*, p. 98.

3.3.2 As críticas epistemológicas, axiológicas e ideológicas ao princípio da supremacia do interesse público

O paradigma tradicional da teoria da supremacia traz também consigo uma série de inconsistências, que serão aqui divididas basicamente em três âmbitos, o epistemológico, o axiológico e o ideológico. Porém, cabe advertir que não há uma separação estanque entre estas objeções, sendo mais comum uma noção de entrelaçamento e, por vezes, até complementaridade.

3.3.2.1 As críticas epistemológicas e axiológicas

Para construir uma sólida objeção filosófica, Sarmento parte da clássica dicotomia público/privado, que atravessa a construção do Direito no pensamento ocidental e atualmente sofre uma inegável reformulação, inclusive com base na redefinição da concepção de espaço público, antes necessariamente vinculada à atividade estatal e agora ampliada pelo chamado terceiro setor (público não-estatal), composto por Organizações Não Governamentais (ONGs), associações de moradores, entidades de classe e outros movimentos sociais. Sob o prisma epistemológico, o paradigma tradicional da teoria da supremacia seria justificado a partir de “*duas perspectivas diferentes, que, no entanto, mantêm alguns denominadores comuns: o organicismo e o utilitarismo*”²⁴⁸.

Mas sob quais parâmetros Sarmento relaciona a teoria da supremacia a concepções organicistas e utilitaristas? No caso do organicismo clássico, de raiz aristotélica, um dos seus traços constitutivos é a construção da ideia de comunidade política como uma espécie de “todo vivo”, sendo que os indivíduos que nela se encontram, funcionariam como órgãos dentro do corpo humano, cada qual com as suas respectivas funções. Isso levaria a se admitir, inclusive, certa relação imutável (natural) de desigualdade intrínseca entre as pessoas, cada qual contribuindo a seu modo (não por escolha) para a construção do bem comum. As comunidades políticas possuiriam fins, valores e objetivos que transcenderiam àqueles dos seus integrantes, o que conduz inexoravelmente à primazia do público sobre o privado, e, por consequência, à

²⁴⁸ Para uma síntese inicial, importaria dizer que, para “o organicismo, o interesse público seria algo superior e diferente ao somatório dos interesses particulares dos membros de uma comunidade política, enquanto, para o utilitarismo, ele confundir-se-ia com tais interesses, correspondendo a uma fórmula para sua maximização”. Nesse sentido: SARMENTO, *Interesses públicos*..., p. 52.

preponderância do Estado e da comunidade políticas sobre concepções individualistas²⁴⁹.

Esta concepção de desigualdade natural teria sido superada pelo organicismo moderno, como na matriz do idealismo/holismo hegeliano, que manteve aquela noção aristotélica clássica do indivíduo como parte do todo, mas acrescentou um marcante e indelével componente idealista de Estado como o epicentro organizador e reitor da sociedade. Para a filosofia hegeliana²⁵⁰, o Estado não seria legitimado a partir de um contrato aprovado pelos indivíduos (contratualismo), mas sim, com base em “*princípios de moralidade política imanentes aos costumes, às normas e práticas pré-jurídicas que configuram aquilo que chama de sociedade civil*”. O Estado fundado no universalismo dialético hegeliano²⁵¹ constituiu-se em “*um todo único e orgânico, que pretende comportar-se racionalmente e ordenar todas as coisas racionalmente, mas que não pode*

²⁴⁹ *Ibidem*, p. 53-54.

²⁵⁰ Embora a análise da “Filosofia do Direito” hegeliana ultrapasse os limites do presente estudo, importa trazer, ainda que em breves apontamentos, algumas considerações sobre sua noção de Estado e sociedade civil. Na linguagem teórica de George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831 d. C.), a tarefa da filosofia está em compreender aquilo que é, porquanto aquilo que é consiste na razão. O pensamento hegeliano parte da relação binomial entre a Razão e a História como os elementos integrados (dois lados de uma mesma moeda), pelo que toda a ação humana seria movida por interesses relacionados à obtenção de determinados bens. Neste sentido, o que caracteriza e diferencia a sociedade civil (sistema de necessidades) e o Estado é a natureza dos interesses que movem os homens à ação ou dos bens que pretendem por ela alcançar (se particular ou se geral): dos interesses particulares derivam ações relacionadas à sociedade civil; já o Estado decorre das ações voltadas ao interesse geral de toda a coletividade, o bem universal realizado na sua totalidade orgânica, no sentido político e não-político. Muito mais do que um simples aparato institucional, o Estado hegeliano representa o fim (síntese dialética) da atividade da vida ética de uma comunidade (família e sociedade civil), pelo que é “*somente no Estado que o homem tem uma existência racional*”. Nas palavras de Hegel: “*O Estado é a realidade em ato da Idéia moral objetiva, o espírito como vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se conhece e se pensa, e realiza o que sabe e porque sabe. No costume tem o Estado a sua existência imediata, na consciência de si, no saber e na atividade do indivíduo, tem a sua existência mediata, enquanto o indivíduo obtém a sua liberdade substancial ligando-se ao Estado como à sua essência, como ao fim e ao produto da sua atividade*”. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Princípios da Filosofia do Direito*. Tradução de Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 216.

²⁵¹ Para uma breve consideração sobre a difundida dialética hegeliana, pode-se dizer com base em Santos, que a família seria a tese, a sociedade civil funcionaria como a antítese, enquanto o Estado (espírito objetivo) representaria a síntese absoluta e imóvel, o fim supremo pelo qual se reúnem os indivíduos. Nesse sentido: SANTOS, Boaventura de Sousa. *Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade*. 6. ed. São Paulo: Cortez, 1999. p. 120.

permitir a expressão da iniciativa ou da dissensão individual, atitudes que se oporiam ao planejamento racional”²⁵².

Contra estas concepções organicistas, tanto a aristotélica clássica como a moderna fundada no holismo hegeliano, Sarmento dirige uma sólida crítica, sob diferentes aspectos. Sobre a compreensão de que o ser humano seria muito mais do que um órgão dentro de um todo maior, uma primeira objeção sustenta que o organicismo acaba por não levar a sério a pessoa humana e seu valor intrínseco enquanto indivíduo, independentemente do papel e *status* funcional-social. Em cada pessoa “*existe todo um universo de interesses, objetivos e valores próprios, irreduzíveis ao ‘todo’ de qualquer entidade coletiva; que a vida humana tem uma importante dimensão pública, mas que ela não faz sentido sem a sua dimensão privada*”, a ser cultivada por meio de objetivos próprios de cada pessoa, com autonomia em relação às finalidades da comunidade política²⁵³.

Na verdade, e já adentrando em concepções axiológico-normativas, a grande justificativa político-jurídica e filosófica para o radical combate às concepções organicistas seria a sua genética autoritária e autocrática. Representam verdadeira dinamite a implodir o edifício moderno das liberdades do indivíduo, epicentro axiológico da ordem constitucional brasileira, fundada na dignidade humana, no Estado democrático de direito e nos direitos fundamentais. Do ponto de vista jurídico, este modelo de “filosofia autoritária e liberticida” revela-se, inclusive, “*absolutamente incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, que impõe sejam as pessoas sempre tratadas como fim, e nunca como meios – consoante o célebre imperativo categórico kantiano*”, sendo inconciliável também “*com todo o ideário do Estado Democrático de Direito, que se baseia no reconhecimento do valor fundamental da autonomia pública e privada do cidadão*”²⁵⁴.

Mas, se a teoria da supremacia do interesse público, por inspiração organicista, fundada na prioridade absoluta do coletivo sobre o indivíduo e na centralidade do Estado, mostra-se incompatível com a Constituição Federal, que tem seu epicentro axiológico deslocado para a dignidade da pessoa humana, haveria um fundamento ético à primazia do interesse público a partir de uma teoria utilitarista?²⁵⁵

²⁵² LIMA, Teoria da supremacia do interesse público..., p. 135.

²⁵³ SARMENTO, Interesses públicos..., p. 56.

²⁵⁴ *Ibidem*, p. 57.

²⁵⁵ Vale ressaltar que o termo *utilitarismo* não apresenta na teoria política e na filosofia um significado preciso, podendo designar uma série de doutrinas e teorias. O utilitarismo pode ser entendido, a partir de um ponto de vista normativo, sob a concepção de

A noção proposta por Sarmento, que faz questão de afastar qualquer relação de continuidade entre o organicismo (aristotélico clássico ou holístico-hegeliano) e as concepções utilitaristas (de raiz liberal), parte de uma doutrina de utilitarismo segundo a qual a *“melhor solução para cada problema político-social é sempre aquela apta a promover em maior escala os interesses dos membros da sociedade”*. Neste caso, o interesse público não seria *“algo diverso e superior ao somatório da totalidade dos interesses dos componentes da comunidade política, mas como a fórmula que, em cada caso, maximizasse os interesses dos integrantes da sociedade, individualmente considerados”*²⁵⁶.

A filosofia utilitarista reconhece a igualdade intrínseca entre todas as pessoas e refuta escolhas públicas fundadas em qualquer concepção religiosa ou metafísica, alicerçando-se em uma espécie de ética consequencialista, a indicar que o *“melhor caminho a ser seguido em cada caso será aquele que promover, em maior escala, o bem-estar, o prazer, a felicidade ou as preferências racionais do maior número de pessoas”*. Já aqueles casos de conflitos entre interesses dos indivíduos devem ser resolvidos pelo sopesamento dos interesses contrapostos, sendo justificável o *“sacrifício dos interesses de um membro da comunidade sempre que este sacrifício for compensado por um ganho superior nos interesses de outros indivíduos”*²⁵⁷.

Neste aspecto característico de claro desapego a uma teoria forte dos direitos fundamentais²⁵⁸ é que reside, para Sarmento, a grande in-

que a justificação moral de determinada ação dependeria exclusivamente da sua utilidade, ou seja, das suas consequências. No sentido ético, poderia ser resumido na máxima da maior felicidade para a maioria dos indivíduos. No Dicionário de Política de Bobbio, Matteucci e Pasquino, o verbete *utilitarismo* é apresentado a partir da doutrina de vários filósofos e teóricos do pensamento político moderno. Para ilustrar: *“O termo Utilitarismo não é um termo de significado unívoco e preciso. Usado inicialmente por J. Bentham e por S. J. Mill para denotar o próprio sistema de ética normativa, e adotado para toda concepção ético-política dos dois pensadores ingleses e dos seus discípulos, o termo, ao longo do tempo, assumiu uma notável variedade de significados e hoje é usado para designar toda uma série de doutrinas ou teorias, seja de natureza fática, seja de caráter normativo, que é importante distinguir com clareza”*. BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, *Dicionário de Política...*, p. 1.274. Para o estudo do utilitarismo a partir das obras clássicas de dois dos seus mais destacados pensadores, consultar: BENTHAM, Jeremy. *Uma introdução aos princípios da moral e da legislação*. Coleção “Os Pensadores”. Tradução de Luiz João Baraúna. São Paulo: Abril Cultural, 1974; MILL, John Stuart. *Utilitarismo*. Introdução, tradução e notas de Pedro Galvão. Porto: Porto, 2005.

²⁵⁶ SARMENTO, *Interesses públicos...*, p. 58-59.

²⁵⁷ *Ibidem*, p. 59-61.

²⁵⁸ A questão da contraposição entre o *utilitarismo* e uma *teoria forte dos direitos* é enfrentada por Ronald Dworkin, com a construção de uma teoria geral do Direito que

congruência entre a filosofia moral utilitarista e a ordem constitucional nacional. A Constituição Federal sobreleva os direitos fundamentais à condição de cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, IV da CF/88), verdadeiros trunfos situados acima dos interesses das maiorias e que têm na sua vocação contramajoritária²⁵⁹ um dos seus essenciais traços normativos e filosóficos, colocando-os *“fora do comércio político, acima dos desígnios e interesses das maiorias de cada momento. Os direitos fundamentais são protegidos, portanto, mesmo quando contrariarem os interesses da maioria dos membros da coletividade”*²⁶⁰.

Mas estas críticas epistemológicas e axiológicas ao paradigma tradicional não pretendem, de forma simplista ou até pouco útil, desqualificar a teoria da supremacia a partir do seu enquadramento como organicista, holista ou utilitarista. O ponto central aqui converge para a demonstração da insubsistência de qualquer paradigma político ou normativo fundado em uma noção (forte ou fraca) de primazia do interesse estatal ou coletivo, em detrimento do indivíduo, porquanto incompatível com a ordem constitucional vigente, marcada pelo epicentro axiológico voltado para a dignidade da pessoa humana e para a promoção dos direitos fundamentais²⁶¹.

Essa firme desconstrução do princípio da supremacia, a partir de fundadas críticas epistemológicas e axiológicas, tem levantado a preocupação de parte da doutrina nacional, no sentido de identificar nas concepções do paradigma emergente a defesa de concepções neoliberais²⁶².

não exclua nem o raciocínio moral nem o raciocínio filosófico, em um modelo baseado nos princípios do liberalismo individualista, nos quais fundamenta uma filosofia política liberal sobre bases mais progressistas e igualitárias. De fato, a filosofia jurídica dworkiniana está fundada em uma forte teoria dos direitos, que encara os direitos individuais, sobretudo o direito à igual consideração e respeito, como verdadeiros trunfos frente à maioria. Por conseguinte, enquanto teoria que justifica a subordinação dos direitos individuais a finalidades coletivas e objetivos sociais, o utilitarismo estaria posicionado em sentido contraposto a uma autêntica teoria dos direitos. Nesse sentido: DWORKIN, Ronald. *Los derechos en serio*. Traducción de Marta Guastavino. 2. ed. Barcelona: Ariel Derecho, 1989, p. 31.

²⁵⁹ Para uma análise mais aprofundada da noção dos direitos como trunfos contra a maioria e da vocação contramajoritária dos direitos fundamentais, consultar: NOVAIS, Jorge Reis. Direitos como trunfos contra a maioria: sentido e alcance da vocação contramajoritária dos direitos fundamentais do Estado de direito democrático. In: CLÈVE, Clémerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho (Org.). *Direitos humanos e democracia*. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 80-113.

²⁶⁰ SARMENTO, *Interesses públicos...*, p. 61-62.

²⁶¹ LIMA, *Teoria da supremacia do interesse público...*, p. 136-137.

²⁶² Nesse sentido: DI PIETRO, *O princípio da supremacia do interesse público...*, p. 94-100.

Nesta quadra, Irene Patrícia Nohara sustenta que a teoria desconstrutivista “tanto pode servir a um **discurso ultraliberal**, no sentido de restaurar a noção de liberdade incondicionada do particular em buscar os meios e fins de sua conduta”, como pode também “servir ao **discurso neoliberal**, que objetiva impor restrições ao intervencionismo estatal na economia”²⁶³.

A crítica que acusa o paradigma emergente de flertar com quaisquer concepções de individualismo extremado ou mesmo de neoliberalismo²⁶⁴, conquanto respeitável, não parece minimamente consistente. Pelo menos, não nos contornos aqui defendidos. Cabe asseverar que nem de longe se pretende desconsiderar a importantíssima e festejada esfera dos direitos coletivos e sociais, que tão magistralmente identificam a Constituição Federal, para render homenagens a qualquer modelo de individualismo extremado, pois todos acarretam a supressão da dimensão coletiva e social dos direitos fundamentais. Na verdade, isso conduziria a uma noção de Estado mínimo, de claro jaez neoliberal, o que não encontra eco no sistema constitucional brasileiro.

O paradigma defendido aqui é outro. Por tudo o que restou até aqui consignado, parece que a perspectiva filosófica e política mais adequada a uma dinâmica, complexa e multifária ordem constitucional como a brasileira, seja, sim, o personalismo (centralidade da pessoa humana), que suplanta aquela clássica visão de autonomia do indivíduo e “reconhece os múltiplos obstáculos materiais para o seu exercício, que devem ser removidos, com o auxílio do Estado, para que a liberdade saia do plano metafísico e ganhe concretude na vida de seres humanos de carne e osso”²⁶⁵.

Realmente, a concepção do personalismo assume uma posição de conformidade axiológica com a ordem constitucional, algo efetiva-

²⁶³ NOHARA, Irene Patrícia. Reflexões críticas acerca da tentativa de desconstrução do sentido da supremacia do interesse público no Direito Administrativo. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves (Coord.). **Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do Direito Administrativo**. São Paulo: Atlas, 2010. p. 141.

²⁶⁴ Uma breve, mas dura e abalizada, crítica ao neoliberalismo pode ser recuperada de Bonavides, quando assim se manifestou: “O Neoliberalismo é a Internacional do Capitalismo em sua versão mais atroz e funesta de dominação universal. Fundou o império dos mercados e das finanças em substituição do império das armas e dos Exércitos. Porque são mais fáceis a conquista e a escravidão pela moeda do que por meios militares”. BONAVIDES, Paulo. **Teoria constitucional da democracia participativa**: por um Direito Constitucional de luta e resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 32.

²⁶⁵ SARMENTO, **Interesses públicos...**, p. 65-74.

mente inconciliável no caso do paradigma tradicional da teoria da supremacia.

Esta noção de “personalização do Direito” tem assumido um amplo espaço no debate do Direito Administrativo. Partindo do discurso acerca da centralidade da dignidade humana, já em 1999 Justen Filho falava textualmente na “**personalização do Direito Administrativo**” e na necessária e profunda revisão de seus institutos e práticas, inclusive a partir da redefinição do conceito de interesse público, com a afirmação da supremacia do princípio da dignidade humana e na “**rejeição à supremacia da burocracia sobre a sociedade civil**”²⁶⁶.

Sob as balizas axiológicas da ordem constitucional vigente, aliçada no princípio da dignidade humana, na promoção dos direitos fundamentais e na ponderação entre os diferentes interesses albergados, não obstante ainda fizesse referência ao princípio da supremacia do interesse público, o que foi mais recentemente superado²⁶⁷, Justen Filho já o definia como instrumento de satisfação da dignidade humana, pelo que nenhum “**governante pode legitimar suas decisões através da pura e simples invocação ao interesse público. Será necessário, sempre, demonstrar como os efeitos concretos da decisão conduzirão à realização do princípio da dignidade da pessoa humana, segundo o espírito do ordenamento jurídico**”²⁶⁸.

3.3.2.2 As críticas ideológicas

Àquelas fundadas e sofisticadas críticas de matriz epistemológica e axiológica, acrescem-se objeções de fundo marcadamente ideológico²⁶⁹. Desta maneira, Luciana Gaspar Melquiades Duarte oferece uma

²⁶⁶ JUSTEN FILHO, **Conceito de interesse público...**, p. 125-129.

²⁶⁷ JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito Administrativo de espetáculo. In: ARAGÃO, Alexandre dos Santos; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coord.). **Direito Administrativo e seus novos paradigmas**. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 79.

²⁶⁸ JUSTEN FILHO, **Conceito de interesse público...**, p. 129-130.

²⁶⁹ O termo ideologia é aqui empregado a partir de uma perspectiva marxista, que foi identificado por Bobbio como sendo o “sentido forte”. Por conseguinte, convém ilustrar: “No intrincado e múltiplo uso do termo, pode-se delinear, entretanto, duas tendências gerais ou dois tipos gerais de significado [...] ‘significado fraco’ e de ‘significado forte’ da Ideologia. No seu significado fraco, Ideologia designa o **genus**, ou a **species** diversamente definida, dos sistemas de crenças políticas: um conjunto de ideias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos. O significado forte tem origem no conceito de Ideologia de Marx, entendido como falsa consciência das relações de domínio entre as classes, e se diferencia claramente do primeiro porque mantém, no próprio centro, diversamente modificada, corrigida ou alterada pelos vários autores, a noção da fal-

interessante crítica ideológica ao paradigma tradicional da teoria da supremacia, a partir da análise da evolução histórica e das diferentes teorias de justificação filosófica, sociológica e política do Estado e “*sua demarcação pelo envolvimento com os interesses de dominação, de manutenção do status quo, que garante primazia social das elites econômicas*”²⁷⁰.

Com base em uma noção marxista de Estado²⁷¹, Duarte procura demonstrar que sob este conceito não subjaz apenas uma noção (quase romântica) de entidade política que busca os legítimos fins pretendidos pela sociedade. Há também “*seu lado perverso, que consiste, justamente, na expressão da vontade dos poderosos, dos detentores da força econômica, cujo apoio revela-se imprescindível para a própria estabilidade e perenidade do ente público*”, sendo que “*os rumos que ele confere à sociedade são aqueles necessários para assegurar a manutenção dos interesses econômicos dessa classe hegemônica*”²⁷².

Esta crítica de viés marxista, construída a partir do chamado materialismo histórico²⁷³, vem embebida em um caldo de inegável realismo, sobretudo no caso do Brasil. Neste quadrante, parece correto afirmar que, embora o Estado represente e persiga uma noção de interesse

cidade: a Ideologia é uma crença falsa. No significado fraco, Ideologia é um conceito neutro, que prescinde do caráter eventual e mistificante das crenças políticas. No significado forte, Ideologia é um conceito negativo que denota precisamente o caráter mistificante de falsa consciência de uma crença política”. BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, *Dicionário de Política...*, p. 585. Para estudos complementares sobre a questão da “ideologia”, consultar: KONDER, Leandro. *A questão da ideologia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

²⁷⁰ DUARTE, Luciana Gaspar Melquiades. Outros fundamentos para a revisão do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. *Revista Eletrônica da Faculdade Metodista Granbery*. Juiz de Fora, v. 01, p. 01-27, 2006, p. 10. Disponível em: <<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25508-25510-1-PB.pdf>>. Acesso em: 13 jan. 2014.

²⁷¹ Sobre a concepção marxista de Estado, Streck e José Luiz Bolzan de Moraes esclarecem que o Estado seria uma entidade de dominação, a serviço dos poderosos, o grande mediador entre a classe operária e a burguesia capitalista, reprimindo as manifestações daqueles e viabilizando a manutenção do *status quo* favorável aos interesses destes últimos. Daí porque deveria ser abolido. Os autores reforçam essa dimensão marxista do Estado como um “*um fenômeno original e histórico de dominação. Observe-se, assim, que o Estado moderno, em sua primeira versão (absolutista), nasce das necessidades do capitalismo ascendente, na (ultra)passagem do período medieval*”. Nesse sentido: STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. *Ciência política e teoria geral do Estado*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 30-41.

²⁷² DUARTE, *Outros fundamentos...*, p. 24-25.

²⁷³ Para uma análise da teoria do materialismo histórico, consultar: HABERMAS, Jürgen. *Para a reconstrução do materialismo histórico*. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990.

público, não se pode descuidar das práticas dos poderes estatais, pois há uma linha muito tênue e facilmente dissimulável entre a efetiva promoção de interesses da sociedade em geral e a camuflada defesa de interesses egoísticos das classes dominantes, inclusive como meio de retroalimentação de um ciclo vicioso de perpetuação daqueles mesmos grupos de interesses no poder.

De fato, sob a égide do paradigma tradicional da teoria da supremacia, longe daquela ideia de supremacia do interesse público na defesa e construção de um Estado social e democrático de direito (mais justo e materialmente igualitário), o realismo da prática brasileira historicamente reproduzida demonstra sim, um completo aproveitamento, efetivo aparelhamento de interesses mesquinhos e egoísticos, por vezes acobertados pelos “donos do poder” sob a vagueza e a indeterminação do conceito de interesse público.

Em sentido semelhante, Borges também denuncia que o interesse público, objeto das mais sórdidas “*manipulações, sempre tem sido invocado, através dos tempos, a torto e a direito, para acobertar as ‘razões de Estado’, quando não interesses menos nobres, e, até, inconfessáveis*”, não sendo raro vê-lo “*manejado por certas administrações públicas como verdadeiro escudo, que imunizaria de quaisquer críticas suas posições autoritárias, e as resguardaria até, em nome de pretensa independência de poderes, do imprescindível controle do Poder Judiciário*”²⁷⁴.

Ainda que não tenha inicialmente refutado a teoria da supremacia, Nohara é incisiva em reconhecer o elevado *deficit* de legitimação do processo de democracia formal que prepondera no panorama atual, o qual prejudica uma real participação da sociedade na construção dos diversos e antagônicos interesses e nas relações de poder. A autora reconhece o papel meritório da ideologia, capaz de “*criticar uma concepção superficial de que o Estado e o Direito seriam referenciais neutros de realização do ser humano*”, o que impõe considerar, ainda, que “*por trás do rótulo ‘interesse público’ ou ‘interesse comum’*”, existem sujeitos concretos, “*historicamente situados e pertencentes a determinadas classes sociais*”. E arremata, afiançando o cabimento de uma crítica ideológica, quando alerta para a armadilha da suposição, “*no sistema democrático, que os valores são submetidos a uma discussão geral; contudo, as ideias e teorias são frequentemente determinadas pela hegemonia e pelo ‘poder espiritual’ dos valores que interessam à classe dominante*”²⁷⁵.

²⁷⁴ BORGES, *Supremacia do interesse público...*, p. 137.

²⁷⁵ NOHARA, *Reflexões críticas...*, p. 140.

Mais do que uma incongruência lógica, epistemológica e axiológica, a teoria da supremacia do interesse público, que no Brasil historicamente posicionou o conceito de interesse público de modo muito próximo e quase indissociável do Estado, pode sim, representar “*um risco ao indivíduo, uma vez que o Poder Público, ao pretexto de atuar em nome da coletividade e na persecução do bem comum, de fins públicos, camufla os interesses das elites, garantindo sua manutenção no poder*”, o que acabaria por permitir situações em que se viria a “*imolar o indivíduo em prol de objetivos escusos e velados dos poderosos*”²⁷⁶.

No Brasil, uma verdadeira genética do que se pode designar por um “patrimonialismo impregnado” toma ares de autêntico Mefistófeles²⁷⁷ a seduzir e enganar os incautos (ou mal-intencionados). Mediante sutis discursos de ocasião, grupos de interesses egoísticos e até estruturas criminosas se infiltram no aparelho estatal e usam, de forma inescrupulosa, discursos de legitimação abstrata como o princípio da supremacia do interesse público.

A teoria da supremacia, na melhor das boas intenções (vale frisar), já foi endeusada pelo paradigma tradicional como a “medida de todas as coisas” (para lembrar a máxima de Protágoras), razão finalística e instrumental última da Administração Pública e do Estado. Mas, na prática, tem servido ao longo da história republicana nacional para encobrir e afastar do conhecimento do povo toda uma ordem de sortilégios e práticas patrimonialistas dos quais a frágil República brasileira jamais conseguiu se desvencilhar.

Tanto que, ainda em 1958, o jurista e historiador Raymundo Faoro demonstrava as profundas raízes históricas do patrimonialismo nacional, do modelo de “*estamento burocrático*”²⁷⁸ e toda a sorte de ma-

²⁷⁶ DUARTE, *Outros fundamentos...*, p. 25.

²⁷⁷ Alusão metafórica a Mefistófeles, personagem satânico de “*Fausto*”, obra-prima do escritor e poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe. Na clássica tragédia, empenhado em roubar almas humanas por meio da sedução e do convencimento a suas vítimas, pela libertação daqueles dogmas divinos usurpadores da liberdade, Mefistófeles aparece ao velho cientista Dr. Fausto, que decide entregar-lhe sua alma em troca da plenitude da sabedoria, do rejuvenescimento e do amor de uma bela donzela. GOETHE, Johann Wolfgang von. Fausto. *Coleção A Obra-Prima de cada Autor*. São Paulo: Martin Claret, 2002.

²⁷⁸ Embora ultrapasse os limites desse estudo a análise mais detida do pensamento de Max Weber (1864-1920), cabe registrar que a percuciente crítica de Faoro, que denuncia o modelo patrimonialista brasileiro referido como “estamento burocrático”, parte da difundida matriz weberiana dos tipos de dominação (dominação racional-legal, dominação tradicional e dominação carismática), definidos como tipos ideais ou puros, mas que não atuam de forma isolada ou estanque na sociedade, uma vez que os

zelas do Poder Público brasileiro, que remontam ao Brasil Colônia e sua relação com a Coroa Portuguesa, protraindo-se por toda a formação evolutiva dos seus modelos e estruturas políticas (Colônia, Império, Primeira e Segunda Repúblicas, Estado Novo), como uma das mais marcantes características do Estado brasileiro através dos tempos (estrutura de poder patrimonialista estamental)²⁷⁹.

Realmente, não se pode perder de vista que estes estamentos burocráticos se perpetuam a partir de uma camuflada (e sofisticada) prática de retroalimentação, em que até variam e se renovam as pessoas no poder, mas os procedimentos são sempre os mesmos, com reduzidas variações. Por conseguinte, estes “*estamentos organizados se apropriam do Estado, de seus cargos e funções públicas, impondo-se um regime de uso dessas vantagens advindas do status ocupado para a utilização da máquina estatal em proveito próprio, para a satisfação de interesses particulares. Eles são os verdadeiros ‘donos do poder’*”²⁸⁰.

Neste contexto, em um país que nem sequer alcançou os patamares mínimos de maturidade republicana (radical republicanaização dos espaços públicos) e democrática (efetiva democratização das decisões políticas) dos poderes constituídos e da sociedade, o paradigma tradicional da teoria da supremacia assume clara condição de “poder simbólico”, naquele significado oferecido por Pierre Bourdieu, um poder invisível, quase mágico, que somente pode ser exercido com uma forte dose de

referidos tipos ideais de dominação admitem uma constante mutação, zonas de transição e diálogos com os diferentes “princípios de legitimidade dos governos”, aqueles instrumentos de dominação usados pelos governos para assegurar a autoridade dos dominantes e a obediência dos dominados. Para o pensamento weberiano, a relação entre dominação e Administração é direta e intestina, de modo que estudar a Administração é estudar a dominação. Sobre o tema, consultar: CAMPANTE, Rubens Goyatá. O patrimonialismo em Faoro e Weber e a Sociologia brasileira. *Revista Dados – Revista de Ciências Sociais*. Rio de Janeiro, v. 46, n. 1, p. 153-193, 2003; WEBER, Max. *Economia e Sociedade*: fundamentos da sociologia compreensiva. Tradução de Regis Barbosa e Karen Elzabe Barbosa. Brasília: Editora da UnB, 1999; OLIVO, Luís Carlos Cancellier de. Aspectos de uma teoria política weberiana. *Revista Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos*, Florianópolis, v. 21, n. 40, p. 121-139, jul. 2000.

²⁷⁹ Nas palavras de Faoro, “*os estamentos governam, as classes negociam. Os estamentos são órgãos do Estado, as classes são categorias sociais (econômicas)*”. FAORO, Raymundo. *Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro*. 4. ed. Porto Alegre: Globo, 1977.v. I, p. 47.

²⁸⁰ SILVEIRA, Daniel Barile da. *Patrimonialismo e a formação do Estado brasileiro: uma releitura do pensamento de Sergio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Oliveira Vianna*. Anais do Congresso Nacional do CONPEDI, Manaus, p. 01-20, 2010, p. 11-12. Disponível em: <<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/Daniel%20Barile%20da%20Silveira.pdf>>. Acesso em: 13 jan. 2014.

cumplicidade e ignorância tanto daqueles que a ele estão sujeitos como daqueles que o exercem²⁸¹. Um potente elemento (instrumental) que, por vezes, facilita a reprodução de um peculiar modelo de dominação estatal, sutilmente colonizável por egoísticos e privatísticos (ilegítimos) movimentos nacionais ou estrangeiros de apropriação do espaço público.

Na verdade, sem a construção de uma cultura de radical defesa da Constituição, instrumentalizada por uma rígida catequese de profunda democratização e republicanização do Estado e da Sociedade, com a criação de uma doutrina forte de eficácia dos direitos fundamentais, o ritual de exorcismo do patrimonialismo estatal não estará consumado e seus fantasmas continuarão a assombrar a sociedade brasileira e desacreditá-la das suas instituições. Um exorcismo que somente restará completo se atacados todos aqueles outros “ismos” claramente afilhados do patrimonialismo estatal brasileiro, como o fisiologismo, o clientelismo, o corporativismo, o nepotismo etc.

3.3.3 As críticas ao caráter conceitual-normativo da supremacia do interesse público

A admissão da existência de um princípio jurídico que assegure *prima facie* a prevalência abstrata do interesse público sobre o privado acaba por subverter a própria concepção de princípios constitucionais. As contemporâneas teorias dos princípios se mostram totalmente inconciliáveis com qualquer ideia de um princípio absoluto, capaz de prevalecer (*a priori*) sobre todos os demais, independentemente de qualquer jogo circunstancial de parâmetros fáticos e jurídicos. Esta crítica conceitual e normativa representa, seguramente, uma das mais consistentes objeções ao paradigma tradicional da teoria da supremacia (quer na sua dimensão forte, quer nos seus contornos reconstrutivistas).

No Brasil, Humberto Ávila procedeu a uma das primeiras manifestações doutrinárias de objeção crítica à supremacia do interesse público, enquanto princípio jurídico. Em artigo originariamente publicado em 1998²⁸², a partir de uma concepção conceitual e normativa de

²⁸¹ BOURDIEU, Pierre. **O poder simbólico**. Tradução de Fernando Tomaz. 7. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

²⁸² ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. **Revista Trimestral de Direito Público**. São Paulo, n. 24, p. 159-180, 1998. Convém esclarecer que aqui será usada a versão (inalterada) daquele artigo, republicada em 2005, no livro organizado por Sarmento. Esta obra, que conta com as contribuições críticas do próprio Sarmento, de Ávila, de Binenbojm, de Alexandre

princípios constitucionais, Ávila demonstra a insubsistência da definição da supremacia do interesse público como princípio, bem como a incompatibilidade da sua concepção axiomática com a noção de postulado normativo.

Esta crítica conceitual ao caráter principiológico da teoria da supremacia se assenta na difundida distinção das normas jurídicas em duas espécies, as normas-regra e as normas-princípio, o que passa a ser (ainda que brevemente) apresentado a seguir.

3.3.3.1 Breve recuperação da distinção estrutural entre regras e princípios

Conforme já se disse alhures, a consolidação do Estado constitucional de direito trouxe consigo a sedimentação da teoria da normatividade dos princípios jurídicos²⁸³. Esta sofisticada doutrina constitucional-contemporânea, desenvolvida sobre as bases de uma teoria material da Constituição, teve como principais precursores autores como Carl Schmitt²⁸⁴, Rudolf Smend²⁸⁵ e Hermann Heller²⁸⁶. Pode-se indicar, mais recentemente, outros grandes representantes, dentre os quais seguem destacados Konrad Hesse²⁸⁷, Friedrich Müller²⁸⁸, Peter Häberle²⁸⁹, Dworkin²⁹⁰ e

Santos de Aragão e de Paulo Ricardo Schier, representa um verdadeiro manifesto, em *terrae brasilis*, com a proposição de muitas das bases teóricas para superação do paradigma tradicional da teoria da supremacia. Nesse sentido: SARMENTO, **Interesses públicos...**, 2005.

²⁸³ Para uma análise da teoria dos princípios constitucionais no discurso jurídico contemporâneo, consultar: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. Sobre o neoconstitucionalismo e a teoria dos princípios constitucionais. In: AGUILA GRADOS, Guido Cesar; CAZZARO, Kleber; SATAFFEN, Márcio Ricardo (Org.). **Constitucionalismo em mutação**: reflexões sobre as influências do neoconstitucionalismo e da globalização jurídica. Blumenau: Nova Letra, 2013. p. 45-74.

²⁸⁴ SCHMITT, Carl. **Teoría de la Constitución**. Traducción de Francisco Ayala. Madrid: Alianza, 2001.

²⁸⁵ SMEND, Rudolf. **Constitución y Derecho Constitucional**. Traducción de José María Beneyto Pérez. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985.

²⁸⁶ HELLER, Hermann. **Teoria do Estado**. Tradução de Lycurgo da Motta. São Paulo: Mestre Jou, 1968.

²⁸⁷ HESSE, Konrad. **Escritos de Derecho Constitucional**. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2. ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992.

²⁸⁸ MÜLLER, Friedrich. **Direito, linguagem, violência**: elementos de teoria constitucional, I. Tradução de Peter Naumann. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1995.

²⁸⁹ HÄBERLE, Peter. **Hermenêutica constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição**: contribuição para uma interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997.

Robert Alexy²⁹¹, estes dois últimos com profunda influência e relevância no contexto do debate contemporâneo sobre a teoria dos princípios.

Apenas para retratar uma recuperação histórica, Bonavides ilustra que fora Jean Boulanger quem tratou de forma precursora da normatividade dos princípios, a eles se referindo como os materiais pelos quais a doutrina pode “edificar com confiança a construção jurídica”, sustentando a existência não somente de uma diferença de importância entre princípio e regra jurídica, mas também de natureza. A generalidade das regras não seria aquela mesma que marca os princípios. As regras seriam gerais na medida em que regulam um número indeterminado de fatos ou atos, mas especiais porque regem uma situação jurídica determinada. Já os princípios seriam gerais no sentido de comportar uma série indefinida de aplicações²⁹².

Embora de inegável conteúdo polissêmico²⁹³, a concepção clássica de princípios jurídicos está intimamente ligada à noção de fundamento, suporte, base, pressuposto teórico que orienta e confere coerência a todo o arcabouço lógico e teleológico do sistema jurídico. Nesse sentido, os princípios constitucionais são normas que sustentam todo o ordenamento jurídico, tendo por função principal conferir racionalidade sistêmica e integralidade (integridade) ao ordenamento constitucional. Podem ser expressos mediante enunciados normativos ou figurar implicitamente no texto constitucional. Constituem-se em orientações e mandamentos de natureza informadora da racionalidade do ordenamento e capazes de evidenciar a ordem jurídico-constitucional vigente. Não servem apenas de esteio estruturante e organizador da Constituição, pelo que veiculam normas constitucionais de eficácia vinculante na proteção e garantia dos direitos fundamentais.

A concepção estrutural (morfológica) dos princípios constitucionais e a conformação normativa das regras e princípios, segundo Alexy, constituem “o marco de uma teoria normativo-material dos direitos fun-

²⁹⁰ DWORKIN, *Los derechos...*, 1989; DWORKIN, Ronald. *O império do Direito*. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999; DWORKIN, Ronald. *Uma questão de princípio*. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

²⁹¹ ALEXY, Robert. *Teoría de los derechos fundamentales*. Traducción de Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993; ALEXY, Robert. *Teoria da argumentação jurídica*. A teoria do discurso racional como teoria da justificação jurídica. Tradução de Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 2001.

²⁹² BONAVIDES, *Curso de Direito Constitucional...*, p. 239-240.

²⁹³ Nesse sentido: CARRIO, Genaro R. *Principios jurídicos y positivismo jurídico*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1970. p. 33-34.

damentais e, com isso, um ponto de partida para responder à pergunta acerca da possibilidade e dos limites da racionalidade no âmbito dos direitos fundamentais”²⁹⁴.

De fato, uma das primeiras e mais originais contribuições à distinção estrutural entre regras e princípios²⁹⁵ pode ser recuperada da filosofia jurídica dworkiniana, um modelo teórico fundado em uma forte teoria dos direitos, que encara os direitos individuais, sobretudo o direito à igual consideração e respeito, como verdadeiros trunfos frente à maioria. Uma teoria individualista e antiutilitarista que não admite a superioridade das diretrizes políticas ou objetivos sociais frente a um genuíno direito.

Conforme a clássica distinção, Dworkin sustenta que as regras são aplicáveis à maneira de um “tudo ou nada” (*all-or-nothing*), ou são completamente aplicáveis ou não possuem nenhuma aplicação. Portanto, atestado que determinada questão prática atende aos pressupostos fáticos hipoteticamente previstos pela regra, sendo ela válida, deve ser aplicada com todas as suas consequências jurídicas. Já os princípios constituem-se em “razões para decidir”, não sendo aplicáveis automaticamente quando satisfeitas as condições previstas como suficientes a sua aplicação, característica que lhes confere a qualidade de critérios que devem ser levados em conta quando da decisão judicial²⁹⁶.

Ademais desta primeira qualidade distintiva, o jusfilósofo estadunidense sustenta outro traço a partir da dimensão do peso ou importância (típica dos princípios). Se para a resolução de um problema acorrer uma pluralidade de princípios em oposição, há que se considerar o peso relativo de cada um deles, conferindo-se prevalência ao que apresentar maior densidade, sem que isso implique a invalidação dos demais²⁹⁷. As regras, por

²⁹⁴ ALEXY, *Teoría de los derechos...*, p. 81-82.

²⁹⁵ Para uma abalizada análise da distinção entre regras e princípios na doutrina de Dworkin e Alexy, consultar: SILVA, Luís Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. *Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais*. Belo Horizonte, v. 1, p. 607-630, 2003.

²⁹⁶ DWORKIN, *Los derechos...*, p. 75-76.

²⁹⁷ Vale ressaltar que a teoria forte dos princípios de Dworkin está sujeita a uma série de críticas (algumas delas até consistentes), no sentido de pôr em dúvida essa distinção lógica ou estrutural entre regras e princípios jurídicos. O próprio autor admite textualmente que a forma de um *standard* nem sempre deixa indubitosa sua qualidade de princípio ou regra jurídica, havendo casos em que ambos podem desempenhar funções muito semelhantes, quando a distinção acaba se consubstanciando quase que exclusivamente em uma questão de forma. Para uma análise da teoria jurídica dworkiniana e algumas das críticas a ela dirigidas, consultar: CRISTÓVAM, *Sobre o neo-constitucionalismo...*, p. 127-136; PRIETO SANCHÍS, Luis. *Sobre principios y normas: problemas del razonamiento jurídico*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. p. 79-86.

outro lado, não possuem a dimensão do peso ou importância e quando em conflito, da aplicação de uma decorre necessariamente a invalidação das demais, segundo critérios determinados pelo ordenamento jurídico²⁹⁸.

Outra original contribuição na construção da distinção estrutural-normativa entre regras e princípios é oferecida por Alexy, para quem as regras seriam normas que se constituem em mandamentos definitivos, sendo que os direitos baseados em regras são direitos definitivos. Já os princípios seriam normas que ordenam que algo deva ser feito na maior medida fática e juridicamente possível. Estando as possibilidades jurídicas determinadas por regras e por outros princípios opostos, há exigência de ponderação, sendo que os direitos baseados em princípios não seriam definitivos e sim *prima facie*.

A distinção alexyana abandona o âmbito gradual e avança para aspectos qualitativos. Deste modo, os princípios seriam normas que ordenam a realização de determinado direito na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. As regras somente poderiam ser cumpridas ou não, pelo que, se uma regra é válida, deve ser cumprida na sua exata medida, nem mais nem menos. Já os princípios funcionariam como “*mandamentos de otimização*”²⁹⁹.

Com efeito, afirmar que a medida do cumprimento dos princípios está vinculada às possibilidades jurídicas significa dizer que a aplicação de determinado princípio depende diretamente dos princípios e regras jurídicas àquele contrapostos. Da mesma forma, a vinculação às possibilidades fáticas atesta que o conteúdo dos princípios somente pode ser determinado a partir do problema prático (concreto). Portanto, pode-se dizer que os princípios veiculam obrigações *prima facie*, que podem ser derogadas por outros princípios em caso de colisão, ao passo que as regras instituem obrigações absolutas, que não podem ser superadas por outras regras, devendo ser cumpridas na sua exata medida.

Ainda que não imune a críticas³⁰⁰, a distinção estrutural defendida por Alexy fica clara no momento da resolução das colisões entre

²⁹⁸ DWORKIN, *Los derechos...*, p. 77-78.

²⁹⁹ ALEXY, *Teoría de los derechos...*, p. 86-87.

³⁰⁰ Da sua teoria, não fica claro se Alexy procura, efetivamente, oferecer um conceito de princípios constitucionais como mandamentos de otimização ou se, realmente, apenas descreve um modelo de aplicação/julgamento, conforme usado pelo Tribunal Constitucional Federal alemão. Apesar disso, segundo sustenta Luis Prieto Sanchís, as características de mandamento de otimização e máxima da ponderação não caberiam exclusivamente aos princípios, mas também para algumas regras que não se apresentam na forma binária, mas gradual. Por conseguinte, a ideia de mandamento de otimização teria aplicação tanto para os princípios como para as regras, não servindo como critério

princípios e dos conflitos entre regras, situações em que duas normas, aplicadas independentemente, conduzem a resultados incompatíveis (juízos contraditórios de dever ser jurídico). Na doutrina de Alexy, enquanto o conflito entre regras se resolve no plano da validade, com a invalidação de uma das regras em conflito ou a introdução de uma cláusula de exceção capaz de solucionar a contradição, a colisão entre princípios se resolve no plano do valor, tendo em vista as circunstâncias do caso, em uma “*relação de precedência condicionada*”³⁰¹.

3.3.3.2 A insubsistência da supremacia do interesse público como princípio constitucional

Conforme visto no item anterior, o discurso jurídico contemporâneo constrói a concepção normativa dos princípios constitucionais, a partir de um modelo de distinção estrutural-qualitativo e das distintas formas de resolução de conflitos entre regras e princípios jurídicos. Para uma síntese daquelas lições de Alexy, pode-se dizer que as regras, como mandamentos definitivos, veiculariam obrigações absolutas, devendo ser aplicadas sempre que presentes os pressupostos fáticos hipoteticamente previstos na norma, na sua exata medida predeterminada. Já os princípios veiculariam obrigações *prima facie*, sendo que sua aplicação dependerá sempre das condições fáticas e jurídicas correspondentes (deveres/mandamentos de otimização), a partir de uma relação de precedência condicionada àquelas referidas questões fáticas e jurídicas (ponderação *in concreto*).

Desta maneira, Ávila conclui pela insubsistência conceitual da ideia de supremacia do interesse público enquanto princípio constitucional, porquanto “*sua descrição abstrata permite apenas uma medida de concretização, a referida ‘prevalência’, em princípio independente das possibilidades fáticas e normativas*”, o que impõe concluir que “*sua abstrata explicação exclui, em princípio, a sua aptidão e necessidade de ponderação, pois o interesse público deve ter maior peso relativamente ao interesse particular*”³⁰², sendo plenamente infensa a qualquer ponderação.

Na forma como está enunciado, e pelo conteúdo que lhe é atribuído pelo paradigma tradicional, o princípio da supremacia do interesse

decisivo de diferenciação. A ideia de mandamento de otimização representaria antes uma técnica de argumentação, que pode ser útil na aplicação de qualquer *standard* normativo, e não um critério de diferenciação qualitativa entre regras e princípios. Isso equivale a dizer que essa diferenciação normativa fundada na ideia de mandamento de otimização parece melhor caracterizar uma distinção funcional que morfológica ou estrutural. Nesse sentido: PRIETO SANCHÍS, *Sobre principios...*, p. 46-50.

³⁰¹ ALEXY, *Teoría de los derechos...*, p. 87-92.

³⁰² ÁVILA, *Repensando o “princípio da supremacia...”*, p. 184.

público estaria a representar uma espécie de “relação abstrata de prevalência absoluta” do interesse público sobre o privado, uma situação em tudo inconciliável com a teoria jurídica contemporânea. Sim, porque no atual discurso jurídico (teoria do Direito), os princípios constitucionais não dispõem de valor em si (dimensão/peso abstrato), ostentando somente condições de prevalência quando da sua aplicação, dependendo das circunstâncias do caso concreto, o que se pode chamar de “relação concreta de prevalência relativa”³⁰³.

Com efeito, segundo os contornos do paradigma tradicional, a supremacia do interesse público acaba por funcionar como uma espécie de Medusa mitológica, a petrificar e tornar estática toda e qualquer dinâmica de conflitos entre direitos e interesses submetidos a sua ótica. Por isso, possui muito mais um aspecto de “regra abstrata de preferência no caso de colisão”, a pender sempre e invariavelmente a favor do interesse público, no caso de conflitos com interesses particulares³⁰⁴. Mas essa concepção de regra abstrata de prevalência absoluta é totalmente inconciliável, do ponto de vista normativo e axiológico, com o modelo de Estado constitucional de direito, marcado por uma teoria forte dos direitos fundamentais e pela centralidade do princípio da dignidade humana.

Além dessa inconsistência conceitual, do ponto de vista normativo, a noção de um princípio implícito da supremacia do interesse público não encontra fundamento de validade e é mesmo inconciliável com a ideia de unidade e coerência normativa da ordem constitucional. A Constituição Federal foi prodigiosa na consagração e na defesa da esfera individual do sujeito, linha de concordância lógica e axiológica que permeia todo o texto constitucional, desde os seus princípios fundamentais (arts. 1º a 4º da CF/88), passando pelo extenso e não exaustivo rol de direitos e garantias individuais fundamentais (arts. 5º a 17 da CF/88), até uma série de outras normas setoriais que protegem o indivíduo contra uma desmedida sanha fiscal do Estado (arts. 145 a 156 da CF/88) e que asseguram o liberalismo econômico e financeiro (art. 170 da CF/88).

A ordem constitucional brasileira protege as liberdades individuais, a intimidade, a privacidade, a igualdade, a segurança, a propriedade privada etc. Nas palavras de Ávila, “direitos subjetivos são protegidos, procedimentos administrativos garantidos; o asseguramento da posição dos indivíduos de seus interesses privados é estabelecido frente ao concorrente interesse público”, sendo que a qualificação de cidadã tipicamente conferida à Constituição Federal decorre justamente da “particular

³⁰³ *Ibidem*, p. 185-186.

³⁰⁴ *Ibidem*, p. 185.

insistência com que protege a esfera individual e pela minúcia com que define as regras de competência da atividade estatal”³⁰⁵.

Como resultado interpretativo desse caldo normativo constitucional, que resguarda amplamente os interesses individuais e a esfera privada do sujeito, em uma radical virada axiológico-normativa, Ávila até arrisca ilustrar a possibilidade de se cogitar, inclusive, da existência sim, de uma espécie de “ônus de argumentação” assecuratório dos interesses privados e em prejuízo dos bens coletivos, pelo qual, em igualdade de condições ou em casos de dúvidas, a prevalência deveria ser dada aos interesses privados, ante a fundamentalidade que assumem no atual modelo de Estado constitucional de direito³⁰⁶.

3.3.3.3 Pode-se aceitar a noção de supremacia do interesse público como um postulado normativo?

Interessante, ainda, debater acerca da possibilidade de a supremacia do interesse público ser aceita como verdadeiro postulado normativo extraído da ordem constitucional vigente. Para os contornos aqui delineados, a noção de postulados normativos será aquela oferecida por Ávila, enquanto normas que traduzem “condições de possibilidade do conhecimento do fenômeno jurídico”, pelo que não oferecem “argumentos substanciais para fundamentar uma decisão, mas apenas explicam como (mediante a implementação de quais condições) pode ser obtido o conhecimento do Direito”³⁰⁷.

³⁰⁵ *Ibidem*, p. 186-187.

³⁰⁶ Ávila parte de um texto de Alexy para apresentar esta ideia do “ônus de argumentação em favor dos interesses privados e em prejuízo dos bens coletivos”, mas não chega a defender que uma norma com este conteúdo (*in dubio pro libertate*) teria fundamento de validade na ordem constitucional brasileira. Mas alerta, inclusive, que o seu conteúdo (se existente) não seria comum a uma espécie de regra absoluta ou relativa de prevalência. “Esse ônus diz respeito, apenas, a uma valoração abstrata e relativa do indivíduo (incluindo, aí, seus interesses) na Constituição brasileira, no sentido de um ônus de argumentação em favor do indivíduo, a exigir que ‘devam corresponder razões maiores para a solução exigida pelos bens coletivos do que para aquelas exigidas pelos direitos individuais’”. *Ibidem*, p. 187.

³⁰⁷ Partindo de uma noção kantiana, Ávila esclarece que postulado “significa uma condição de possibilidade do conhecimento de determinado objeto, de tal sorte que ele não pode ser apreendido sem que essa condição seja preenchida no próprio processo de conhecimento. Os postulados variam conforme o objeto cuja compreensão condicionam. Dai dizer-se que há postulados normativos e ético-políticos”. ÁVILA, Humberto. *Revista Diálogo Jurídico*. Salvador, v. I, n. 4, p. 01-36, jul. 2001, p. 18. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_4/dialogo-juridico-04-julho-2001-humberto-avila.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2014.

Deste modo, essas “condições de possibilidade do conhecimento jurídico reveladas pela hermenêutica jurídica consubstanciam postulados normativos”, aquilo que a “doutrina comumente denomina de ‘princípio como ideia normativa geral’ (ou princípio explicativo), como fundamento ou pressuposto para o conhecimento do ordenamento jurídico ou de parte dele”³⁰⁸.

Na linha do discurso jurídico contemporâneo, pode-se afirmar a impossibilidade da dedução de um fundamento de validade constitucional à supremacia do interesse público, como postulado normativo na Constituição Federal. Realmente, este paradigma tradicional da teoria da supremacia mostra-se, inclusive, incompatível com outras normas extraídas da ordem constitucional vigente e amplamente reconhecidas como válidas, como as máximas da proporcionalidade e da concordância prática, que Ávila identifica como postulados normativos³⁰⁹.

Admitir a validade normativa de um postulado constitucional da supremacia do interesse público sobre o particular, em um sistema constitucional que alberga uma norma que impõe o dever de proporcionalidade como parâmetro de aferição da constitucionalidade e da regularidade axiológica na concretização das demais normas jurídicas corresponderia a aceitar como válidas duas estruturas normativas abstratamente inconciliáveis. Uma que imporia um dever abstrato de prevalência do interesse público (teoria da supremacia); outra que determinaria a ponderação, no caso de conflitos ou colisões entre normas concretamente consideradas, quer assecuratórias de interesses privados (individuais) quer protetivas de interesses públicos (coletivos). Isso equivaleria a admitir como válida uma fatal incongruência sistemática, em total prejuízo às exigências de “adequação valorativa” e “unidade interior” do próprio sistema constitucional³¹⁰.

Mas haveria, ainda, a possibilidade de se defender a existência de um postulado normativo da supremacia do interesse público sobre o particular, a funcionar como um verdadeiro postulado explicativo do

³⁰⁸ Nesse sentido: “[...] o conhecimento da norma pressupõe o do sistema e o entendimento do sistema só é possível com a compreensão das suas normas (postulado da coerência); só é possível conhecer a norma com a análise simultânea do fato, e descrever os fatos com recurso aos textos normativos (postulado da integridade); só é possível conhecer uma norma tendo em vista a sua pré-compreensão pelo sujeito cognoscente, definida como a expectativa quanto à solução concreta, já que o texto sem a hipótese não é problemático, e a hipótese, por sua vez, só surge com o texto (postulado da reflexão)”. *Ibidem*, p. 19.

³⁰⁹ ÁVILA, Repensando o “princípio da supremacia...”, p. 191.

³¹⁰ Aqui as expressões “adequação valorativa” e “unidade interior” do sistema constitucional são empregadas naquela dimensão conceitual usada por Canaris. Nesse sentido: CANARIS, Pensamento sistemático..., p. 14-22.

regime jurídico-administrativo e da relação Estado-cidadão. Não no sentido de uma ideia fundamental ético-política, imanente à própria sociedade e desprovida de qualquer necessária positivação, que “represente uma necessidade racional para a comunidade política”, mas como postulado normativo conformador e ordenador do regime de Direito Público³¹¹.

Esta ideia também não encontra asilo na ordem jurídica brasileira, basicamente por duas fortes razões: Primeiro, porque não há no ordenamento jurídico nacional qualquer fundamento político-jurídico que leve à defesa de uma automática supremacia dos interesses públicos sobre os particulares; quando em conflito interesses públicos e privados relacionados, a solução decorrerá de um processo de ponderação entre as condições fáticas e jurídicas que povoam aquele conjunto de interesses reciprocamente implicados, o mesmo valendo para os conflitos entre interesses públicos (que também carecem de ponderação). Segundo, porque o Direito Administrativo contemporâneo não consegue mais dar conta de toda a complexidade em que está inserido somente a partir daquela tradicional contraposição bipolar entre Estado-cidadão, ou melhor, entre interesse público e interesse privado. A multiplicidade de novas figuras e relações administrativas multipolares (interesses individuais, sociais, de grupos) está a exigir uma nova perspectiva fundamental ao Direito Administrativo, com a superação (e não a afirmação) da ideia de supremacia do interesse público³¹².

3.4 HÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE PARA UM PRINCÍPIO DO INTERESSE PÚBLICO NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO?

Afastada a possibilidade de uma defesa da teoria da supremacia do interesse público, nos mais variados e sólidos contornos, inclusive

³¹¹ ÁVILA, Repensando o “princípio da supremacia...”, p. 204-205.

³¹² Ávila faz referência, como exemplo, a uma série de figuras administrativas que não estão relacionadas àquela contraposição entre interesses públicos e interesses privados, como “administração cooperativa e Estado cooperativo (decorrência da privatização de serviços públicos ou mesmo da necessidade de fiscalização e cooperação em novas áreas como meio ambiente, saúde pública, comunicações, telefonia, correios, mídia eletrônica, as quais não revelam tanto relações antinômicas, mas uma coordenação recíproca entre vários interesses”, bem como novos conceitos de Direito Administrativo (a redefinição do conceito de serviço público sem a titularidade do Estado) e a ideia de Direito Administrativo multipolar (interesses individuais, sociais, de grupos etc.). *Ibidem*, p. 207-210.

demonstrada a sua insubsistência enquanto norma-princípio e também enquanto postulado normativo, remanesce uma relevante questão: Haveria fundamento de validade para um princípio do interesse público no ordenamento jurídico nacional?

Não naquele sentido conferido pelo paradigma tradicional, enquanto norma abstrata de prevalência do interesse público sobre o particular (teoria da supremacia), mas como princípio normativo compatível conceitual, lógica e axiologicamente com o paradigma emergente da Administração Pública democrática, conciliável com o princípio da dignidade humana, a eficácia dos direitos fundamentais e a ponderação de interesses.

Vale, de início, o alerta de que o debate em torno da existência de fundamento de validade, na ordem jurídica brasileira, para um princípio do interesse público, não indica que se esteja refluindo de quaisquer das considerações já lançadas contra o paradigma tradicional da teoria da supremacia. Por conseguinte, adverte Sarmento que, se *“a subordinação dos direitos individuais ao interesse coletivo pode ser a ante-sala para totalitarismos de variados matizes”*, não se pode negar também que *“a desvalorização total dos interesses públicos diante dos particulares pode conduzir à anarquia e ao caos geral, inviabilizando qualquer possibilidade de regulação coativa da vida humana em comum”*.³¹³

3.4.1 O princípio do interesse público na ordem infraconstitucional

No prisma infraconstitucional, importa reconhecer que a Lei Federal 9.784, de 29.01.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei do Processo Administrativo Federal), em seu art. 2º é expressa em assegurar que a *“Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”*.

Inclusive, convém ilustrar que, poucos dias antes do advento daquela legislação federal, no Estado de São Paulo foi editada a Lei Estadual 10.177, de 30.12.1998, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública daquela unidade federativa, também com idêntica consagração em seu art. 4º do princípio do interesse público: *“A Administração Pública atuará em obediência aos princípios da legalida-*

³¹³ SARMENTO, *Interesses públicos...*, p. 28.

de, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos atos administrativos”.

A previsão do princípio do interesse público pela legislação ordinária é expressa. Mas isso não retira a necessidade de um debate normativo-conceitual: Seria este enunciado normativo efetivamente uma norma-princípio? Ou poderia, embora positivado como princípio, veicular uma regra jurídica?

Nesse sentido, tanto partindo daquela distinção estrutural de Dworkin (aplicação das regras a um “tudo ou nada” e a densidade comum aos princípios, aplicados como razões para decidir), ou se empregada aquela oposição morfológico-qualitativa defendida por Alexy (regras como mandamentos definitivos (absolutos) e princípios como mandamentos de otimização, aplicáveis segundo as condições fáticas e jurídicas e precedência), ou, ainda, se assumida a original proposta conceitual oferecida por Ávila (regras como normas de conduta que estabelecem indiretamente fins, com a prescrição em maior exatidão do comportamento devido; princípios como normas finalísticas que estabelecem diretamente fins, com a previsão mais aberta do comportamento devido)³¹⁴, não parece adequado ou possível dizer que a norma trazida pelo art. 2º da Lei Federal 9.784/99, quando impõe à Administração Pública a obediência ao princípio do interesse público, estaria a ostentar o caráter de norma-regra, do tipo aplicável a um “tudo ou nada”; ou a veicular deveres absolutos; ou, inclusive, a funcionar como norma de conduta a indicar indiretamente fins, prescrevendo com maior exatidão o comportamento devido. Sua estrutura normativo-conceitual está sim, a veicular autêntico princípio jurídico.

³¹⁴ Inegavelmente, a proposta distintiva de regras e princípios oferecida Ávila representa um importante contributo para a teoria do Direito e para o debate jurídico contemporâneo. Por conseguinte, e apenas para apresentar a “fórmula sintetizada” dos critérios de distinção, Ávila define os princípios como *“normas que estabelecem diretamente fins, para cuja concretização estabelecem com menor exatidão qual o comportamento devido (menor grau de determinação da ordem e maior generalidade dos destinatários), e por isso dependem mais intensamente da sua relação com outras normas e de atos institucionalmente legitimados de interpretação para a determinação da conduta devida”*. Já as regras são definidas como *“normas que estabelecem indiretamente fins, para cuja concretização estabelecem com maior exatidão qual o comportamento devido (maior grau de determinação da ordem e maior especificação dos destinatários), e por isso dependem menos intensamente da sua relação com outras normas e de atos institucionalmente legitimados de interpretação para a determinação da conduta devida”*. Nesse sentido: ÁVILA, *A distinção entre princípios e regras...*, p. 21. Para um estudo mais detido da sua teoria dos princípios, consultar: ÁVILA, *Teoria dos princípios...*, 2004.

Realmente, no marco da legislação infraconstitucional resta inequívoca a consagração do princípio do interesse público, de cogente obediência pela Administração Pública Federal e aplicável subsidiariamente³¹⁵ a todas as demais esferas estaduais e municipais da Federação, o que remete à necessária indagação acerca da sua conformidade à ordem constitucional, ou seja, da sua constitucionalidade (princípio da supremacia da Constituição).

Pela hermenêutica constitucional contemporânea³¹⁶, ressaltada a hipótese da construção de uma tese a defender a inconstitucionalidade

³¹⁵ Nesse sentido: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – REsp. 1.148.460/PR – 2ª T. – Rel. Min. Castro Meira – j. em 19.10.2010 – DJe em 28.10.2010. Brasília. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaelectronica/ita.asp?registro=200900305180&dt_publicacao=28/10/2010>. Acesso em: 09 jan. 2014; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – REsp. 1200981/PR – 1ª T. – Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima – j. em 05.10.2010 – DJe em 14.10.2010. Brasília. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaelectronica/ita.asp?registro=201001303750&dt_publicacao=14/10/2010>. Acesso em: 09 jan. 2014.

³¹⁶ Embora não seja objeto central do presente estudo, a temática relacionada à hermenêutica constitucional contemporânea é aqui recorrente, o que indica a referência, ainda que breve, ao pensamento de Hans-Georg Gadamer (1900 – 2002), seguramente um dos mais importantes filósofos do século XX sobre o tema. Profundamente influenciado pelos estudos de Martin Heidegger (1889 – 1976), de quem foi aluno e assistente na *Philipps-Universität Marburg*, em sua obra “Verdade e Método”, publicada originariamente em 1960, Gadamer apresenta sua teoria acerca da hermenêutica filosófica, a partir da crítica ao pensamento filosófico cartesiano, fundado na “suposta” racionalidade do método (técnicas e meios científicos) e na ruptura com as estruturas das instituições e da tradição. Para a hermenêutica filosófica gadameriana a historicidade desempenha um papel fundamental, em contraposição à hegemonia do método e à ideia de enquadramento da verdade, com base em uma proposta teórica que pretende voltar à fenomenologia das coisas, com a interpretação do mundo do ser desvinculada daqueles rígidos e aprisionadores padrões e condições da metódica racionalista moderna. Para Gadamer, mais do que um método científico, a hermenêutica deve ser entendida como o desvelar de um texto pela via da história de seus efeitos, sem desconsiderar os preconceitos e as tradições do intérprete, sempre inserido em um período e em um dado contexto cultural. Diversamente da aposta filosófica do racionalismo moderno, o homem é um personagem da história e vê (interpreta) o mundo e todas as coisas a partir de determinados preconceitos e tradições culturais. As questões relacionadas à tradição, aos preconceitos, à autoridade, à “distância temporal”, à “consciência da história dos efeitos”, ao “círculo hermenêutico” e ao “problema hermenêutico da aplicação” são algumas das categorias centrais à hermenêutica filosófica gadameriana que, embora não possam ser aqui debatidas, guardam repercussão direta com a hermenêutica jurídica contemporânea. Mais do que uma técnica ou um modelo para a decodificação de um texto, a hermenêutica jurídica constrói-se pelo constante, aberto e dialético movimento de compreensão, interpretação e reinterpretação de um texto, cabendo mais ao intérprete descobrir a pergunta a que o texto vem responder, do que a própria resposta. Uma relação dialógica de perguntas e respostas entre o intérprete e o texto, restando àquele superar seus prejulgamentos e preconceitos, abrindo-se ao diá-

da norma (total ou parcial inconstitucionalidade, com ou sem redução de texto, interpretação conforme a Constituição)³¹⁷, pelo princípio da presunção de constitucionalidade das leis, suas prescrições normativas devem ser consideradas constitucionalmente válidas.

Mas interessa, por certo, cogitar a sua compatibilidade constitucional. Nesta quadra, o fundamento axiológico e conceitual-normativo para a constitucionalidade do princípio do interesse público, nos limites e contornos aqui delineados, pode ser buscado a partir do próprio princípio republicano, aqui entendido como um dos princípios estruturantes do novo regime jurídico-administrativo³¹⁸, juntamente com os princípios da dignidade humana e do Estado democrático de direito. O princípio republicano traz em si, como decorrência implícita (imane), a noção de defesa e consecução (não de supremacia ou prevalência abstrata) dos interesses públicos extraídos da ordem normativa constitucional e infraconstitucional³¹⁹.

logo e à experiência que brota da compreensão do texto e da linguagem. Sobre o tema, consultar: GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e Método**: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1998; GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e Método II**: complementos e índice. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2002; STRECK, Lenio Luiz. **Verdade e consenso**: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.

³¹⁷ Para uma análise panorâmica do controle de constitucionalidade, consultar: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional e teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 887-1058; MENDES, Gilmar; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

³¹⁸ A noção de princípios estruturantes, aqui empregada, como de resto nas diversas outras ocorrências da expressão, é aquela oferecida pelo constitucionalista português José Joaquim Gomes CANOTILHO, que será apresentada no item 6.1 do capítulo sexto. Nesse sentido, consultar: CANOTILHO, **Direito Constitucional**..., p. 1.173-1.175.

³¹⁹ Inclusive, essa noção de centralidade do princípio republicano para o regime jurídico-administrativo talvez encontre concordância em Ávila. Diz-se talvez, porque parece que, em sentido semelhante, o autor assim se manifesta, em passagem que procura demonstrar a insubsistência do princípio da supremacia do interesse público: “A constatação de que os funcionários não representam interesses outros além do público não resulta do interesse público propriamente dito (definido, aliás, pela finalidade), mas do desinteresse, por sua vez reconduzido à função pública e ao princípio republicano. E é o princípio republicano que estrutura o bem público, a ser constatado no direito positivo. Perquirir sobre as causas que levaram o legislador a instituir prazos maiores para a administração ou a atribuir determinadas características ao ato administrativo, por exemplo, é objeto da ciência política. Seu aspecto jurídico circunscreve-se a descrever e explicar o sentido e o alcance das normas que instituíram determinadas prerrogativas que os particulares não possuem. Esse aspecto normativo,

Desta maneira, inclusive poder-se-ia cogitar certa aproximação (parcial e não comprometedor do seu conteúdo autônomo) do princípio do interesse público com aquela dimensão própria do princípio da finalidade administrativa³²⁰, que também retira sua base constitucional do princípio republicano³²¹.

3.4.2 O interesse público como princípio constitucional implícito

Admitido como adequado o teste positivo de constitucionalidade do princípio do interesse público, expressamente previsto pela legislação infraconstitucional, interessa agora discutir se tal princípio não teria o *status* de verdadeiro princípio constitucional implícito, a extrair seu fundamento de validade constitucional do próprio princípio republicano.

Na verdade, uma das características constitutivas da noção de princípio implícito³²² é o de não poder ser considerado como sentido dire-

contudo, nada tem a ver com um princípio de supremacia". ÁVILA, Repensando o "princípio da supremacia...", p. 201.

³²⁰ No sentido da relação entre o princípio do interesse público e o princípio da finalidade administrativa, consultar: MEIRELLES, *Direito Administrativo...*, p. 108.

³²¹ Lima faz referência, ainda que breve, ao princípio da finalidade como decorrência do princípio republicano. Nesse sentido: LIMA, *Teoria da supremacia do interesse público...*, p. 131.

³²² No que toca à noção de princípios constitucionais implícitos, Prieto Sanchís oferece interessantes considerações, partindo do modelo tipológico de Jerzy Wróblewski, com a classificação dos princípios em expressos, implícitos e extrassistemáticos. Por conseguinte, princípios constitucionais implícitos seriam aqueles que não podem ser considerados como o sentido direto e imediato de alguma disposição constitucional, sendo obtidos a partir de um exercício de descoberta de uma ou várias disposições que se constituem em casos de aplicação ou especificação de tais princípios. Por meio de um exercício lógico e axiológico de analogia, são obtidos determinados princípios que, embora não expressamente dispostos no texto da Constituição, integram implicitamente o ordenamento constitucional. O procedimento que identifica os princípios implícitos é a analogia, enquanto generalização a partir de uma ou várias normas do ordenamento jurídico, em um processo de criação ou reconhecimento de um princípio geral. O raciocínio analógico não ostenta uma natureza estritamente lógico-formal, sendo informada por um componente axiológico que fundamenta os juízos de semelhança, tornando o processo de reconhecimento dos princípios implícitos suscetível de discussão e interpretações diversas. Assim, a discricionariedade dos juristas ocupa um lugar destacado no processo de identificação dos princípios constitucionais implícitos. Vale ressaltar que os princípios constitucionais implícitos decorrem tanto de um processo indutivo como dedutivo. No primeiro caso, o princípio é identificado como o elemento central de um conjunto de disposições que refletem casos semelhantes e se constitui em norma generalizante capaz de disciplinar novos casos análogos. No se-

to e imediato de alguma norma constitucional³²³, mas descoberto por meio de um raciocínio lógico e axiológico de analogia, por meio dos novos parâmetros de hermenêutica e interpretação constitucional³²⁴.

Deste modo, e até como decorrência lógica e axiológica da característica estruturante do princípio republicano, que perpassa a ordem constitucional e contribui para a efetiva construção de um conceito de unidade da Constituição, pode-se reconhecer a existência de um claro bloco de legitimação e sustentação (suporte) constitucional do princípio do interesse público.

Um inventário somente das expressas ocorrências do termo "interesse" no atual texto constitucional, se consideradas as alterações e revisões operadas pelas Emendas Constitucionais e incluído o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, registrará nada menos que 54 ocorrências nas suas mais variadas expressões qualificativas, que podem ser assim distribuídas: interesse público (arts. 19, I; 37, IX; 57, § 6º, II; 66, § 1º; 93, VIII e IX; 95, II; 114, § 3º; 128, § 5º, I, "b" da CF/88; e arts. 51, §§ 2º e 3º do ADCT); interesse social (arts. 5º, XXIV, XXIX e LV; 127, *caput*; 184, *caput* e § 2º da CF/88; e arts. 71, *caput* e 79, *caput* do ADCT); interesse coletivo, difuso, geral ou comum (arts. 5º, XXXIII; 25, § 3º; 129, III; 173, *caput*; 192, *caput* e 200, I da CF/88); interesse nacional e de

gundo, parte-se da argumentação pela qual uma norma constitucional geral guarda relação de implicação com o princípio implícito, sendo este uma consequência lógica daquela, reforçada pelos valores ou interesses tutelados pela norma explícita. PRIETO SANCHÍS, *Sobre princípios...*, p. 142-146.

³²³ Apenas para fins de ilustração, é ideia corrente na nova hermenêutica constitucional que não se pode confundir ou reduzir a complexa e dinâmica ideia de norma jurídica à concepção de texto normativo (enunciado, dispositivo). O texto é o enunciado linguístico, ao passo que a norma é o produto da interpretação deste enunciado normativo. Para estudos complementares, consultar: GRAU, Eros Roberto. *Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito*. São Paulo: Malheiros, 2002; STRECK, Lenio Luiz. Diferença (ontológica) entre texto e norma: afastando o fantasma do realismo. *Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa*. Lisboa, v. XLVI, p. 55-86, 2006.

³²⁴ No discurso constitucional contemporâneo, estudo que tem consolidado enorme relevo para a teoria constitucional, refere-se ao que se pode, genericamente, designar como o debate em torno da nova hermenêutica e interpretação constitucional. Sobre o tema, consultar: BARROSO, Luís Roberto. *Interpretação e aplicação da Constituição*: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; COELHO, Inocêncio Mártires. *Interpretação constitucional*. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007; STRECK, Lenio Luiz. *Hermenêutica jurídica e(m) crise*: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013; STRECK, Lenio Luiz. *Jurisdição constitucional e hermenêutica*: uma nova crítica do Direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

soberania (arts. 12, § 4º, I; 148, II; 172, *caput*; 176, § 1º; 231, § 5º da CF/88; e arts. 36, *caput* e 44, § 1º do ADCT); interesse local (arts. 30, I e V da CF/88); interesse dos Entes Federados (arts. 29, XIII; 52, V; 109, I e IV; 144, § 1º, I; 155, § 2º, V, “b” e 231, § 6º da CF/88); interesses fazendários nacionais (art. 237, *caput* da CF/88); interesse do Governo brasileiro (art. 52, parágrafo único do ADCT); interesse econômico (artigo 71, *caput* do ADCT); interesses de grupos ou categorias (arts. 5º, LXX, “b”; 8º, III; 9º, *caput*; 10, *caput*; 129, V; 149, *caput*; 202, § 6º e 232, *caput* da CF/88); interesse particular, pessoal ou individual (arts. 5º, XXXIII e XXXIV, “b”; 56, II; 127, *caput* da CF/88; e art. 47, § 5º do ADCT).

Certamente, não se pode reduzir a normatividade constitucional sobre a questão que envolve o interesse público a este emaranhado e controverso grupo de disposições constitucionais. Além de simplista, incompleto e inadequado, isto ressoaria inclusive quase inútil. Mas a função explicativa daquele inventário de dispositivos constitucionais é outra. Três outras, para ser mais exato.

Primeiro, parece ficar claro e reforçado que a ordem constitucional brasileira alberga um bloco de sustentação ao princípio implícito do interesse público³²⁵, a partir de uma alargada gama de normas constitucionais que prestigiam a defesa de interesses sociais, difusos e coletivos, ancorados em maior ou menor grau na base estruturante do princípio republicano. Mas sem que isso possa significar, ainda que indiretamente, uma norma de prevalência abstrata do interesse público e, menos ainda, de uma insuperável contraposição entre o interesse público e o interesse individual. Isso já foi devidamente afastado pelas análises anteriormente realizadas, não sendo o caso agora retornar àquela temática.

Em um segundo plano, igualmente relevante, fica evidente que a Constituição Federal não reduziu e nem conduziu a noção de interesse público a um significado estatal, sendo plenamente possível estabelecer uma relação de diferenciação entre interesses públicos (mais relacionados àqueles direitos sociais, difusos e coletivos) e os reais interesses do aparato estatal, dos Entes Federados, do Fisco e do Governo. Isso reforça a ideia da construção de um conceito de interesse público que não se esgote no Estado ou a ele não esteja essencial e visceralmente vinculado.

³²⁵ Este também parece ser o entendimento de Sarmiento, não para admitir um princípio de prevalência abstrata do interesse público (teoria da supremacia), mas um princípio de tutela do interesse público, no sentido de que é dever da Administração perseguir o interesse público. Nesse sentido: SARMENTO, *Supremacia do interesse público...*, p. 125.

Em um terceiro prisma, também muito importante, não se pode desconsiderar que, assim como a ordem constitucional alberga estruturas normativas de defesa do interesse público, há também destacada guarida a legítimos interesses particulares (individuais, de grupos e corporações).

Nesse sentido, a partir das bases estruturantes do princípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CF/88) e da prodigiosa carta de direitos e garantias individuais, que não se resumem àqueles insculpidos no artigo 5º e suas dezenas de incisos, com defesa das liberdades individuais, os direitos civis em geral, a livre-iniciativa (direitos econômicos), também exsurge cristalino o *status* constitucional da proteção aos direitos e interesses particulares (privados).

Não se quer com isso, nem indiretamente, defender uma tese antagônica de supremacia dos direitos individuais sobre os interesses coletivos, o que representaria também uma inconcebível ruptura com o sistema (teleológico-valorativo) constitucional vigente. Como adverte Sarmiento, “a tese da superioridade incondicional dos direitos individuais diante dos interesses da coletividade parece assentar-se sobre premissa antropológica distorcida, própria a um superado individualismo liberal-burguês, que via nas pessoas humanas seres isolados e desenraizados”³²⁶.

Curioso, inclusive, é o fato de que a Constituição Federal, a despeito de ser caracterizada por uma profunda abrangência normativa (prolixa), mesmo assim não apresenta qualquer enunciado normativo que estabeleça (de forma abstrata e normativa) uma rota de colisão ou mesmo concorrência entre interesses públicos e privados. Isto, inclusive, reforça a completa ausência de fundamento normativo ou justificativa axiológica para uma norma (abstrata) de prevalência (absoluta) do interesse público sobre o particular, inclusive porque não parece possível extrair uma necessária relação de conflito constitucional abstrato entre interesses públicos e privados.

3.4.3 A não retomada do paradigma tradicional

Não se pode negar que o reconhecimento do caráter normativo do princípio do interesse público enquanto princípio implícito (*status* constitucional) traz alguns questionamentos: Isto não resultaria no amplo respaldo ao paradigma tradicional da teoria da supremacia? Não equivaleria à manutenção da teoria da supremacia do interesse público e todas as suas indesejáveis consequências? Não haveria aqui a simples (e aparente)

³²⁶ SARMENTO, *Interesses públicos...*, p. 28.

revisão de nomenclatura do princípio, com a manutenção do seu conteúdo normativo e simbólico? Ostentaria este princípio do interesse público conformidade com o conjunto de direitos fundamentais que compõe o sistema constitucional vigente? Essas questões merecem análise.

Importa, primeiramente, afastar a objeção continuísta de que haveria apenas um falso ataque (de nomenclatura) ao paradigma tradicional, com a desqualificação conceitual-normativa à teoria da supremacia, para, posteriormente, reconhecer a existência de um princípio do interesse público como norma constitucional implícita, com idêntico conteúdo normativo daquele comum à teoria da supremacia.

Com efeito, a negação ao paradigma tradicional da prevalência do interesse público sobre o particular não é enfraquecida pelo reconhecimento do princípio do interesse público, nos contornos já delineados. Não restaura aquela contradição conceitual-normativa de estabelecer um princípio de supremacia (abstrata) do interesse público sobre o particular, uma autêntica e insubsistente regra (abstrata) de prevalência apriorística, o que resultaria em uma situação inconciliável com aquelas teorias principiológicas comumente aceitas pela doutrina jurídica contemporânea.

Assim, também se mantém suprimida aquela inadequada dimensão de perpétua e reiterada contraposição relacional entre interesses públicos (coletivos) e interesses privados (do indivíduo), comum a alguns matizes da teoria da supremacia. A ideia de que a satisfação de um interesse público envolva abstrata e invariavelmente o sacrifício a interesses particulares está privada de justificação no atual estágio da teoria constitucional.

Em uma Constituição que representa a síntese normativo-valorativa de um extenso, dinâmico e multifário mosaico de interesses públicos e privados, ambos a admitir uma atuação conjugada e complementar do Estado e da sociedade em geral (iniciativa privada), o signo de prevalência deve ser o da cooperação. Impõe-se a superação daquele reducionismo ultrapassado e insubsistente da contraposição de interesses, que somente concebe a noção de Estado contra os interesses individuais e estes como inconciliáveis com qualquer perspectiva estatal. A esfera do público não pertence (titularidade) e nem se esgota no Estado (público não estatal). A dimensão privada não se reduz a uma esfera egoística e mesquinha do sujeito.

No palco do Estado constitucional de direito, as esferas dos interesses públicos e privados dançam entrelaçadas, ao som orquestrado pelos direitos fundamentais (que se afinam e se afirmam a cada dia). E as eventuais brigas e crises (conflitos entre interesses), comuns à vida práti-

ca (concretização) deste genioso e (por vezes) egocêntrico casal, devem ser solucionadas a partir de uma adequada composição de interesses (ponderação), e não com base em um dogma apriorístico de prevalência. Juarez Freitas, embora ainda admitindo uma concepção fraca da teoria da supremacia, parece pensar em sentido semelhante a esse, quando reconhece um princípio do interesse público em “*simultânea subordinação das ações administrativas à dignidade da pessoa humana e o fiel respeito aos direitos fundamentais*”³²⁷.

Em linhas semelhantes parece conduzir-se o pensamento de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que sustenta a existência de quatro regras básicas para a aplicação do princípio do interesse público, quando posto em concorrência com outros princípios: 1. O princípio do interesse público não excluirá de forma apriorística nenhum outro princípio concorrente, tampouco poderá ser assim excluído; 2. O princípio do interesse público “*deverá ser ponderado, em face de cada um dos demais princípios em concurso*”; 3. O princípio do interesse público, assim como todos os demais princípios concorrentes, deverá ser otimizado em sua aplicação (eficácia máxima possível); 4. O princípio do interesse público “*deverá ser motivadamente enfatizado, quando se justificar a atribuição de alguma relevância aplicativa na relação*” em causa (justificação da maior relevância atribuída)³²⁸.

A noção de um princípio do interesse público, arquitetado a partir desses limitados contornos e sem qualquer vocação de prevalência abstrata, acaba por superar também aquela concepção da supremacia do interesse público como princípio estruturante do regime jurídico-administrativo. Afasta-se aqui aquela sua condição de verdadeira pedra de toque a irradiar justificação e legitimação conceitual, normativa e axiológica ao sistema de prerrogativas e sujeições comuns à Administração Pública e derogatórias daquela dimensão horizontalizada informativa das relações privadas.

No paradigma emergente, o regime jurídico-administrativo apresenta-se totalmente consonante à garantia dos direitos fundamentais, edificado a partir das disposições estruturantes da dignidade da pessoa humana, do Estado democrático de direito e do princípio republicano. O sistema de prerrogativas e privilégios da Administração Pública, justifi-

³²⁷ FREITAS, O controle dos atos administrativos..., p. 36.

³²⁸ MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O futuro das cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. In: ARAGÃO, Alexandre dos Santos; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coord.). *Direito Administrativo e seus novos paradigmas*. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 590.

cado como inerente e considerado decorrência lógico-axiomática do princípio da prevalência do interesse público, agora somente encontra espaço de legitimação se efetivamente compatível com a própria ordem constitucional e suas correspondentes disposições infraconstitucionais, desde que com aquela parametrizadas.

Deste modo, aquela relação de incompatibilidade axiológica do paradigma tradicional da teoria da supremacia com a ordem constitucional resta superada, pela convivência harmoniosa, no plano normativo, entre o reconhecido princípio do interesse público e o sistema de direitos fundamentais, concretizados a partir da teoria da ponderação (relação concreta de prevalência relativa).

Isto, inclusive, suplanta aquele poder simbólico e autoexplicativo da prevalência apriorística do interesse público, que diversamente de assegurar um regime de concretização privilegiada de uma ordem de supremacia dos direitos sociais e dos interesses coletivos da sociedade, na realidade prática sempre esteve a serviço de mesquinhos e egoísticos interesses (mais ou menos) acoitados sob o seletivo e tendencioso manto estatal, em um perverso circuito vicioso que se retroalimenta nas estruturas patrimonialistas das quais o Estado brasileiro jamais foi completamente exorcizado.

Afastado o paradigma tradicional da teoria da supremacia, que legava ao princípio da prevalência do interesse público o *status* axiológico de medida de todas as coisas e parâmetro capital de legitimação da atividade administrativa, norma estruturante do regime jurídico-administrativo, importa debater agora os contornos, limites e possibilidades da teoria da ponderação de interesses, que será objeto de análise do próximo capítulo.